

الأستاذ الدكتور

عبد الله مبروك النجار

العميد الأول لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر

أستاذ ورئيس قسم القانون الخاص بجامعة الأزهر

عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف

محام بالنقض ومحكم دولي

المبادئ الأساسية لعقد البيع

الطبعة الخامسة

٢٠٢٣ — ٢٠٢٤ م

حقوق الطبع محفوظة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

أحمد الله تبارك وتعالى، وأصلى وأسلم على خير خلقه وأشرف رسله، سيدنا محمد بن عبدالله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن سار على منوال شريعته إلى يوم الدين.

وبعد،،

فإن أهمية عقد البيع لا تخفى على أحد، وقد ظهرت آثار تلك الأهمية في نظر المشروع من خلال اهتمامه بالأحكام المتعلقة بعقد البيع فعالجها بنصوص اختصه بها وجعلها مثلاً يحتذى في بقية العقود الأخرى، وقد بلغ من اهتمام المشرع بهذا العقد أن تطرق إلى أدق تفاصيله، وخاصة ما يتعلق بأركانه وآثاره بالنسبة للبائع وما يجب عليه الالتزام به تجاه المشتري بخصوص نقل ملكية المبيع، وضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية، بما يكاد يشكل نظرية خاصة بالضمان في عقد البيع، وذلك فضلاً عما يشكله هذا العقد من أهمية في التطبيق العلمى للنظرية العامة للالتزام.

وهذه الأهمية التى اختص بها عقد البيع من قبل المشرع الوضعى تكاد تتفق في مجملها مع ما أولته الشريعة الإسلامية الغراء لهذا العقد، حيث اعتبره فقهاء تلك الشريعة النموذج الأكمل الذى تقوم عليه الأحكام المتعلقة بالالتزام على وجه العموم، حتى إنهم ليطلقون على جميع العقود التى يكون محلها مالا: اسم البيع بمعناه العام، وهو

مبادلة المال بالمال مطلقاً، وإن كان التعريف الاصطلاحي للبيع عندهم يحدده بالمعنى المراد به، اللهم فيما يتعلق باتساع نطاق الثمن في عقد البيع في الشريعة الإسلامية، ليشمل النقود والأعيان جميعها، وليدخل في مفهومه: المقايضة في فقه القانون، ويزيد عليها عقد السلم، وعقد الصرف.

وعلى العموم فإن الأحكام المقررة لعقد البيع في القانون الوضعي، لا تبتعد كثيراً عن الأحكام المقررة له في مذاهب الفقه الإسلامي المختلفة وخاصة فيما يتعلق بالأركان والآثار، ولم نلاحظ خلافاً في هذا المجال، عدا ما يتعلق بتقرير بعض الفوائد الربوية على البائع للمشتري في بعض حالات ضمان استحقاق المبيع، وفي موضعها من تلك الدراسة، لم أتردد في بيان مدة مخالفة تلك الفوائد لأحكام الشريعة الإسلامية على أساس أنها تدخل في مفهوم الربا المحرم شرعاً، وذلك على نحو ما سيراه القارئ، وما هو موجود بين دفتي هذا الكتاب يُعد تسجيلاً منظماً للمحاضرات التي أقيمت على طلاب السنة الرابعة بكلية الشريعة والقانون في مادة "العقود المدنية"، وهو في نظري كاف لإعطاء الطالب فكرة متكاملة عن هذا العقد، ولهذا آثرت أن أسميه: "مبادئ عقد البيع"، إذ أن محتواه لا يعدو أن يكون بداية المبتدئ في مجال موضوعه، أما من يريد التعمق في دراسة هذا العقد، فعليه بما هو مشار إليه في حاشيته من مراجع

لأستاذنا الأجل الذين تيسر لنا الاستفادة من علمهم في هذا
الموضوع، وبما هو موجود في المكتبة القانونية والفقهية وهو كثير.
أدعو الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا العمل، وأن يوفقنا جميعاً
لما يحب ويرضى، هذا بالله التوفيق،،

الأستاذ الدكتور
عبد الله النجار

عقد البيع

تمهيد

لا يخفى على أحد مدى أهمية عقد البيع، حيث يُعد من أكثر العقود شيوعاً وانتشاراً لأنه من أهم الوسائل لتبادل رءوس الأموال، والقيم بين الناس، كما أنه وسيلة رئيسية لحصول الإنسان على ما يحتاج إليه من أمور حياته وما يتصل بذلك من مأكّل ومشرب وملبس ومسكن ومركوب وغير ذلك، هذا فضلاً عن كونه وسيلة لتصرف ما يحتاج إليه الإنسان، كما يُعد في ذاته مهنة لقطاع عريض في المجتمع ممن يحترفون البيع والشراء.

وعقد شأنه كذلك، حرى بأن يستتعض في المشروع أقصى درجات الاهتمام به، لتنظيم أحكامه وعلاج ما ينشأ بشأنه من منازعات أمام القضاء، ولهذا فقد ورد عقد البيع ضمن مجموعة العقود المسماة في القانون المدني.

البيع أحد العقود المسماة:

عقد البيع هو أحد العقود المسماة؛ بل هو أحد العقود المسماة الواردة على الملكية، ومن ناقلّة القول: أن العقود تنقسم إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة، والعقود المسماة هي التي حظيت بتنظيم المشرع لها، وبيان القواعد الخاصة بها لأهميتها العملية ولكثرة تداولها

في الحياة العلمية حتى عرفت بأسمائها الخاصة^(١)، وذلك كالبيع والإيجار والشركة والوكالة والتأمين والعمل والمقاوله.

أما العقود غير المسماه: فهي تلك التي لم يرد لها تنظيم خاص في القانون، وهذه العقود لم تحظ بالحصص الدقيق من الفقه وإنما اكتفى بمجرد التمثيل لها، ومن أمثلتها عقد النشر، وعقد النزول في فندق، وعقد العلاج مع مستشفى أو طبيب.

وهناك شبه إجماع في الفقه على أن العقود غير المسماه لا تقبل الحصر وإنما الذي يحمها ما يترأى للمتعاقدين في التعامل^(٢)، وذلك وفقاً لأحكام القواعد العامة في نظرية العقد المنصوص عليها في

(١) السنهاورى - الوسيط - ج٤ - عقد البيع - ص٥ وما بعدها - طبعة ١٩٨٦م، د. محمد السعيد رشدى أحكام عقد البيع ١٩٩٢م - ص٦، د. منصور مصطفى منصور - مذكرات في العقود المسماه ١٩٥٨ - ص٢٢١، د. عبد الرازق حسن فرج - عقد البيع - ص٥ الطبعة الأولى، د. سمير السيد تناغو - عقد البيع - ص٥، د. عبد المنعم البداروى - الوجيز في عقد البيع - طبعة ١٩٧٠ - فقرة ٣٠٢، د. محمد على عمران - الوجيز في عقد البيع - طبعة ١٩٧٠ - فقرة (١)، د. خميس خضر - العقود المدنية - الكثيرة - ص٨، د. جميل الشرقاوى - العقود المدنية - البيع والمقايضة ١١٩١ - ص٣، د. عبد الودود يحيى - دروس في العقود المسماه - البيع والتأمين - ص٣ وما بعدها، دار النهضة العربية ١٩٧٨م، د. جمال زكى - قانون عقد البيع في القانون المدنى - الكويت ١٩٧٥م - ص٥ هامش (١).

(٢) د. سمير تناغو - السابق - ص٦ هامش (٢)، ومن أمثلتها أيضاً العقد الذي يبرم بين مدير مسرح وأحد الممثلين، والعقد الذي يبرم بين مستشفى وإحدى كليات الطب بوضع عدد معين من الأسرة تحت تصرفها للدروس والأبحاث الطبية، راجع: د. عبد الرازق حسن فرج - السابق - ص٥.

المواد ٨٩ - ١٦١ مدنى، وإذا لم يوجد نص في هذه المواد يمكن تطبيقه، فإنه يمكن الرجوع إلى مصادر التشريع الأخرى، كالعرف ومبادئ الشريعة الإسلامية، ومبادئ العدالة والقانون الطبيعي.

ويلاحظ أن قائمة العقود المسماة تختلف من دولة إلى أخرى، كما أنه تزيد أو تنقص مع تغير الزمن في الدولة الواحدة بحسب الزيادة أو النقص في أهمية تلك العقود في مجال التعامل، مما يجعلها محل اهتمام المشرع، فمثلاً كان القانون المدنى القديم لا يورد عقد التأمين ضمن طائفة العقود المسماة، وفي القانون المدنى الجديد تغير الأمر وأصبح عقد التأمين ضمن العقود المسماة فيه.

ومن ناحية أخرى فإن القانون المدنى الجديد لا يضع تنظيمًا خاصاً لعقود زادت أهميتها في الوقت الحاضر، مثل عقد النشر وعقد النزول في فندق، مع أن هذين العقدين يعتبران من ضمن طائفة العقود المسماة في بعض الدول، وهما على درجة كبيرة من الأهمية ترقى بهما لتنظيم المشرع المصري لهما في يوم من الأيام^(١).

والعقود المسماة الواردة في المجموعة المدنية اثنان وعشرون عقداً صنفها القانون المدنى في خمس مجموعات:

الأول: العقود التى تقع على الملكية، وهى البيع والمقايضة والهبة والشركة والقرض والصلح.

(١) د. عبد الرازق السنهورى - السابق - ص ٥، د. سليمان مرقس - عقد البيع - ص ٢ - طبعة ١٩٦٨م.

الثاني: العقود الواردة على الانتفاع بالشيء، وهى الإيجار والعارية.

الثالث: العقود التى تقع على العمل، وهى المقاوله، والتزام المرافق العامة، وعقد العمل والوديعة والحراسة.

الرابعة: عقود الغرر، أى العقود الاحتمالية، وهى المقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة، وعقد التأمين.

ويلاحظ أنه بالنسبة للعقدين الأولين وهما المقامرة والرهان، فإن المشرع قد نظم بطلانهما، لأنه قد نص على بطلانهما^(١)، أما العقدان الآخران وهما المرتب مدى الحياة وعقد التأمين فقط نظم المشرع أحكامهما عامة لأنهما غير مخالفين للنظام العام من وجهة نظره.

الخامسة: عقود التأمينات الشخصية كالكفالة، وعقود التأمينات العينية كعقد الرهن الرسمي والحيازى، وقد عولج هذان العقدان في باب الحقوق العينية التبعية لا في باب العقود، لأنهما يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالحق العيني الناشئ عنهما، فقد الرهن، حق شخصي لأنه رابطة بين دائن ومدين، ولكنه ينشأ عنه حق عيني تبعى يعطى الدائن سلطة تتبع الشيء المرهون كما يعطى الأفضلية لهذا الدائن على سائر الدائنين العاديين، أو الدائنين المرتهنيين المتأخرين عنه في المرتبة على النحو الوارد في القانون.

(١) وقد ورد في المذكرة الإيضاحية بمجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى الجديد، حرم المشرع المقامرة تحريماً أبعد من تحريم التقنين الفرنسى فكل اتفاق على مغامرة أو رهان يكون باطلاً، ويستطيع من خسر أن يسترد ما دفعه، وله أن يثبت الدفع جميع الطرق، راجع: مجموعة الأعمال التحضيرية - ج ٥ - ص ٢٠٠.

عقد البيع في الشريعة والقانون:

ولئن كان البيع مشروعاً ومنصوصاً عليه ضمن طائفة العقود المسماة في القانون، فهو مشروع أيضاً في التشريع الإسلامي، حيث دل على مشروعية كتاب الله تعالى وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وإجماع علماء المسلمين.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} ^(١).

حيث لا يخفى على من يقرأ تلك الآية الكريمة أنها تحل البيع، أى تجعله مشروعاً، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} ^(٢)، ومن المؤكد أن البيع ينطوى على نوع من التراضى في أكل المال مما يجعله مشروعاً.

ومن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ما روى عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء"، وما روى عن رافع - رضى الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن أطيّب الكسب، فقال: "عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور" ^(٣)، والتاجر هو

(١) سورة البقرة - من الآية ٢٧٥.

(٢) سورة النساء - الآية ٢٩.

(٣) سبل السلام - ج ٣ - ص ٤ ، والحديث رواه البزار وصححه الحاكم.

الذي يمارس البيع والشراء، ومدحه في الحديث على هذا النحو بدل على مشروعية البيع الذي يمارسه تصدق وأمانة. وقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة. وقد عنى القانون بتنظيم أحكام البيع في الفصل الأول من الباب الأول الخاص بالعقود التي ترد على الملكية في المواد من ٤١٨ إلى ٤٨٠ ، وتناول أحكامه بالتنظيم في فرعين جعل أولهما: البيع بوجه عام، وخصص ثانيهما: لبعض أنواع البيوع.

خطة البحث:

وسوف نقوم بدراسة العقد من خلال الأبواب الآتية:
باب تمهيدي: للتعريف بالبيع وتمييزه عما يختلط به من العقود الأخرى

الباب الأول: أركان عقد البيع

الباب الثاني: آثار عقد البيع

الباب التمهيدي
تعريف البيع وتميزه
عما يختلط به من العقود

الفصل الأول

التعريف بالبيع وبيان خصائصه

الفصل الأول

التعريف بالبيع وبيان خصائصه

المبحث الأول

تعريف عقد البيع

ورد تعريف عقد البيع في المادة (٤١٨) من التقنين المدني المصري، حيث تقول: "البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل المشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر ثمن نقدي".

وقد ورد في المذكرة الأيضاحية التقنين المدني: أن هذا التعريف يمتاز عن تعريف القانون المدني القديم بأمرين، أولهما: أنه لا يقتصر البيع علي نقل الملكية وإنما يتعدي ذلك الي أي حق مالي آخر، كحق انتفاع أو حق ارتفاع مثلاً، وقد يقع في حقوق شخصية كما في حوالة الحق، ويبين، ثانيهما: أن الثمن لابد وأن يكون من النقود وهذا وصف جوهرى في الثمن يحسن أن يذكر في التعريف، لأنه هو الذي يميز بين البيع والمقايضة، وهذا علي خلاف ما هو مقرر في الشريعة الإسلامية، ففيها أن البيع مبادلة مال بمال، فيشمل غير البيع المقاضية والمصرف^(١)، والسلم.

وينتضح من هذا التعريف أن البيع من العقود الرضائية لأن المشرع لم يشترط لانعقاده أى شكل خاص، كما أنه عقد ملزم للجانبين، حيث يلتزم البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالى آخر بينما

(١) مجموعة الأعمال التحضيرية - ج ٤ - ص ١٥.

يلتزم المشتري بدفع الثمن، وهو بالإضافة إلى ذلك من عقود المعاوضة، فكل واحد من طريفيه يتلقى عرضاً عما يبذله^(١).

كما يكشف ذلك التعريف عن قصد المشرع في تلافي ما وجه من نقد إلى تعريف القانون المدني القديم للبيع حيث كان ينص في المادة (٢٣٥)، على أنه: "عقد يلتزم به أحد المتعاقدين نقل ملكية شيء للآخر في مقابل التزام ذلك الآخر بدفع ثمنه المتفق عليه"، وقد أخذ الفقه عليه أنه يقصر محل البيع على ملكية الأشياء فقط في حين أنه لا مانع من ورود البيع على أى حق مالى آخر غير ملكية الأشياء، كحق الانتفاع أو حق الارتفاق أو حقوق الدائنين أو حق الملكية الأدبية، وقد تلاقى تعريف البيع في القانون، ما وجه إلى هذا التعريف من نقد، وجاء تعريفه للبيع بما يجعل هذه الأشياء داخلة ضمن محله^(٢).

ما يؤخذ على هذا التعريف:

وقد أخذ جانب من الفقه على هذا التعريف، أنه لا يكاد ينبئ عن أهم أثر يترتب على البيع في القانون الحديث وهو انتقال الملكية بمجرد العقد، مع أن التقنين المدني الملغى قد نص على ذلك صراحة في المادتين ١٤٥/٩١ ، ١٤٦/٩٢ ، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة (٢٠٤) من التقنين المدني الحالى، حيث تقضى بأن الالتزام بنقل

(١) د. سمير تتاغو - السابق - ص ١٦ وما بعدها.

(٢) د. سليمان مرقس - السابق - ص ١٧، د. عبد الرازق حسن فرج - السابق - ص ١١.
وجدير بالذكر أن البيع في الفقه الإسلامي يعرف لغة بأنه: مبادلة مال بمال مطلقاً، واصطلاحاً: هو مبادلة مال بمال تمليكاً وتملكاً.

الملكية أو أى حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل، ويرى هذا الجانب من الفقه أن التعريف وإن كان قد أغفل هذه المادة إلا أنه رغم ذلك يتضمن نقل الملكية أو الحق العيني فعلاً ولا يقتصر دوره على إنشاء التزام بنقل الملكية^(١). ويضيف بعض الفقهاء أن انتقال الملكية ليس أثراً للبيع، بل هو أثر للالتزام بنقل الملكية الذي ينشئه البيع^(٢).

كما أخذ بعض الفقهاء على هذا التعريف عيباً آخر حاصله: أنه يعرف العقد بآثاره والتعريف بالأثر يعتبر معيباً من الناحية المنطقية، إذ يقضى المنطق بأن يكون تعريف العقد ببيان ماهيته المتمثلة في أركانه، وعناصره المكونة له، لا في آثاره، ولأن جوهر العقد ليس هو الأثر، وإنما هو - إذا أردنا الدقة في التعريف - يتمثل في التراضى^(٣).

وفي رأينا أن التعريف بالأثر وإن كان معيباً من الناحية المنطقية، إلا أنه من الناحية العملية والواقعية غير معيب، فالالتزام بنقل الملكية والالتزام بدفع الثمن اللذان يمثلان جوهر الآثار الناشئة

(١) د. سليمان مرقس - السابق - ص ١٧.

(٢) د. السنهورى - الوسيط - ص ٢٦، في الهامش وما بعدها.

(٣) د. إسماعيل غانم - الوجيز في عقد البيع ص ١٧ - طبعة ١٩٦٣م.

عن عقد البيع، لا يتصور وجودهما دون إرادة تعطيها شهادة الميلاد، ولولا الإرادة الموجودة فعلاً لما كان لتلك الآثار أى أثر.

وقد عبر المشرع عن هذا المعنى بقوله في المادة (٤١٨): "يلتزم به البائع"، وهو ما يفصح عن اتجاه إرادته نحو هذا الالتزام، ومن ثم فإنه يكون تعريفاً صحيحاً.

وغنى عن البيان أن عقد البيع يفى الشريعة الإسلامية يترتب عليه نقل ملكية المبيع بذاته، لأن نقل الملكية يعتبر من أحكام هذا العقد، حيث يعتبر هذا الحكم من قبيل ترتيب المسبب على السبب، وإذا كان العقد سبباً لنقل الملك، فإن الملك يعتبر مسبباً عنه.

وقد أشار المرحوم الدكتور السنهورى إلى هذه الميزة في التشريع الإسلامي، فقال بعد أن أشار إلى التطور الذي لحق بعقد البيع من ناحية نقله للملكية، حيث بدأ في القانون الرومانى التزاماً ينقل الحياة إلى المشتري إلا إذا اشترط المشتري على البائع أم ينقل له الملكية، وكانت الملكية في القانون الفرنسى القديم لا تنتقل إلا بالقبض إلى أن انتهت بما انتهى إليه القانون المدنى، فقال - رحمه الله -: "وَجَدِير بالذكر أن الفقه الإسلامى قد تعجل هذا التطور، وجعل البيع ناقلاً للملكية قبل ذلك بدهور طويلة^(١)، وبمقتضاه يصبح المشتري للعقار أو للمنقول مالكا للمبيع بمجرد العقد^(٢)".

(١) د. السنهورى - السابق - ص ٣٠.

(٢) راجع في هذا الكاسانى: بدائع لصنائع - ج ٥ - ص ٢٤٣.

المبحث الثاني

خصائص عقد البيع

ومن خلال تعريف المادة (٤١٨) مدنى للبيع، يتضح أن له خصائص منها: أنه عقد رضائى ، ملزم للجانبين، كما أنه من عقود المعاوضات، وهو عقد ناقل للملكية، ونوضح هذه الخصائص بالتفصيل المناسب على النحو التالى:

أولاً: عقد البيع عقد رضائى:

ومعنى أن عقد البيع عقد رضائى يتم بمجرد اتفاق الطرفين ولا يحتاج انعقاده إلى أى إجراء شكلي، أنه يستوى في انعقاده أن يكون قد تم كتابة أو مشافهة أو إشارة^(١)، أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالاته على المقصود، وكما يكون انعقاده صريحاً فإنه يجوز أن يكون ضمناً مادة (٩٠) مدنى، وإذا كان عقد البيع كذلك، فإنه لا يحتاج في انعقاده إلى شكل معين كما أنه ليس عقداً عينياً، فهو ينعقد دون حاجة إلى تسليم الشيء المبيع أو دفع الثمن، فكل ما يشترطه القانون فيما يتعلق بالشكل إذا صح هذا التعبير أنه يجب إثباته كتابة إذا زادت قيمة الالتزام عما حدده قانون الإثبات للإثبات بالكتابة، مادة (٦٠) من قانون الإثبات.

(١) د. سليمان مرقس - السابق - ص ١٨.

ويظل عقد البيع رضائياً ولو كان سائراً لوصية، فلو أن الوصية كانت مستورة في عقد بيع، فلا محل للنص على العقد، بأنه لم يستوف الأركان الشكلية للوصية، إذ العبرة بشكل العقد السائر لا المستور، كما أن الرضائية ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على خلافها^(١).

ما يستثنى من الرضائية في عقد البيع:

ولئن كان الأصل في عقد البيع أنه عقد رضائي، إلا أن هذا المبدأ يرد عليه بعض الاستثناءات، وهذه الاستثناءات تتمثل فيما يلي:

(١) بيع السفن البحرية:

وعلى استثناء بيع السفن البحرية من مبدأ الرضائية، حيث اعتبر المشرع بيعها عقداً شكلياً، أن المادة (٣) من قانون التجارة البحرى تنص على أن: بيع السفينة كلها أو بعضها اختياراً يلزم أن يكون بسند رسمي سواء حصل قبل السفر أو في أثناؤه، وإلا كان البيع لاغياً.

(٢) إذا كان الثمن على هيئة مرتب يدفعه بالمشتري للبائع مدى الحياة:

وفي هذه الحالة نصت المادة (٧٤٣) من التقنين المدنى المصري الحالى على أن البيع لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً.

(١) د. سليمان مرقس - السابق - ص ٢١.

(٣) التصرف الوارد على حق المؤلف:

وقد نصت المادة (٢/٣٧) من القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٤٥ على أن كل تصرف يرد على حق المؤلف في استغلال مصنفه لا ينعقد إلا بالكتابة، ومن ثم فإن التصرف في المصنف إذا كان بيعاً، فإنه يكون عقداً شكلياً بنص القانون^(١).

(٤) ورود البيع على عقار:

ومما يُعد استثناء من مبدأ الرضائية في عقد البيع ورود العقد على عقار بعد صدور قانون التسجيل في سنة ١٩٢٣ والذي ألغى بصدور قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦، الصادر في ١١/٨/١٩٤٦، والذي عمل به اعتباراً من أول يناير سنة ١٩٤٧، حيث نص هذا القانون في المادة (١٣) منه، على وجوب شهر التصرفات الناقلة للملكية بين الأحياء.

وقد أثار هذا النص خلافاً في الفقه حول مدى رضائية عقد البيع الوارد على العقار رغم ما ينص عليه هذا القانون، فذهب رأى في الفقه إلى أن عقد البيع أصبح بمقتضاه عقداً شكلياً لا يتم إلا بالكتابة، وأن التسجيل أصبح لازماً لنقل الملكية سواء بالنسبة للمتعاقدین أو بالنسبة للغير^(٢).

(١) د. السنهوري - الوسيط - ج٤ - ص ٥١ هامش (١).

(٢) د. عبد الرازق حسن فرج - السابق - ص ١٤، والمراجع المشار إليها في الهامش.

والرأى الراجح في الفقه: أن عقد البيع يعتبر عقداً رضائياً ولو كان وارداً على عقار، ذلك أن تحتيم تسجيله وفقاً لقانون الشهر العقاري يقتضى تدوينه في محرر، لأن التسجيل لا يرد على العمل القانوني في ذاته، بل على المحرر المثبت له، ولئن كان عقد البيع قد شابه أنه أصبح بعد صدور قانون التسجيل عقداً شكلياً، فإن ذلك الفهم ما لبث أن تبدد، وانعقد اجماع الفقه على أن ذلك القانون لم يغير من طبيعة البيع الرضائية، وأنه إنما اشترط التسجيل لنقل الملكية فحسب، وصار مسلماً أن بيع العقار ينعقد كبيع المنقول بمجرد التراضي، ولا تعتبر الكتابة إلا أداة لإثبات العقد تجعله صالحاً للتسجيل، فإذا لم يدون بيع العقار في محرر جاز إثباته عن طريق الإقرار أو اليمين أو غيرهما، وفقاً لقواعد الإثبات، وقام الحكم المثبت له مقام المحرر الذي يصدر من الطرفين من حيث التسجيل^(١).

والشريعة الإسلامية تعتبر عقد البيع عقداً رضائياً، يتم بالتراضي بين طرفيه دون حاجة إلى شكلية يضرب فيها، عملاً بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} ^(٢)، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما جاء عنه في

(١) د. سليمان مرقس - السابق - ص ٢٠.

(٢) سورة النساء - الآية ٢٩.

خطبة الوداع عن عمرو بن يثري: " لا يحل لأمرئ من ماله أخيه إلا ما طابت به نفسه"^(١).

وواضح من الآية الكريمة، والحديث الشريف أن الرضا وطيب نفس باذل المال من شروط صحة أكله وتملكه ولم يؤثر غير التراضي شرطاً للانعقاد في التشريع الإسلامي فيكون الحكم فيه على منواله.
ثانياً: عقد البيع من أعمال التصرف:

ولئن كان عقد البيع من العقود الرضائية التي تستلزم الرضا به، فإن الرضا لا يمكن صدوره إلا من شخص له أهلية التصرف سواء كان بائعاً أو مشترياً.

ثالثاً: البيع عقد ملزم للجانبين:

كما أن عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين البائع والمشتري بمعنى أنه يترتب التزامات متبادلة في ذمة كل واحد منهما فالبائع يلتزم بنقل الملكية والتسليم والضمان، والمشتري يلتزم بدفع الثمن^(٢).
ويترتب على ذلك أن يكون لكل من طرفي العقد أن يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم الطرف الآخر بالتنفيذ، أو بعرض الوفاء وفقاً لما تقضى به المادة (١/٢٤٦) مدني، كما أن لكل من طرفيه أن يطلب الفسخ عند عدم التنفيذ (م١٥٧) مدني.

(١) نيل الأوطار للشوكاني - ج ٨ - ص ١٧٢.

(٢) د. سليمان مرقس - السابق - ص ٢٢ وما بعدها.

رابعاً: عقد البيع عقد معاوضة:

ومن خصائص عقد البيع أنه عقد معاوضة يتم مقابل ثمن نقدي فيلزم الاتفاق على مقابل هو ثمن المبيع، وأن يكون هذا المقابل من النقود، كما أن المشتري ينقل ملكية المبيع في مقابل هذا الثمن النقدي الذي ارتضاه، فلو عدم الثمن يكون العقد عقد هبة، وتتحقق الصورة العملية لانعدام الثمن، إما بتحديد ثمن للمبيع دون أن يلتزم المشتري بأدائه فعلاً، وذلك بأن يعفى من ذلك باتفاق مستتر بين المتعاقدين وذلك ما يعرف بالثمن الصوري، وإما بتقدير ثمن للمبيع يبلغ من عدم التناسب مع قيمة المبيع حداً يجعله في حكم المعدوم، فلو كان كذلك لكان عقد هبة لا عقد بيع، ومن ثم يجب أن تسرى عليه الأحكام الموضوعية للهبة^(١)، ومنها ما تقضى به المادة (١/٤٨٨) مدني بقولها: "تكون الهبة بورقة رسمية إلا وقعت باطلا ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.

خامساً: عقد البيع ناقل للملكية:

ومن خصائص عقد البيع أنه ناقل للملكية سواء كانت الملكية واردة على شيء معين أو أى حق مالى آخر، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (٤١٨) مدني بقولها: "البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر... إلخ".

(١) د. خميس خضر - السابق - ص ١٦.

ومن ثم فإن البيع ينقل الملكية بذاته، وفور نشوئه إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم مادة (٢٠٤) مدنى، وقد نصت المادة (٩٣٢) مدنى، على أن الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول تنتقل بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف، وفقاً لما تقتضى به المادة (٢٠٤) مدنى.

ومع ذلك، فإن هناك حالات يتأخر فيها نقل الملكية حتى يتم إجراء آخر، كما في بيع المنقول المعين بالنوع، فإن نقل ملكيته يتراخى إلى وقت الإفراز، كذلك فإن بيع العقار وإن كانت الملكية فيه تتراخى إلى ما بعد التسجيل، إلا أن البائع يلتزم بمقتضى العقد أن يقوم بكل ما يلزم لتمكين المشتري من إجراء التسجيل^(١).

سادساً: الخصائص الأخرى لعقد البيع:

وبجانب تلك الخصائص الرئيسية في عقد البيع توجد بعض الخصائص الأخرى ينبغى أن نترك موضوع خصائص عقد البيع دون الإشارة إليها، خاصة وأن الفقه قد أشار إليها، وإن كان البعض قد أوردها تحت مسمى الخصائص الفرعية^(٢).

ومن تلك الخصائص: أن عقد البيع محدد القيمة، حيث يستطيع كل من طرفيه أن يعلم وقت انعقاد العقد مقدار التزامه إعطاء، ومقدار حقه أخذاً، ومع ذلك فإن العقد قد يكون في بعض صوره غير

(١) د. عبد الفتاح عبد الباقي - السابق - ص ١٥ وما بعدها.

(٢) د. خميس خضر - السابق - ص ١٧.

محدد القيمة، كما لو كان تحديد قيمة المبيع أو مقدار الثمن متوقفاً على حادث غير محقق كما في البيع في مقابل إيراد مرتب مدى الحياة^(١)، فإن مقدار الثمن يكون في هذه الحالة مرتبطاً بمدى حياة البائع، وذلك المقدار مما لا يمكن تقديره وقت العقد، ومن ثم يزيد الثمن بطول تلك الحياة وينقص بقصرها ولهذا كان تحديد الثمن أمراً محتملاً^(٢).

كما أن عقد البيع من عقود المساومة: حيث لا يتم البيع إلا بعد أخذ ورد ومناقشة عناصر الالتزام فيه بحرية واختيار، وهذا بخلاف عقود الاذعان التي يضع الموجب فيها شروطه مقدماً ودون أن يكون للمتعاقد الآخر مناقشتها، وما على القابل إلا أن يذعن لها دون مناقشة للموجب أو مفاوضة^(٣).

كما أن عقد البيع قد يكون مدنياً إذا كان موضوعه عملاً مدنياً، وقد يكون تجارياً إذا كان مضمونه عملاً تجارياً^(٤).

وخصائص عقد البيع في الشريعة الإسلامية تكاد تتطابق مع ما قرره فقه القانون بخصوصها، لولا أن عقد البيع في الشريعة الإسلامية ناقل للملكية بذاته، وقد أشرنا إلى ذلك، هذا بالإضافة إلى

(١) المرجع نفسه - ود. عبد الرازق حسن فرج - السابق - ص ١٦.

(٢) د. سليمان مرقس - السابق - ص ٢٤.

(٣) د. عبد الرازق حسن فرج - السابق - ص ١٧.

(٤) د. محمد كامل مرسى - عقد البيع - ص ٢١.

أن عقد البيع وإن كان عقد معاوضة في الشريعة الإسلامية، إلا أن المعاوضة فيه لا يتحتم أن تكون نقوداً كما نص القانون على ذلك، وقد نصت المادة (٥٠٧) من التقنين المدني العراقي التي تعرف البيع بما استقاه واضعوها من الشريعة الإسلامية بقولها: "البيع باعتبار المبيع أما أن يكون بيع العين بالنقد، وهو البيع المطلق أو بيع النقد وهو الصرف أو بيع العين بالعين وهو المقايضة".

الفصل الثانى

تميز عقد البيع عما يختلط به

من العقود

الفصل الثانى

تميز عقد البيع عما يختلط به من العقود الأخرى

رأينا أن عقد البيع يتميز عن غيره من العقود بأنه ناقل للملكية أو منشئ لالتزام بنقلها، وهو بهذا يختلف عن الإيجار والمقاوله والوكالة، كما أن نقل الملكية فيه يتم بمقابل، ومن ثم فإنه بهذا يختلف عن الهبة والمقايضة والوصية، ومع هذا التمايز الواضح لعقد البيع عن غيره من العقود، فإنه قد يلتبس بالوصية ومن ثم تحسن الإشارة إلى تلك الفوارق، ونخصص لتمييز كل عقد منها عن البيع مبحثاً:

المبحث الأول

التمييز بين البيع والإيجار

إذا كان المقصود من البيع نقل الملكية أو أى حق مالى آخر، فإن عقد الإيجار يختلف عن ذلك، حيث عرفته المادة (٥٥٨) مدنى بقولها: "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم"، وبالتالي يكون المقصود منه هو تمكين المستأجر من الانتفاع بالشئ المؤجر فذلك هو مضمون الالتزام الجوهرى الذي ينشئه الإيجار، وإذا كان البيع ينقل الملكية بحيث يخلف المشتري البائع فيها فإن المستأجر لا يكون خلفاً للمؤجر، وإنما هو دائن له بما يمكن من الانتفاع بالعين المستأجرة فآثر البيع حاسم، وآثر الإيجار مؤقت^(١)، ورغم هذا الوضوح في تمييز البيع عن الإيجار إلا أن التطبيق العملى قد كشف عن صعوبات في بعض الأحوال يكون التمييز فيها بين البيع والإيجار أمراً متعذراً، مما جعل الفقه والقضاء يتردد فيها بين اعتبارها بيعاً وبين اعتبارها إيجاراً. وبداية فإنه لا وجه للالتباس بين البيع والإيجار إذا كان المعقود عليه مالاً مادياً، أى حق ملكية شيء مادي، وذلك لوضوح الفرق بين اتجاه قصد المتعاقدين إلى نقل الملكية، أو اتجاهه فقط إلى مجرد الزام

(١) د. عبد الرازق حسن فرج - السابق - ص ١٩.

المالك بتمكين العاقد الآخر من الانتفاع بالشيء مدة معينة مع بقاء ملكيتها لصاحبها^(١).

غير أن الأمر يدق، إذا كان المعقود عليه ليس مالاً مادياً بل مالاً معنوياً، وخاصة إذا كان حقاً شخصياً يخول المنفعة كالحق في أخذ ثمار العين أو حاصلاتها مدة معينة، وحالتئذ يختلط البيع بالإيجار ويصبح تكيف العقد أمراً غير هين، مع أنه لا مفر منه لتكيف العقد في نزاع يفرض نفسه، ولا بد من تكيفه لاستجلاء طبيعته وهل هو عقد بيع أم عقد إيجار حتى يتسنى تطبيق الأحكام عليه^(٢).

فإذا انتهى التكيف إلى أن العقد بيع، كان قابلاً للإبطال لعدم ملكية البائع له وينتهي حق المشتري بانتهاء المدة المتفق عليها، وكان للبائع حق امتياز على المبيع، وإن كانت الثانية كان العقد غير قابل للإبطال، بسبب عدم ملكية المؤجر للمعقود عليه، وكان قابلاً للتجديد فقط، وليس امتياز البائع إذا كان المعقود عليه عقاراً.

ومعلوم أن امتياز البائع يختلف عن امتياز المؤجر في مداه وفي أحكامه^(٣).

(١) د. سليمان مرقس - السابق - ص ٢٧.

(٢) المرجع والمكان السابقان، د. عبد الودود يحيى - ص ٣.

(٣) راجع: محمد كامل مرسى - التأمينات الشخصية والعينية - ص ٢٣٤، ص ٣٦٠ - طبعة

١٩٤٩م.

ويمكن إرجاع حالات الاختلاط في التكيف بين البيع والإيجار إلى حالتين:

الحالة الأولى: حالة النزول للغير عما ينتجه الشيء من حاصلات وثمار في مقابل ثمن نقدي:

فلو أن شخصاً أعطى آخر الحق في جنى ثمار عين معينة أو في أخذ حاصلاتها مدة محددة في مقابل جعل ثابت، هل يعتبر هذا العقد بيعاً أم إيجاراً؟

لقد اختلفت آراء الفقه والقضاء في ذلك، ويمكن إبراز تلك الآراء كما يلي:

(١) التفرقة بين أخذ الثمار، وأخذ الحاصلات:

وأصحاب هذا الرأي يرون وجوب التفرقة بين العقد الذي يعطى الحق في أخذ الثمار والعقد الذي يخول أخذ الحاصلات، حيث يعتبر الأول إيجاراً والثاني بيعاً^(١).

(١) د. عبد المنعم البدر أوري - البيع - ص ٤٦ طبعة ١٩٦٣م، وانظر: نقض مدني مصري في ١٩٥١/١٢/٦ مجموعة أحكام النقض ٣ - ١٦١ - ١٣، وقد جاء فيه: "أنه إذا كان الطاعن قد تعاقد مع وزارة المالية المطعون عليها على أن يقوم باستغلال النطرون الجاف بمستنتقات منطقتين رسا موادهما عليه مقابل ثمن معين، وعلى أن يدفع للمطعون عليها علاوة على ذلك اناوة لواقع كذا جنيهاً لكل طن يستخرج زياة على ١٥٠٠ طن من المنطقة الأولى، و ١٠٠٠ طن من المنطقة الثانية، فهذا العقد موضوعه محصول طبيعي غير متجدد يكون جزءاً من المستنتقات ولا بد من نفاذه يوماً وهو ليس ثمناً أو ريعاً للمستنتقات المذكورة، ومهما ورد في هذا العقد من ألفاظ المؤجر والإيجار والمستأجر فإنه عقد بيع للنطرون، لا عقد إيجار للمستنتقات، وهذا الاتجاه هو اتجاه الفقه والقضاء الفرنسي، راجع: بلانيول وريير ودي لاموراند بيير - ج ٢ - ص ٦٥٦.

وللتذكرة فإن الحاصلات أو منتجات الشيء هي ما ينتجه الشيء في مواعيد غير دورية ولا منتظمة، وينتقص من أصله كأحجار المحجر أو أشجار الغابة، ومن ثم يعتبر العقد بيعاً لمنقول بحسب المال، هو حاصلات الشيء المعقود عليه، أما الثمار فهي ما ينتجه الشيء في مواعيد دورية متجددة دون أن تنقص من الأصل شيئاً، وبالتالي يكون العقد الوارد عليها إيجاراً.

وحجة أصحاب هذا الرأي أن الإيجار يقصد به تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر، وأن جوهر هذا العقد هو أن يرد المستأجر الشيء بعد انتهاء عقد الإيجار بالحالة التي كان عليها، وفقاً لما تقضى به اامادة (٥٩١) مدنى، في حين أن الحاصلات تنقص من الأرض، فهي جزء منها ومآلها للزوال يوماً ما. ومن ثم كانت العقود التي تتعلق بالحاصلات لا تعتبر إيجاراً لأن الشيء قد نقص على نحو لا يمكن معه رده بالحالة التي كان عليها^(١).

ويؤخذ على هذا التوجيه أنه لا مانع في العقد الوارد على الثمار أن تنتج نية المالك إلى بيع الثمار ذاتها لا إلى مجرد الالتزام بتمليك الطرف الآخر من أخذ غلة العين، كما أن العقد الوارد على الحاصلات يمكن اعتباره إيجاراً إذ كان أخذ هذه الحاصلات هو الطريق الطبيعي لاستغلال العين^(٢).

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - السابق - فقرة ٥٩.

(٢) د. سليمان مرقس - المرجع نفسه - ص ٢٩.

(٢) التفرق بين التنازل عن الثمار ناضجة أو غير ناضجة:

وذهب رأى آخر إلى أن المعول عليه في اعتبار العقد بيعاً أو إيجاراً هو طبيعة نزول الملك عن الثمار، فإذا كان تنازله عنها ناضجة ومعدة للنقل فيكون العقد بيعاً، وأن كان نزوله عنها مقترباً بالتزام المتنازل إليه بالعمل على إنمائها، وإنضاجها وحصرها فيكون العقد إيجاراً^(١).

ولكن يؤخذ على هذا الرأي، أنه لا مانع في عقد البيع من أن يلتزم المشتري بالقيام ببعض الأعمال اللازمة لإنتاج المبيع^(٢).

(٣) النظر إلى طبيعة الآثار الناشئة عن العقد:

وذهب آخرون إلى أن المعمول عليه في اعتبار مثل هذا العقد بيعاً أو إيجاراً طبيعة الآثار التي تترتب عليه، فإن كان من شأنه أن ينقل ملكية حق ثابت من قبل في ذمة المتصرف، كان بيعاً، وإن اقتصر على إنشاء التزام في ذمة المتصرف بتمكين المتصرف إليه من اخذ الثمار أو الحاصلات فهو إيجار، لكن يؤخذ على هذا الاتجاه أن الآثار التي تترتب على عقد ما، ليست سوى نتيجة لاتجاه إرادة العاقدین إليها، وأن المسألة كلها تنحصر في معرفة ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين^(٣).

(١) فاهل: في تعليق له على حكم النقض الفرنسي - في ١٣/١٢/١٩٠٩م - سيرى ١٩١٢م

- ١ - ٤١٣.

(٢) د. السنهوري - الوسيط - ج ٤ - ص ٢٨.

(٣) د. سليمان مرقس - السابق - ص ٢٩.

(٤) الغيرة بقصد المتعاقدين:

ولهذا الاختلاف فقد ذهب رأى قوى إلى أن العبرة بقصد العاقدين وأن الآثار التي لا يكون ثمة شك في اتجاه قصدهما إليها يمكن أن يستدل بها على تكييف العقد للاستعانة بهذا التكييف على تنظيم الآثار التي لم يثبت اتجاه قصدهما إليها، وبعبارة أخرى فإن ظروف التعاقد وأحكامه الواضحة يمكن اعتبارها قرائن قضائية مؤقتة دالة على حقيقة التكييف الذي اتجهت إليه إرادة المتعاقدين، بمعنى أنها ترجح أحد التكييفين على الآخر إلى أن يثبت العكس^(١).

فمثلاً يعتبر ورود العقد على الحق في أخذ الحاصلات - وهي غير متجددة - قرينة على أن العقد عقد بيع، ما لم يثبت من ظرف آخر، أن العاقدين اتجهت إرادتهما إلى الإيجار وآثاره، وبالعكس من ذلك يعتبر ورود العقد على العقد في أخذ ثمار الأرض كلها وهي متجددة - قرينة على أنه قصد به الإيجار لا البيع، فإذا كان محل العقد نوعاً معيناً من الثمار فقط كان الراجح أن العقد بيع إلا إذا كان المتصرف إليه قد تعهد بإنماء هذه الثمار وإنضاجها على نفقته، فإن ذلك يرجح الإيجار على البيع^(٢).

والواقع - كما يقول أستاذنا الدكتور عبد الرزاق حسن فرج:

أن المعايير السابقة جميعاً ما هي إلا معايير تقريبية، وليست مؤكدة

(١) د. السنهوري - الوسيط - ج٤ - ص٣٨.

(٢) د. سليمان مرقس - السابق - ص٣٠.

لعدم وجود قاعدة يمكن إعمالها في هذا الشأن ، ولهذا فإنه يتعين على حسب الظروف والملابسات، وللقاضى أن يكيف العقد مستهدياً في ذلك بما تتجه إليه إرادة المتعاقدين، وقصدهما الحقيقى دون اعتبار للوصف الذي يضيفانه على العقد، وللقاضى كذلك أن يستهدى بالمعايير السابقة وما تتضمنه من قرائن تعينه على ترجيح تكييف على آخر^(١).

الحالة الثانية: حالة البيع الإيجارى:

والبيع الإيجارى هو البيع الذي يقوم فيه الاتفاق بين طرفيه على أن يقوم أحدهما بتسليم شيء معين للآخر في مقابل قيام الأخير بدفع مبلغ دورى متجدد لمدة معينة ويتفقان على اعتبار هذا المبلغ الدورى أجرة في نظير الانتفاع بالشيء، فإذا ما قام المتصرف إليه بالوفاء بجميع الأقساط المتفق عليها، انتقلت إليه الملكية، وانقلب العقد بيعاً، واعتبرت الأجرة المدفوعة أقساطاً للثمن، أما إذا تخلف عن الوفاء بأى قسط من الأقساط التى حل ميعاد استحقاقها، كان عليه أن يرد الشيء إلى مالكه مع حق هذا المالك في الاحتفاظ بما سبق، دفعه من أقساط بوصف كونها أجرة ثم قبضها نظير الانتفاع بالشيء طوال المدة التى ظل فيها في يد المنتفع.

ومثال ذلك: أن يتفق تاجر أدوات كهربائية مثلاً على أن يؤجر لعملية ثلاثة أشهر لمدة معينة أجرة شهرية قدرها مائة جنيهاً، وعلى أنه إذا

(١) د. عبد الرزاق حسن فرج - السابق - ص ٢٣.

وفى المستأجر التزامه كاملة تملك الثلاجة في نهاية المدة دون أن يدفع شيئاً آخر.

هذا الاتفاق يشبه البيع في أنه يؤدي إلى نقل ملكية الثلاجة في مقابل ثمن يدفع على هيئة أقساط شهرية، كما أنه يشبه الإيجار في أنه لا يترتب عليه فور انعقاده تملك بل مجرد تمكين من الانتفاع، وفي أن فسخ العقد لإخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته كلها أو بعضها لا يترتب عليه وجوب إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، بل يحتفظ كل من الطرفين التي عادت عليه في الماضي من تنفيذ العقد^(١).

ومن هذا يتضح أن المتعاقدين قد أرادا أن يكون هذا العقد إيجاراً وبيعاً، فيكون إيجاراً حتى يتم الوفاء بالثمن كاملاً، ويكون بيعاً حين يتم الوفاء به.

وتبدو أهمية تكيف العقد بأنه إيجار ينقلب إلى بيع في حماية البائع، إذ يظل بمثابة مؤجر يحتفظ بملكية الشيء ويستطيع بالتالي استرداده إذا ما توقف من تسليم الشيء عن الوفاء بالأقساط أو أفلس قبل قيامه بالوفاء بها، مع عدم التزامه برد ما تسلمه منها على أساس أنه أجره، أما لو اعتبر العقد بيعاً منذ البداية فإنه يترتب على فسخه التزام المشتري برد المبيع، والتزام البائع برد ما تسلمه من أقساط، هذا فضلاً عن أن تكيف العقد على أنه إيجار يجعل يد المستأجر على الشيء يد أمانة، فإذا تصرف فيه للغير، عُد مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة^(٢).

(١) د. سليمان مرقس - السابق - ص ٣١.

(٢) د. جميل الشرقاوى - ص ٢٧، د. عبد الفتاح عبد الباقي - ص ٢٤.

وقد كان تكييف موضوع البيع الإيجارى محل خلاف في الفقه والقضاء قبل صدور التقنين المدنى المصري الحالى، فذهب رأى إلى أن العقد يعتبر إيجاراً وبيعاً في ذات الوقت، فهو إيجار معلق على شرط فاسخ، وبيع معلق على شرط واقف، والشرط في الحالتين هو الوفاء بجميع الأقساط المتفق عليها، فإذا تحقق الشرط الفاسخ وذلك بتمام الأقساط المتفق عليها، انفسخ عقد الإيجار، وتحقق الشرط الواقف الذي علق عليه البيع فيوجد العقد وينتج آثاره مستنداً إلى وقت الاتفاق، ويعتبر من تسلم الشيء كأنه قد اشتراه منذ البداية^(١).

أما إذا تخلف الشرط بعدم تمام الوفاء بالأقساط، فإن الإيجار يتأكد ويعتبر البيع كأن لم يكن، ويحتفظ المالك بما قبض من مبالغ باعتبارها أجرة في نظير الانتفاع بالشيء^(٢).

وقد أخذ على هذا الرأى بأن تكييف العقد على أنه بيع وإيجار في آن واحد معاً، مما يتنافى مع طبيعة التكيف إذا المفروض أن يكون واحداً لا متعدداً، فهو إما أن يكون بيعاً أو إيجاراً فقط، لا بد وأن يكون أحدهما^(٣).

والقول بهذا التكيف من شأنه أن يؤدي إلى أن البيع قد تم بدون ثمن، فالأقساط التى دفعت كانت إيجاراً في المدة التى يسرى

(١) د. عبد الفتاح عبد الباقي - ص ٢٦.

(٢) المرجع نفسه.

(٣) د. إسماعيل غانم - ص ٣٧.

فيها العقد، وذلك مقابل الانتفاع بالشيء فإذا اقلب العقد إلى بيع فمعنى ذلك أنه قد تم بلا ثمن، ومعنى ذلك أنه يعتبر باطلاً، لفقدانه ركناً أساسياً وهو الثمن^(١).

وذهب رأى آخر إلى أن العقد يعتبر بيعاً علق فيه نقل الملكية على شرط واقف، هو الوفاء وهذا هو الوفاء بالأقساط جميعها، وهذا هو ما يتفق مع قصد المتعاقدين، حيث قصدا البيع منذ البداية ولم يكن لوصف العقد بأنه إيجار من أثر سوى أنه وسيلة للحصول على الثمن، واستيفاء الأقساط كاملة، وهذا ما قرره المشرع في التقنين المدني المصري الحالي في المادة (٤٣٠) والتي تنص على أنه:

(١) إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله، ولو تم تسليم المبيع.

(٢) فإذا كان الثمن يدفع أقساطاً، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقى البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط، ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقاً للفقرة الثانية من المادة (٢٢٤).

(٣) وإذا وفيت الأقساط جميعاً، فإن انتقل الملكية إلى المشتري يعتبر مستنداً إلى وقت البيع.

(١) في هذا المعنى: د. عبد الرازق حسن فرج - ص ٢٥.

(٤) وتسرى أحكام الفقرات السابقة، ولو سمي المتعاقدان البيع إجباراً. وبهذا النص حسم المشرع الخلاف في تكييف هذا العقد، حيث اعتبره بيعاً بالتقسيط، علق فيه انتقال الملكية على الوفاء بكامل أقساط الثمن، وبحيث يستند انتقال الملكية إلى المشتري عند الوفاء بكامل الثمن إلى وقت البيع^(١).

ومن هذا النص يتضح أن المشرع قد أوضح في الفقرة الأولى منه: أن انتقال الملكية في هذا البيع يكون موقوفاً على الوفاء بالثمن كله، ولكن التزامات البائع بتسليم المبيع، وضمنان الاستحقاق وضمنان العيوب الخفية، وكذلك التزامات المشتري بتسليم المبيع وبتحمل نفقات العقد كلها تكون منجزة، كما بين في الفقرة الثانية حكم تخلف المشتري عن القيام بدفع جميع الأقساط واشتراط البائع مقدماً أن يستبقى جزءاً معيناً من الأقساط المدفوعة على سبيل التعويض عن فسخ البيع، وأنه يجوز للقاضي تخفيض هذا التعويض، طبقاً لأحكام المادة (٢٢٤) مدنى، وأن هذا التعويض يعتبر بمثابة شرط جزائي، يستحقه البائع حتى ولو لم يثبت له حصول ضرر من الفسخ^(٢).

وفي النهاية فإن تكييف العقد من خلال مقصد المتعاقدين هو ما يتفق مع قواعد التشريع الإسلامي التي تقرر أن العبرة في العقود بالمقصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

(١) د. سليمان مرقس - ص ٣١.

(٢) د. عبد الرازق حسن فرج - ص ٢٧.

المبحث الثاني

البيع والمقاول

عرف المشرع عقد المقاول من خلال ما نصت عليه المادة (٦٤٦) من التقنين المدني بقولها: "المقاول عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يضع شيئاً أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر".

ووفقاً لما تنص عليه المادة (٦٤٧) مدني، فإنه يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله، كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً.

فعقد المقاول وإن كان بحسب الأصل عقد يرد على العمل إلا أن ما قضت به المادة (٦٤٧) مدني، من جواز تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة التي يستخدمها فيه، قد أوجد اشتباهاً بينه وبين عقد البيع، فمن السهل أن يعتبر المقاول بائعاً للمواد التي يستخدمها في العمل^(١).

وقد ذهببت أغلبية الفقه والقضاء في هذا الشأن إلى اعتبار الأصل في الحالات التي يتعهد فيها المقاول بتقديم مادة العمل أن العقد بيع، إلا إذا كانت قيمة المواد أو المهمات المستعملة ثانوية بالنسبة إلى

(١) د. سليمان مرقس - ص ٣٢.

عمل المقاول، فالترزى الذي يحيك لعميله ثوباً يتعهد دائماً بتوريد المواد الأولية البسيطة، كالخيط والأشرطة وغيرها، كما يتعهد أحياناً بتقديم قماش الثوب ذاته، ففي الحالة الأولى يعتبر العقد مقاوله، لأن محله الرئيسى عمل الترزى وهو حياكة الثوب، ولأن ما يقدمه من الخيط وسائر المواد الأولية البسيطة ليس إلا أمراً ثانوياً إلى جانب تفصيل الثوب وحياكته، أما في الحالة الثانية فإن قيمة الأقمشة والمهمات التى يتعهد الترزى بتوريدها تبدو أهم من قيمة العمل المتعهد به.

ومن ثم يصح اعتبار العقد بيعاً لشيء مستقبل، وكذلك إذا تعهد المقاول بان يبنى بأدوات من عنده بناء على أرض مملوكة لرب العمل، فإن العقد يعتبر مقاوله، لأن المهمات تعتبر ثانوية بالنسبة إلى الأرض، أما إذا تعهد بتقديم بناء بقيمة بأدوات من عنده، وعلى أرض يقدمها هو، فإن العقد يغلب عليه وصف البيع^(١).

(١) د. توفيق فرج - عقد البيع والمقايضة في القانون اللبنانى - ص ٥٤ بيروت سنة ١٩٦٨م.

المبحث الثالث

البيع والوكالة

والوكالة وفقاً لتعريف المادة (٦٩٩) من التقنين المدني: "عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل".
ولئن كانت الوكالة محلها التزام الوكيل بالقيام بعمل، فإن البيع يتمثل محله في نقل ملكية شيء أو أى حق مالى في مقابل ثمن نقدي.

ورغم هذا الوضوح في التفرقة البيع والوكالة، إلا أن تلك التفرقة قد تكون عزيزة المنال في بعض الصور، وذلك كما في حالة عقد التوزيع، حيث يتعهد شخص بمقتضاه أن يسلم شخصاً آخر كمية معينة من سلعة لبيعها في مقابل مبلغ معين يؤديه لمنتج السلعة، على أن يلتزم برد ما تبقى لديه دون بيع، فهل يعتبر من يقوم بالتوزيع وكيلًا، أم أن العقد يعتبر بيعاً معلقاً على شرط واقف أو فاسخ، هو عدم التمكن من بيع السلعة خلال مدة محددة.

وتبدو أهمية التفرقة بين وصف العقد بأنه وكالة أو بيع في أن الوكالة تعبر من عقود الأمانة، فالوكيل إذا بدد الأشياء التي عهد إليه بها، فإنه يعاقب بعقوبة خيانة المانة، في حين أن البيع ليس من عقود

الأمانة، ولا يعاقب المشتري إذا ما تصرف فيما سلم إليه باعتباره مبيعاً إليه^(١).

وحل مشكلة تكيف العقد في هذه الحالة يتوقف على معرفة القصد الحقيقي للمتعاقدين فإذا اتجهت إرادتها إلى نقل الملكية كان العقد بيعاً، وإلا فهو وكالة، فالاتفاق على أن يقوم من تسلم الشيء ببيعه على أن يأخذ لنفسه نسبة معينة من الثمن الذي يبيع به، ويرجح أن يكون العقد وكالة، وكذلك إذا حدد صاحب الشيء السعر الذي يجب على من تسلمه أن يبيعه به، ويستفاد ذلك أيضاً من اعتراف الشخص الذي تسلم الشيء لبيعه بالوكالة^(٢).

أما إذا اتفق على أن يدفع من تسلم الشيء مبلغاً محدداً لمالكه يقطع النظر عن الثمن الذي يتمكن من بيعه به، مع الاحتفاظ بحقه في رد الشيء دون دفع الثمن المتفق عليه إذا لم يتمكن من بيعه، فإن ذلك يرجح أن يكون العقد بيعاً مقترناً بشرط فاسخ، هو عدم تمكن المشتري من بيع الشيء إلى الغير^(٣).

(١) د. سليمان مرقس - ص ٣٣.

(٢) د. إسماعيل غانم - ص ٣٧.

(٣) د. خميس خضر - ص ٢٩.

المبحث الرابع

البيع والهبة

يتفق عقد البيع مع عقد الهبة في أن كلا منهما يرد على نقل الملكية بين الأحياء، والهبة وفقاً لما عرفتھا المادة (١/٤٨٦) مدنى: "عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض".

ومن خلال هذا التعريف يتضح الفرق بين البيع وبين الهبة، فلئن كان نقل الملك في الهبة يتم للموهوب له دون عوض، وعلى نحو يقصد به التبرع، فإن البيع يتم نقل الملك فيه بعوض، وهو من عقود المعاوضات، فالهبة تقترن بنية التبرع من الواهب، وقبول من الموهوب له، وهذا هو العنصر النفسي فيها، أما العنصر المادي فهو نقل المال دون مقابل^(١).

ولكن الهبة قد تكون بمقابل، وهذا ما عبرت عنه المادة (٢/٤٨٦) بقولها: "يجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين"، فتكون الهبة في تلك الحالة بعوض يجب على الموهوب له أن يؤديه، وفي هذه الحالة فإنها تشبه البيع من ناحية أن المتصرف إليه يلتزم بهذا العوض ويؤديه كما يلتزم المشتري بالثمن، ويزداد التشابه بين البيع والهبة كلما اقتربت قيمة العوض من ثمن المثل.

(١) د. عبد الرازق حسن فرح - ص ٢٩، د. محمد على إمام - ص ٢٣.

وفي الحالات التي تشبه فيها الهبة بالبيع يثور التساؤل عما إذا كان العقد بيعاً أم هبة؟

يرى جانب من الفقه أن العقد يكون هبة في حال توافر شرطين: أولهما: أن يكون العرض أقل من المال الموهوب.

ثانيهما: أن تتوافر نية التبرع.

ولا يتنافى تكيف العقد على أنه هبة بتوافر هذين الشرطين مع وجود العوض، لأن المعول عليه هو نية التبرع، ولا يسوغ مع هذا الاعتبار أن يقال بأن هذا التصرف عقد بيع في حدود قيمة العوض وهبة فيما زاد عنه، وإذا كان العوض مساوياً لقيمة المال الموهوب أو مقارباً له فإن العقد يعتبر بيعاً لا هبة ولا يستقيم القول بتوافر نية التبرع في هذه الحالة^(١).

ويرى بعض الفقهاء أن المعول عليه في اعتبار العقد هبة هو نية التبرع حتى ولو كانت الهبة بمقابل نقدي كبير، وإذا لم توجد نية التبرع كان العقد بيعاً ولو كان المقابل النقدي أقل قيمة من الشيء المباع^(٢).

وإذا كانت الهبة مستترة في صورة عقد آخر، كعقد البيع فإنها تكون صحيحة وقد أعفاها المشرع من شرط الرسمية، ويخضع عقد الهبة المستترة من حيث الموضوع لأحكام الهبة، ومن ثم يشترط في

(١) د. خميس خضر - ص ٣٠، د. منصور مصطفى منصور - ص ٢٦.

(٢) د. سمير السيد تناغو - عقد البيع - ص ٢٢.

الهبة في تلك الحالة أن يكون للعقد مظهر للبيع بالفعل، كأن يذكر الثمن في البيع الظاهر، أما إذا حدد الثمن في العقد وذكر أن المشتري قد أبرأ المشتري فيه أو هبة له، فإن العقد لا يكون بيعاً، بل يكون هبة صريحة، وتكون باطلة إلى لم تفرغ في الشكل المطلوب^(١).

(١) د. خميس خضر - ص ٣٠ ، د. عبد الرازق حسن فرج - ص ٣٠ ، د. سليمان مرقس - ص ٣٨ .

المبحث الخامس

البيع والمقايضة

المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال ليس من النقود (م ٤٨٢) مدنى، ومن خلال هذا التعريف يتضح أن المقايضة تتميز عن البيع في أن المقابل فيها ليس من النقود.

والاختلاط الذي يقع بين البيع والمقايضة قد يقع في بداية العقد، كما لو جعل أحد المتعاقدين للآخر أن يختار بين بدلين للشيء الذي التزم بنقل ملكيته إليه، وكان أحد الدائنين مبلغاً من المال، وكان البديل الآخر مالا غير نقدي كمنزل أو سيارة أو غير ذلك، ففي هذا المثال لا يمكن أن نعرف طبيعة العقد عند إبرامه ولكن طبيعته تتحدد بشكل واضح عندما يختار من له الحق في الخيار أحد البدلين النقدي أو غير النقدي.

ولكن قد يلتبس البيع بالمقايضة ابتداءً وانتهاءً، إذا كان أحد البدلين مكوناً من عنصرين: أحدهما نقدي، والآخر غير نقدي كأن يكون أحد العوضين سيارة جديدة والعوض الآخر سيارة قديمة بالإضافة إلى مبلغ نقدي.

ولتحديد طبيعة هذا العقد يؤخذ بالعنصر الغالب في العوض المكون من عنصرين، فإذا كان المبلغ النقدي هو العنصر الغالب،

كان العقد بيعاً، أما إذا كانت السيارة القديمة هي العنصر الغالب فإن العقد يكون مقايضة^(١).

ولا يكون هناك لبس في طبيعة العقد إذا كان أحد العوضين سبيكة ذهبية أو ورقة مالية، فإن هذا العقد يعتبر مقايضة رغم سهولة تحويل المقابل، وهو السبيكة الذهبية أو الورقة المالية إلى مبلغ نقدي، كما لو بعثك سيارتي بسبيكة ذهبية وخمس سندات، وكذلك لا يكون هناك لبس في طبيعة العقد إذا كان المقابل فيه إيراداً مرتباً مدى الحياة، فإن العقد يكون بيعاً وإن كان الثمن فيه محدداً بطريقة احتمالية^(٢)، وما دام هذا الإيراد من النقود، هذا ومما تجدر ملاحظته أن الثمن في هذه الحالة لا يتمثل في الأقساط التي يقوم المشتري بدفعها، بل في الحق في الإيراد المرتب للبائع، مما يدعو إلى القول بأن العقد في حقيقته يعتبر مقايضة لا بيعاً، إلا أن الرأي في الفقه وفي القضاء قد استقر على اعتبار هذا العقد بيعاً^(٣).

ومما يجب ذكره أن المقايضة تعتبر صورة من صور البيع في الشريعة الإسلامية وقد سبق الإشارة إلى ذلك.

(١) بلانيول وريبير، وهامل - ج ١٠، فقرة ٤٠٣، وراجع حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم ٩٧ س ٤٠٤ مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض - ج ٢ - ص ٩٨٦.

(٢) د. السنهوري - ج ٤ - ص ٣٦٤.

(٣) د. عبد الرازق حسن فرج - المكان نفسه.

المبحث السادس

البيع والوصية

والوصية كما جاء في المادة الأولى من قانون الوصية التي تكلفت بتعريفها: "تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت، والوصية كما يبدو من تعريفها تعتبر تصرفاً بالإدارة المنفردة، وليست عقداً كالبيع الذي لابد فيه من توافق إرادتين هما: إرادة البائع وإرادة المشتري، كما أن الوصية لا تنقل الملكية في الحال، وإنما تنقلها بعد وفاة الموصى مصرّاً على وصيته، فقبل الوفاة يحق للموصى أن يرجع في وصيته، ومع أن عقد البيع يجوز أن يقع معلقاً على شرط أو مضافاً إلى أجل، إلا أن هذا الأجل لا يصح أن يكون هو وفاة البائع، ومعلوم بدهاءة أن نقل الحق في الوصية يتم بدون مقابل أما نقل الملك في عقد البيع فإنه يتم بمقابل نقدي.

ورغم وضوح التفرقة بين البيع والوصية، إلا أن الخلط بينهما قد يقع، ووقوعه قد يتم قصداً للتحايل على بعض قواعد القانون الآمرة وإعمالاً لإرادة الموصى، وذلك كما في القاعدة التي تقضى بعدم جواز الوصية قيماً زاد على الثلث، حيث يقصد الموصى مخالفة هذه القاعدة، فيجعل تصرفه في صورة بيع، وليس في صورة وصية، فيكون البيع حالئذ بيعاً صورياً يوارى خلفه وصية حقيقية، وبالتالي يكون لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالتصرف الحقيقي وأن يثبت صورية البيع

الذي أضر به، ويمكن استخلاص حقيقة التصرف مما يحيط به من ظروف وملابسات وبما يتضمنه م شروط.

ومن القرائن التي يمكن أن تساعد في تكييف العقد وأخذ بها القضاء في اعتبار التصرف وصية ليس بيعاً، قلة الثمن المذكور في العقد، أو إبراء المشتري من الثمن، أو فقر المشتري، كما لو كان البيع لطفل لا يملك شيئاً يدفعه كثرمن، ويمكن اعتبار التصرف وصية لا بيعاً، إذا احتفظ البائع لنفسه بحق الانتفاع بالشيء المبيع وحيازته إلى حين وفاته، أو منع المشتري من التصرف في البيع طوال حياة البائع^(١).

وقد كانت المحاكم مترددة في الأخذ بشرط دون آخر من هذه الشروط أو الاكتفاء بشرط منها دون آخر، حتى نثبت نية الإيضاء إلى أن حسم المشرع في التقنين المدني المصري هذا الأمر حين نص في المادة (٩١٧) منه على أنه: "إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً لما بعد الموت، وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقد دليل يخالف ذلك".

وقد أنشأ هذا النص قرينة قانونية تدل على توافر نية الإيضاء ليستطيع من يدعى أن التصرف وصية أن يعفى من عبء الإثبات، ولكن هذه القرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها، ومن ثم فإن لكل ذي

(١) د. إسماعيل غانم - ص ٥٥.

مصلحة أن يثبت أن التصرف بيع وليس وصية، فيثبت وجود الثمن، وقصد انتقال الملكية حال حياة المتصرف^(١).

ولعل ما يبرر مسلك القانون الجديد وميله إلى ترجيح جانب الوصية على جانب البيع والهبة من خلال تقريره لتلك القرينة، مما يؤدي إلى تقييد التصرف، أن باعث القضاء على التساهل في تفسير التصرف على أنه بيع أو هبة قد إنعدم، فقد كان القضاء يرجح جانب البيع أو الهبة على جانب الوصية لما لمسه في القانون السابق من تضيق عن الأيضاء للوارث، فكان يعالج بمسلكه هذا عيباً في ذلك القانون، وليصح وصايا لها ما يبررها في ظروف الأسرة، مثل أن تتم تحت ستار أنها ببوع أو هبات منجزة، أما وقد عدل المشرع المصري من أحكام القانون وأجاز الوصية للوارث فيما لا يزيد على ثلث التركة، فلم يعد هناك مقتض لتسمية التصرفات بغير اسمائها الحقيقية، وما دامت الوصية السافرة للوارث جائزة فلا محل إذا للوصية المستترة^(٢).

ومن ذلك نرى أن القرينة القانونية التي أقامها القانون الجديد، وهي احتفاظ المورث بالحياسة، وبحقه في الانتفاع مدى حياته، هي

(١) د. السنهوري - الوسيط - ج٤ - ص ٣٣ حيث يقول: " ويجوز إثبات أن التصرف بيع أو هبة لا وصية، بتقديم قرائن في هذا المعنى، كتسجيل التصرف، والتنازل عن شرط منع التصرف، وتبرير الاحتفاظ بحياسة العين عن طريق أن المشتري قاصر وأن المشتري باشر الحياسة نيابة عنه".

(٢) د. السنهوري - المرجع نفسه.

الشيء الثابت في هذه المسألة، وهى قرينة قابلة لإثبات العكس، فيجوز إثبات أن التصرف بيع أو هبة بتقديم قرائن في هذا المعنى. ومما دفع القانون الجديد لهذا المسلك أن التكييف للعقد في ظل القانون القديم، كان يتطلب أو لا تقصى ما اتجهت إرادة الطرفين إلى إحداثه من آثار قانونية، مع مراعاة ظروف وملابسات هذه الإرادة وهذا مما بدخل في سلطة قاضى الموضوع على أن يلتزم بقواعد الإثبات، فإذا كان انزعاع بين وارث المتصرف الذي يتمسك بان التصرف وصية تلحق به ضرراً لتجاوزها حدود ثلث تركة مورثه، فيحق له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، بما فيها البنية والقرائن، لأن ما يريد إثباته ينطوى على احتيال على القانون من جانب المتصرف^(١)، والقرائن التى يلجأ إليها كثيرة ومتنوعة وتقديرها متروك لقاضى الموضوع، بشرط أن يكون ما يستخلص منها سائغاً وغير مخالف للثابت بالأوراق^(٢)، وفي هذا كثيراً ما يختلف القضاء.

كذلك اختلفت المحاكم في ظل التقنين الملغى، في شأن مثل هذا العقد فاعتبره البعض بيعاً^(٣)، بينما اعتبرته بعض الحاكم وصية، وهذا الفريق الذي اعتبر التصرف وصية اختلف فيما بينه بشأن

(١) د. سليمان مرقس - السابق - ص ٤٠.

(٢) د. سليمان مرقس - أصول الإثبات وإجراءاته - السابق - ص ٨٨.

(٣) من ذلك حكم محكمة النقض المدنى في ١٧/٢/١٩٣٦، مجلة امحامة ١٦ - ٨٧٨ - ٤٠١، نقض مدنى ٨/٣/١٩٤٥م، مجموعة القواعد القانونية.

الظروف والشروط والقيود، والملاسات التي يمكن أن تستفاد منها نية الإيضاء، فاكنت بعض المحاكم بثبوت حصول التصرف دون مقابل، وببقاء العقد في حيازة المتصرف أو عدم تسجيله، واستتباط بعضها الآخر نية الإيضاء من اتفاق العاقدین على عودة ملكية المبيع إلى البائع إذا توفى المشتري قبله، أو من بقاء البائع محتفظاً بمزايا الملكية ومظهرها، كالحيازة والتأجير والتقاضى^(١).

ولقد كان من أهم القرائن التي عول عليها القضاء في استتباط نية الإيضاء من التصرف الذي ثبت حصوله دون مقابل، أن يكون البائع قد احتفظ لنفسه بحق الانتفاع إلى حين وفاته^(٢)، أو أن يشترط على المشتري المنع من التصرف في المبيع حال حياته، وقد اتفقت بعض المحاكم بأحد هذين الشرطين، واشترط البعض الآخر اجتماعهما، بينما رأت أغلبية المحاكم ن اجتماع هذين الشرطين لا يكفي لثبوت نية الإيضاء، ولا يمنع وجودهما من اعتبار العقد بيعاً، ما لم توجد قرائن أخرى تعزز فكرة الإيضاء، ومن ثم كان من اللزوم على المشرع أن يتدخل لحسم هذا الخلاف، وذلك بما نص عليه في المادة (٩١٧) مدنى.

(١) حكم محكمة مصر بهيئة استئنافية في ١٦/١٢/١٩٢٥ مجلة المحاماة ٦ - ٣٢٧ - ٢٥٠.

(٢) حكم محكمة استئناف مصر في ٢٢/١/١٩٢٣ مجلة المحاماة ٣ - ١٦٢ - ١٠٨ وحكم محكمة النقض المدنى في ٢/٢/١٩٦٩م المجموعة ٢٠ - ٦٤٩ - ١٠٥.

ويشترط لوجود توافر القرينة على نية الإيصاء وفقاً لما تنص عليه المادة ٩١٧ مدني، أن تتوافر الشروط الآتية:

أولاً: أن يكون التصرف صادراً إلى أحد الورثة، ويشترط أن تتوافر هذه الصفة للمتصرف إليه، وقت وفاة المتصرف لا وقت انعقاد التصرف فإذا كان المتصرف إليه وارثاً وقت التصرف، ثم أصبح غير وارث وقت الوفاة، فإن القرينة لا تقوم، والعكس بالعكس، فإذا كان المتصرف إليه غير وارث وقت التصرف ثم أصبح وارثاً وقت الوفاة، فإن الشرط يكون متوافراً.

ثانياً: أن يحتفظ المتصرف بأي طريق كان بحياسة العين التي تصرف فيها، والحياسة واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات، كأن يقوم باستعمال العين واستغلالها أو دفع الضرائب المقررة عليها ويكتفى هنا بالحياسة المادية، فلا يشترط الركن المعنوي للحياسة^(١).

ثالثاً: أن يحتفظ المتصرف لنفسه بحق الانتفاع بالعين طوال حياته، تلك هي الشروط الثلاثة التي أقامتها المادة (٩١٧) مدني، لتقوم القرينة على أن التصرف وصية، ويستطيع المتصرف إليه أن يثبت أن العقد في حقيقته بيع، وذلك بكافة طرق الإثبات.

ويلاحظ كما يقرر الأستاذ السنهوري أن المادة (٩١٧) من القانون المدني قد استحدثت قرينة قانونية تتصل بموضوع الحق اتصالاً وثيقاً، ومن ثم لا يكون لها أثر رجعي شأنها في ذلك شأن سائر القواعد الموضوعية^(٢)، لأن الرجعية لا تقرر إلا بنص ولا نص هنا.

(١) د. السنهوري - الوسيط - ج ٤ - ص ٣٣.

(٢) الوسيط - ج ٤ - ص ٢٤ وما بعدها.

الباب الأول

أركان عقد البيع

الباب الأول

أركان عقد البيع

يلزم لانعقاد البيع توافر أركان معينة هي الرضا والمحل والسبب، وهذه الأركان يمكن أن تعتبر شروطاً لانعقاد، فإذا تخلف ركن منها كان عقد البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً، كما يشترط لصحة البيع أهلية المتعاقدين، وسلامة رضاهما من العيوب، فإذا شاب الرضا غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال، أو كان أحد المتعاقدين ناقص الأهلية كان العقد قابلاً للإبطال لمصلحة ناقص الأهلية، أو من كان رضائهم معيباً، وتطبق هنا القواعد العامة^(١).

ودراسة أركان عقد البيع تقتضي بيان الرضا والمحل ثم إن المحل في عقد البيع مزدوج لأنه يشمل المبيع والتمن، ولم تقتضي الدراسة أن تتعرض للسبب كركن في العقد، حيث أن تطبيقه على عقد البيع ليس فيه زيادة عما يدرس في النظرية العامة للالتزام، ومن ثم فإننا بالنسبة لدراسة نكتفي بالإحالة عليها، ونقصر دراستنا على الفصول الآتية:

الفصل الأول: الرضا في عقد البيع.

الفصل الثاني: المبيع.

الفصل الثالث: الثمن.

(١) د. عبد الرزاق حسن فرج - ص ٣٦ فقرة ١٨.

الفصل الأول

الرضا في عقد البيع

الفصل الأول

الرضا في عقد البيع

من المعروف أن العقد يتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التعبير عن إرادتين متطابقتين، وذلك وفقاً لما تقضى به المادة (٨٩) مدنى، ومن ثم فإن عقد البيع لا ينعقد إلا إذا اقترن الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول من المتعاقد الآخر مطابق له فيما تضمنه من شروط، ولكن هل يصلح السكوت أن يكون قبولاً في عقد البيع؟

الواقع أن السكوت المجرد لا يصلح - بحسب الأصل - أن يكون قبولاً، لأن السكوت عدم، ولهذا يقرر فقهاء الشريعة الإسلامية: انه لا ينسب لساكت قول، ولئن كان ذلك كذلك، إلا أن السكوت المجرد يمكن أن يكون قبولاً استثناءً، وذلك وفقاً للضابط المعروف والذي يقضى بأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإنه إذا قامت قرينة تدل على أن السكوت يصلح قبولاً، وذلك على نحو ما تنص عليه المادة (٩٨) مدنى مصري، بقولها: "ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين، واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه"، وفي هذا الإطار أيضاً يجيئ نص المادة (٨١) مدنى مصري التى تقرر أنه: "لا ينسب لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان، وفي هذا الإطار يمكن أن يكون السكوت قبولاً".

وفي الفقه الإسلامي يكون سكوت البكر قبولاً منها بالزواج، وقد ثبت هذا الحكم بالسنة النبوية المطهرة، فيما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الأيّم تستأمر، والبكر تستأذن، وإذنها سكوتها"، فهنا أيضاً يقوم السكوت مقام القبول، وغنى عن البيان أن هناك نوعاً من العقود ينعقد بالتعاطى، وبدون كلام يصدر من الموجب أو القابل، فالسكوت له دور في الانعقاد إذا دلت القرائن على وجود الرضا معه.

المبحث الأول

مضمون الرضا في عقد البيع

الرضا لازم لانعقاد البيع، والبيع شأنه في ذلك شأن أى عقد آخر، ولا يتصف الرضا في البيع بما يميزه بصفة خاصة عن الرضا في العقود الأخرى، والرضا في عقد البيع يجب أن يتم على العناصر الجوهرية التى يتم التراضى عليها فيه، كما يقتضى بيان الأهلية اللازمة لإبرام عقد البيع، وسلامة الإرادة من العيوب ونخصص لكل موضوع منها مطلباً.

المطلب الأول

التراضى على العناصر الرئيسية في عقد البيع

والعناصر التى يتم التراضى عليها في عقد البيع تنقسم إلى عناصر رئيسية، وعناصر تفصيلية أو ثانوية.

أولاً: العناصر الأساسية التى يتم التراضى عليها في عقد البيع:

لعل من أهم تلك المسائل أن يتطابق الإيجاب والقبول على طبيعة العقد الذي يراد إبرامه وهو عقد البيع، فإذا لم تتطابق الإرادتان، بأن قصد الطرف الأول بيعاً، وقصد الثانى رهناً أو نكاحاً فإن العقد لا ينعقد على أى مما قصده التعاقدان، وذلك لعدم تطابق الإرادة^(١).

(١) في هذا المعنى: حكم النقض المدنى في ١٠/١٠/١٩٦٣.

كذلك فإنه يجب تطابق الإرادتين على الشيء المبيع، فإذا عرض احد الطرفين على الآخر أن يبيعه منزلاً يملكه في مدينة معينة، بينما اتجهت إرادة الطرف الآخر إلى شراء منزل آخر فلا يكون هناك بيع ولا ينعقد العقد لعدم تطابق الإرادتين على الشيء المبيع.

كما يجب أن تتطابق الإراداتان على ثمن الشيء المبيع فإذا كان الثمن المعروض من البائع للسيارة مقداره عشرة آلاف جنيه فقبل المشتري الشراء بمبلغ خمسة آلاف جنيه، فإن العقد لا ينعقد وذلك لعدم توافق الإرادتين على ركن من أركان البيع وهو الثمن.

ومن المسائل التي يثيرها الفقه في هذا الصدد مسألة ما إذا رضى المشتري بالشراء بثمن أعلى من الثمن الذي طلبه البائع، حيث ذهب جانب من الفقه إلى أن البيع ينعقد بالثمن الأقل الذي سماه البائع، وذلك لورود الاتفاق عليه ضمناً، فالمشتري بعرضه ثمناً أكبر من الثمن الذي يطلبه البائع يعتبر راضياً بالثمن الأقل من باب أولى^(١).

وهناك جانب آخر من الفقه يفرق بين حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان المشتري يعتقد عن غلط أن الثمن الذي قام بعرضه هو نفس الثمن الذي عرضه البائع، ففي هذه الحالة ينعقد البيع بالثمن الأقل، أما إذا كان المشتري يعلم بالثمن الذي عرضه

(١) من هذا الرأي: الهاللي وحامد زكى - شرح القانون المدنى عقد البيع والحوالة والمقايضة في القانونية القديم والجديد ١٩٥٤ - ص ٧١.

البائع، وزاد هو فيه لاقتناعه بأن المبيع يساوى هذا الثمن فعلاً، ورغبته في عدم استغلال حاجة البائع أو عدم علمه بما يساويه المبيع فعلاً، فإن الثمن الأعلى يعتبر عرضاً جديداً يتضمن إيجابياً من المشتري، فلو سكت البائع عنه يُعد قبولاً لهذا الإيجاب الجديد الصادر من المشتري لأنه يتمخض لمنفعته، وذلك تطبيقاً لحكم المادتين (٩٦، ٩٨/٢) مدنى، والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه: "إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه، اعتبر رفضاً بتضمن إيجاباً جديداً، كما تقضى الفقرة (٢) بأنه: "يعتبر السكوت عن الرد قبولاً إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه"^(١).

المسائل الجوهرية في عقد البيع - إذن - يمكن تلخيصها في ورود التراضى على طبيعة العقد، وعلى محله المتمثل في البيع والتمن، وتلك هى المسائل الجوهرية التى يجب الاتفاق عليها في البيع، ومع ذلك فإن هناك سؤالاً يثار حول مدى كفاية الاتفاق على تلك المسائل لانعقاد العقد، بحيث يكون الاتفاق عليها كافياً لإبرامه أم لابد من الاتفاق على المسائل التفصيلية أو الثانوية الأخرى كزمان تسليم الشيء المبيع ومكانه، وزمان الوفاء بالتمن ومكانه؟ ذلك ما سنبيّنه في الفقرة الآتية.

(١) د. عبد الرزاق حسن فرج - ص ٤١.

ثانياً: الاتفاق على المسائل التفصيلية أو الثانوية:

والمسائل التفصيلية كما سبق أر رأينا، هي التي لا يتوقف انعقاد العقد عليها، وذلك مثل مكان تسليم المبيع، وميعاد دفع الثمن، فمثل هذه المسائل إذا سكت عنها المتعاقدان ولم يتعرضا لمناقشتها، فإن نصوص القانون المكملة لإرادة الأفراد أو قواعد العرف أو العدالة تكون كفيلة بحلها، ويتم العقد دون الاتفاق الصريح عليها، وفي هذا المعنى تنص المادة (٩٥) مدنى على أنه: "إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبار العقد قد تم، وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فإن المحكمة تقضى فيها طبقاً لطبيعة المعاملة، وأحكام القانون والعرف والعدالة"^(١).

ومن هذا النص يتضح أنه إذا اتفق كل من البائع والمشتري على البيع، وعلى الشيء المبيع والثمن، واحتفظا ببعض المسائل التفصيلية للاتفاق عليها فيما بعد، فإنه يفترض أنهما قد ارتضيا حكم القانون أو العرف أو العدالة في هذا الشأن، وهى قواعد مكملة لإرادة الطرفين.

أما إذا انصرفت نيتها إلى أن يجعلها من المسائل التفصيلية غير الجوهرية، عناصر داخلية في الاتفاق، أو مناقشا مسألة تأجيل الثمن أو تقسيطه، أو من يتحمل منهما مصاريف تسلم البيع إلا إذا تم

(١) د. عبد الرازق حسن فرج - ص ٤٢.

اتفاقهما، ليس فقط على المسائل الجوهرية، بل وعلى المسائل التي تفاوضا فيها، أو ناقشاها.

وتقدير ما إذا كان المتعاقدان قد علقا انعقاد البيع على الاتفاق بشأن هذه المسائل التفصيلية من عدمه، أو أنهما قد جعلتا منها مسائل جوهرية، يعتبر من المسائل الموضوعية، التي يترك أمرها لقاضى الموضوع، يفصل فيها وفقاً لطبيعة المعاملة، وطبقاً لحكم القانون والعرف والعدالة^(١).

والأصل في الإيجاب ألا يكون ملزماً، فيجوز للموجب الرجوع عنه إلى أن يتلقى به القبول، ولكن إذا مات من صدر له الإيجاب أو فقد أهليته بعد صدور القبول منه، فإن ذلك لا يمنع من تمام البيع، عند اتصال القبول بعلم الموجب، وهذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل^(٢).

الإيجاب الموجه إلى الجمهور:

ولا يشترط في الإيجاب ان يكون موجهاً إلى شخص معين، بل أنه قد يكون موجهاً للكافة، وينعقد به العقد إذا ما اقترن به قبول، وكثيراً ما تجرى عادة التجار، على أن يعلنوا عن سلعهم سواء بعرضها في واجهات محلاتهم مع كتابة أثمانها عليها، أو بالإعلان عن السلع

(١) الوسيط للسنهورى - ج ٤ - ص ٦٠ وما بعدها.

(٢) المرجع والمكان نفسه.

وأثمانها في الجرائد اليومية، أو في نشرات خاصة يرسلونها إلى عملائهم، أو يوزعونها عليهم ولا نزاع في أن عرض السلع مع كتابة أثمانها في واجهات المحلات التجارية يعتبر إيجاباً صريحاً من الموجب (التاجر) ينعقد به العقد إذا ما اقترن به قبول، وليس للموجب أن يرفض العقد بدعوى أن هذا الإيجاب لم يكن موجهاً لمن قبل، فالأصل أن شخصية المتعاقد لا اعتبار لها في عقود المعاوضات. ولكن ما الحكم إذا كان التاجر قد أعلن عن بضاعته في الصحف اليومية أو في نشرات خاصة أرسلها إلى عملائه، فهل يعتبر ذلك منه إيجاباً ينعقد به العقد إذا اقترن به قبول أم أن الأمر ليس كذلك؟

ذهب رأى إلى أن ذلك يعتبر إيجاباً صحيحاً وصالحاً لأن يقترن به القبول، ويلتزم تبعاً لذلك من وجه الإيجاب على هذا النحو بالتعاقد مع كل من يتقدم إليه بالقبول أولاً فأول في حدود مقدار ما عنده من سلع، ولا يتقيد الموجب بهذا الإعلان بعد نفاذ ما عنده من سلع^(١).

وذهب رأى آخر إلى أن ذلك لا يعتبر إيجاباً، وإنما يعتبر دعوى إلى التفاوض ما لم يتبين عكس ذلك من دقة البيانات التي تتضمنها هذه الإعلانات^(٢).

(١) د. محمد على عمران - ص ٣٤.

(٢) د. سمير تتاغو - ص ٤١، د. جمال زكى - قانون عقد البيع - ص ١٨.

ويرى الأستاذ الدكتور السنهوري - رحمه الله - أنه يجب التفرقة بين الحالتين:

الحالة الأولى: عرض السلع على الجمهور عن طريق النشرات والإعلانات والكتالوجات وهذا في الغالب يكون دعوة إلى التعاقد لا إيجاباً كاملاً.

الحالة الثانية: حالة ما إذا كانت النشرة أو الإعلان أو الكتالوج قد أرسل إلى شخص بالذات بعنوانه الشخصي، وقد قصد صاحب المتجر أن يوجه إليه إيجاباً، فإن هذا يعتبر إيجاباً كاملاً، فإذا لقي هذا الإيجاب استجابة ممن وجه إليه كان هذا قبولاً وتم البيع^(١)، وهذا الرأي هو الذي يترجح لدينا.

المطلب الثاني

الأهلية اللازمة لإبرام عقد البيع

والمراد بالأهلية في عقد البيع هي أهلية الأداء، ومفادها صلاحية الشخص لإبرام التصرفات القانونية، ومناط أهلية الأداء هو التمييز، ومن ثم فإن هديم المميز، كالصبي غير المميز، وهو من لم يبلغ سبع سنين من عمره (م ٤٥) مدنى، والمجنون والمعتوه بعد تسجيل قرار الحجر عليهما أو قبل تسجيله، وكانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها يكون بيعهم

(١) الوسيط للسنهوري - ج ٤ - ص ٦٢ ومابعداها.

باطلاً، وكذلك فإن بيع الصبي المميز، وهو من بلغ السابعة، ولم يبلغ الحادية والعشرين من عمره في غير الحدود الجائزة التي نص عليها القانون، يكون العقد قابلاً للإبطال لمصلحته، فإذا اجزء الوصى أو الوصى أو القيم عليه، أو أذنت به المحكمة، كان صحيحاً، ويأخذ حكم الصبي المميز السفيه، وذو الغفلة (م ٤٦) مدنى بعد تسجيل قرار الحجر عليهما أو بعد تسجيله إذا كان تصرفهما بالبيع نتيجة استغلال أو تواطؤ، وإذا أذن لهما بإدارة أموالهما بعد الحجر عليهما، كان حكمهما حكم الصبي المأذون له في إدارة أمواله فيصبح بيعهما وشراؤهما فيما تقتضيه أعمال الإدارة بالنسبة لهذه الأموال^(١).

ولما كان عقد البيع من أعمال التصرف، فإنه يلزم لانعقاده أهلية التصرف التي تتوافر - بحسب الأصل - لكل من بلغ سن الرشد وهى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.

وقد أجاز القانون على سبيل الاستثناء لمن لم يبلغوا هذه السن أن يتصرفوا بالبيع في بعض الأحوال، ومن ذلك:

أولاً: ما تقضى به المادة (٦١) من قانون الولاية على المال، رقم ١٦ لسنة ١٩٥٢ من أن: "للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته ويصح التزامه المتعلق بهذه الأغراض في حدود هذا المال فقط، ومن ثم فإن بيعه

(١) د. عبد الرزاق حسن فرج - ص ٤٤.

المتعلق بأغراض نفقته يكون صحيحاً في هذه الحدود فإذا تجاوز هذه الحدود، كان التصرف قابلاً للإبطال لمصلحته".

ثانياً: للقاصر الذي بلغ السادسة عشرة من عمره التصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره (م ٦٣) من قانون الولاية على المال، فيجوز له أن يشتري ما يشاء من كسب عمله، ويكون شراؤه صحيحاً ما دام في حدود هذا الكسب.

ثالثاً: كذلك فإن لمن بلغ الثامنة عشرة من عمره أن يتجر إذا اذنته المحكمة في ذلك (م ٥٧) من القانون المذكور، فله أن يبيع ويشترى فيما يتعلق بتجارته، وفي حدود الإذن الصادر من المحكمة.

رابعاً: للقاصر المأذون بالزواج التصرف في المهر والنفقة ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك عند الإذن أو في قرار لاحق (م ٦٠) من القانون المذكور.

خامساً: إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره، وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون (م ١١٢) مدنى.

ويبدو من ذلك أن للقاصر المأذون بتسلم أمواله كلها أو بعضها أن يدير هذه الأموال، وإدارته لها، قد تقتضى قيامه بإبرام البيع والشراء، وذلك مثل قيامه بشراء السماد والآلات، أو بيع ما تنتجه الأرض من ثمار وحاصلات، فيكون بيعه صحيحاً في نطاق هذه الحدود^(١).

(١) د. عبد الرزاق حسن فرج - ص ٤٤ وما بعدها.

المطلب الثالث

سلامة الإرادة من العيوب

عقد البيع كغيره من العقود يشترط لصحته أن يكون خالياً من العيوب وهى الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال، ولما كان القانون المدنى المصري الحالي لم يتضمن نصوصاً تنظم هذه العيوب في عقد البيع، فإنه يتعين الرجوع في هذا الشأن للقواعد العامة في نظرية العقد.

إلا أن المشرع قد أورد في باب البيع حكماً خاصاً بشرط العلم بالبيع على النحو الكافى، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة (٤١٩) مدنى، كما أورد حكماً خاصاً بالغبن في بيع العقار المملوك للقاصر، المواد (٤٢٥ إلى ٤٢٧) مدنى، ومن ثم يجب بيان هذين الأمرين.

الفرع الأول

العلم بالمبيع علماً كافياً

تنص المادة (٤١٩) مدنى، على أنه: "١- يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً، ويعتبر العلم كافياً إلى اشتمل على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه.

٢- وإذا ذكر عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إذا ثبت تدليس البائع".

وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني المصري على هذا النص بأنه يوفق بين خيار الرؤية المعروف في الشريعة الإسلامية، وبين المبادئ العامة للقانون المدني، وهذه لا تشترط رؤية المبيع، بل تقتصر على اشتراط أن يكون معيناً تعييناً كافياً^(١).

التعريف بخيار الرؤية في الفقه الإسلامي:

خيار الرؤية معناه: الحق المقرر للمشتري عند شراء ما لم يره في إمضاء البيع أو فسخه بعد رؤية المبيع، ولخيار الرؤية أهمية خاصة في عقود البيع التي يغلب أن يكون المبيع فيها أشياء أو آلات لم يرها المشتري، وإنما رغب في شرائها من خلال معرفة أوصافها في كتاب أو خطاب، وهنا يجبي دور خيار الرؤية ليكون وسيلة من وسائل تحقيق الرضا في مثل هذه الصور من صور البيع، حين يفاجأ المشتري بأن الشيء الذي رغب في شرائه ليس على الحالة التي يريدها^(٢).

دليل مشروعية خيار الرؤية:

وقد دل على مشروعية خيار الرؤية ما روى عن أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه"^(٣)، حيث دل هذا الحديث على أن خيار الرؤية مما يثبت للمشتري في بيع ما لم يره، وذلك عند رؤية المبيع.

(١) مجموعة الأعمال التحضيرية - ج٤ - ص ١٩.

(٢) فتح القدير - للكمال بن الهمام - ج٥ - ص ١٣٧.

(٣) أخرجه الدارقطني في سننه والبيهقي في سننه - راجع: نصب الراية - ج٤ - ص ٩.

وقت ثبوت خيار الرؤية وسببه:

ويثبت خيار الرؤية للمشتري عند رؤية المبيع لا قبلها فلو أجاز البيع قبل الرؤية لا يلزم البيع ولا يسقط الخيار، وله أن يرد المبيع، ومما يدل على اعتبار وقت الرؤية لثبوت الخيار قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه"، حيث رتب الحديث ثبوت الخيار على عدم الرؤية، فدل على أن وقته يتعين بها، كما يدل أيضاً على أن الرؤية سبب لثبوته، فالخيار يثبت عند رؤية المبيع لا قبلها كما أن المشتري إذا أسقط حقه في خيار الرؤية فإنه لا يسقط، لأن إسقاط الخيار فرع عن ثبوته، وثبوت الخيار بالرؤية، فهو يثبت بعد الرؤية لا قبلها.

أثر الخيار على العقد وشروط ثبوته:

من المقرر أن خيار الرؤية يؤثر على لزوم العقد، حيث يجعله غير لازم بمعنى أنه يجوز للمشتري أن يرجع فيه بعد إبرامه، ولكن حتى يتحقق ذلك الأثر لابد من توافر شرطين:

أولهما: أن يكون محل العقد مما يتعين بالتعيين، أي أن يكون عيناً من الأعيان التي يمكن أن ترى وتفحص كالأشياء، والآلات، والأدوات وغيرها، ومن ثم لا يثبت خيار الرؤية في حالة ما إذا كان المعقود عليه ديناً كما في عقد السلم.

ثانيهما: عدم رؤية محل العقد، فيشترط حتى يثبت الخيار أن يكون محل العقد لم ير من قبل بالنسبة للمشتري، فإذا كان قد سبق أن رآه فإن السبب الذي بمقتضاه يثبت حق خيار الرؤية يكون قد زال.

ما تتحقق به الرؤية:

والمراد بالرؤية في خيار الرؤية حصول العلم بالمبيع وتحقيق معرفته أعم من أن تكون تلك المعرفة بالرؤية فتشمل حصول العلم بالرؤية في كل ما من شأنه أن يرى كما يثبت العلم بالشئ أو بالذوق أو باللمس أو غير ذلك من الخواص التي يمكن ان يتحقق العلم بها^(١).

مسقطات خيار الرؤية:

(١) ويسقط خيار الرؤية بإسقاط من له الخيار صريحاً: كأن يقول:

أسقطت الخيار، أو أجزت البيع، أو غير ذلك من العبارات التي تدل على الإسقاط الصريح للخيار، ومما يفيد الإسقاط أيضاً، تصرف المشتري في المبيع بعد الرؤية بأى وجه من وجوه التصرف كالببيع والهبة والوصية، وكذلك التصرف المادي كشوي اللحم، وعجن الدقيق، وغير ذلك من وجوه التصرف المادي في المبيع.

(٢) موت من له الخيار: من المعروف أن الموت تسقط به الحقوق المتعلقة بمشيئة الميت وإدارته، وخيار الرؤية منها فيسقط بالموت.

(٣) هلاك المعقود عليه: إذا هلك المعقود عليه، فإنه بهلاكه يسقط خيار الرؤية، لتفرعها عن وجود المعقود عليه، وإذا هلك فإنه بهلاكه يفوت محلها، كما يفوت بالتالي الخيار الناشئ عنها.

(١) وفي هذا المعنى تنص المادة (٢/٥١٧) مدنى عراقى، على أن المراد بالرؤية الوقوف على خصائص الشيء ومزاياه بالنظر أو الفحص أو الشم أو السمع أو المذاق، وراجع المادة (٣٢٣) من مجلة الحكام العدلية.

حقيقة العلم الكافي بالمبيع:

والعلم الكافي وفقاً لما تنص عليه المادة (٤١٩) مدنى، يقصد به معرفة أوصاف الشيء الأساسية وبيانها يمكن من التعرف عليها، والعلم الكافي على هذا النحو يختلف عن تعيين المبيع أو قابليته للتعيين، حيث يقصد بتعيين المبيع ما يمكن به تمييزه عن غيره، كما أن المبيع قد يكون معيناً دون أن يعلم به المشتري علماً كافياً وذلك كما في بيع منزل معين بموقعه، فإن هذا يكفى لتحقيق شرط التعيين، وينعقد العقد، إلا أن المشتري قد لا يعلم بالأوصاف الرئيسية للمنزل، من حيث عدد الطوابق والوحدات السكنية به، والمساحة وغير ذلك مما يعد من أوصاف البيع الرئيسية^(١).

كما يختلف العلم الكافي عن تعيين المبيع في الأثر المترتب على كل منهما، فعدم تعيين المبيع يترتب عليه بطلان العقد بطلاناً مطلقاً، أما عدم العلم بالمبيع علماً كافياً، فإنه يترتب عليه قابلية العقد للبطلان فيكون منتجاً لآثاره حتى يقضى بإبطاله^(٢).

ما يتحقق به العلم الكافي بالمبيع:

والعلم الكافي بالمبيع كما يتحقق بالرؤية المادية، يمكن كذلك تحقيقه بمجرد وصف الشيء المبيع وصفاً يمكن من تعرفه، خلاف ما هو مقرر في الرؤية التي يثبت بها خاير الرؤية في الفقه الإسلامي، حيث يشترط فيها العلم لا الوصف^(٣).

(١) د. عبد الرزاق حسن فرج - ص ٤٩ وما بعدها.

(٢) المرجع السابق - ص ٥٠، وراجع: د. إسماعيل غانم - ص ٧٨.

(٣) قارن في هذا: أستاذنا الدكتور عبد الرزاق حسن فرج - ص ٥٠.

ومن ثم فإن العلم بالمبيع يمكن أن يتحقق في القانون بالطرق الآتية:

أولاً: معاينة المبيع معاينة تكفى للتعرف عليه:

وهذه المعاينة قد تتحقق بالمشاهدة المادية أو باللمس أو بالذوق، أو بالشم حسب طبيعة الشيء المبيع، وقد تتم المعاينة بمعرفة لمشتري نفسه، كما يجوز أن يقوم بها نائب عنه.

والمعاينة المطلوبة هنا، هي تلك التي تتم ثقت ايرام العقد أو قبله، أما المعاينة التي تتم بعد تمام البيع، فلا تحول دون قيام المشتري بطلب الإبطال، ومعاينة المشتري للمبيع علي هذا النحو تكفي لاعتباره عالماً للمبيع ولو لم تكن هذه المعاينة قد أدت في الحقيقة إلى معرفة المشتري لأوصاف المبيع الأساسية ما دامت قد تمت بطريقة وافية من شأنها أن تمكن العلم للرجل المعتاد^(١).

ثانياً: بيان المبيع وأوصافه الأساسية في العقد:

وكما يتم العلم بالمعاينة فإنه يتم أيضاً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه مادة (١٩/٤) مدنى، وكون الوصف كافياً أو غير كاف لتتحقق على لمشتري يعتبر من المسائل الموضوعية التي يترك تقديرها لقاضى الموضوع^(٢).

(١) د. خميس خضر - فقرة ٢٨.

(٢) د. عبد الفتاح عبد الباقي - المكان السابق.

والعلم بطريق الوصف قد تقضيه الضرورة أحياناً، كما لو اشترى الأعمى بنفسه، أو اشترى المبصر شيئاً ليس في مجلس العقد ووصف له وصفاً شفويّاً أو كتابياً^(١).

ثالثاً: إقرار المشتري بالعلم بالمبيع:

إذا لم يعاين المشتري المبيع، ولم يذكر في العقد بيان أوصافه الأساسية، ولكن ذكر فيه أن المشتري عالم به، فإن هذا يعتبر إقراراً من المشتري بالعلم به، وقد جاء في المادة (٢/٤١٩) مدني: "إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع".

فإقرار المشتري بالعلم بالمبيع عند التعاقد يسقط حقه في الطعن في العقد بدعوى عدم العلم به، سواء اكان هذا العلم متفقاً مع الواقع، فيتحقق العلم فعلاً، أم كان مخالفاً للواقع فيدل على أن المشتري لا يعلق أهمية على علمه بالمبيع، أو أنه قد تنازل عن التمسك بالطعن في البيع على أساس عدم العلم بالمبيع، وفي هذا مخالفة للأحكام المقررة في خيار الرؤية المقرر في الفقه الإسلامي، والتي لا تجيز النزول عنه قبل أن تتم الرؤية فعلاً وذلك على نحو ما رأينا. إلا أنه إذا كان إقرار المشتري بالعلم بالمبيع قد جاء نتيجة تدليس قام به البائع فإن حق المشتري في طلب الإبطال لا يسقط

(١) راجع: د. جميل الشرقاوى - ص ٤٨.

ومثل ذلك أن يوهم البائع المشتري بأن المبيع شيء آخر غير لذي عين في العقد، فيقر المشتري بأنه يعرف المبيع^(١).

الجزاء المترتب على عدم علم المشتري بالمبيع:

فإذا لم يعلم المشتري بالمبيع على النحو السابق يكون له الحق في طلب إبطال البيع على أساس عدم علمه بالمبيع، ومؤدى هذا أن العقد في هذه الحالة يظل صحيحاً منتجاً لآثاره حتى يتقرر إبطاله بناء على طلب المشتري فتزول آثاره باثر رجعي، وتستطيع المحكمة أن تحكم بهذا الإبطال هنا، إذا لم تمسك المشتري به، وهو صاحب الحق فيه.

وأساس إبطال العقد لعدم علم المشتري به، أن المشتري إذا لم يعلم بالمبيع فعقده غير صحيح إما لغلط فيه، وإما لأن المبيع لا يكون معيناً مع أن القانون يوجب تعيينه^(٢)، وخصوصية الغلط هنا من ناحيتين:

أولاً: أنه غلط خاص بوفاء العين المبيعة بالغرض المقصود منها.

ثانياً: أنه غلط يفترضه القانون، ويعفى المشتري من إثباته^(٣).

سقوط حق المشتري في الإبطال لعدم العلم بالمبيع:

من الواضح أن المشرع لم يعرض لتنظيم سقوط حق المشتري في طلب الإبطال لعدم العلم بالمبيع، ومن ثم فإنه يجب الرجوع إلى

(١) د. سليمان مرقس - ص ٤٢، د. عبد المنعم البداروي - ص ٢٥١.

(٢) أحمد نجيب الهلالي وحامد زكي - السابق - فقرة ٧٢.

(٣) الوسيط للسنةوري - ص ١٦٤ هامش (١).

القواعد العامة التي تقضى بسقوط الحق في التمسك بالإبطال،
بالإجازة والتقدم، وبالأسباب الأخرى التي يسقط بها خيار الرؤية في
الفقه الإسلامي.

١ - الإجازة:

يسقط حق المشتري في طلب إبطال البيع لعدم العلم بالمبيع
بالإجازة الصريحة أو الضمنية ومثال الإجازة الصريحة أن يقول
المشتري: رضيت أو أجزت، أما الضمنية فإنها تتمثل في اتخاذ
المشتري موقفاً يدل على نيته في إمضاء العقد، كأن يتصرف في
العين المشتراه بالبيع أو أن يبني عليها، ويشترط حتى تنتج الإجازة
أثرها ويسقط الحق في طلب الإبطال صدورها بعد علم المشتري
بالمبيع.

٢ - الإبطال:

يسقط حق المشتري في التمسك بالإبطال لعدم العلم بالمبيع
طبقاً للقواعد العامة، إذا سكت عن التمسك به خلال ثلاث سنوات تبدأ
من وقت علمه بالشيء المبيع، أو بمضي خمس عشرة سنة تبدأ من
وقت انعقاد البيع أي المدين أقصر، مادة (١٤٠) مدني.

٣ - حالات أخرى لسقوط الحق في طلب الإبطال:

وثمة حالات أخرى تؤدي إلى سقوط خيار الرؤية في الشريعة
الإسلامية، وذلك مثل:

(أ) تعيب المبيع في يد المشتري وهلاكه أو زيادته في بعض الأحوال، ففي هذه الحالات يسقط حق المشتري في طلب الإبطال لاستحالة رد المبيع إلى البائع بالحالة التي كان عليها وقت تسليمه، وهذا رأى جانب كبير من الفقه في مصر^(١)، كما أنه يتفق مع أحكام خيار الرؤية.

(ب) تصرف المشتري في المبيع قبل العلم به تصرفاً يوجب حقاً للغير:

ومن المقرر طبقاً للقواعد العامة أن الإجازة لا تنتج أثرها إلا إذا صدرت ممن له الحق فيها بعد زوال العيب الذي لحق بالعقد، ومن ثم فإن قيام المشتري بالتصرف في المبيع قبل العلم به لا يعتبر إجازة، إلا أنه لما كان المشرع قد جعل من ذكر المشتري في عقد البيع أنه عالم بالمبيع مسقطاً لحقه في طلب الإبطال ولو لم يكن على علم به في الواقع، فإنه يمكن بالقياس - من باب أولى - اعتبار تصرف المشتري في المبيع قبل العلم به مانعاً من حقه في طلب الإبطال^(٢).

(ج) موت المشتري:

إذا مات المشتري فإن حقه في طلب الإبطال يسقط، وذلك ما ذهب إليه فقهاء الحنفية، لأن الخيارات لا تورث عندهم وجمهور الفقهاء على خلاف رأى الحنفية، حيث إن عندهم كل حق يتعلق

(١) راجع: السنهوري - السابق - ص ١٦٣ هامش (٢).

(٢) د. منصور مصطفى منصور - ص ٧٥ وما بعدها.

بالمال يورث وحق الخيار متعلق بالمال فيورث، ومثله الأخذ بالشفعة، وقد أخذت محكمة النقض برأى الجمهور، وقررت أن الموت لا ينهى الحقوق المتعلقة بالمال، وأنها تنتقل إلى الورثة^(١)، ومن ثم فإن حق طلب الإبطال لعدم العلم الكافي ينتقل إلى الورثة^(٢).

الفرع الثانى

الغبين في بيع عقار مملوك لناقص الأهلية

يعرف الغبن بأنه عدم التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وما يحصل عليه من مقابل، حيث يكون أحد البدلين غير متكافئ مع الآخر في القيمة عند التعاقد.

والغبين في فقه الشريعة لا يبتعد عن هذا المعنى، حيث يعرف بأنه النقص في أحد العوضين على نحو فادح، وهذا النوع من الغبن يعطى المشتري الحق في طلب فسخ العقد إذا اشترط في العقد على نحو ما ورد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - لحبان بن منقذ: "إذا بعت فقل لا خلافة ولى الخيار ثلاثة أيام فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فأردها على صاحبها"^(٣).

(١) حكم محكمة النقض في ١٩٤٦/١/٣١، مجموعة عمر - ج ٥ - ص ٨٠ رقم ٣٣.

(٢) د. عبد الرازق حسن فرج - ص ٥٧.

(٣) راجع: صحيح البخارى مع فتح البارى - ج ٤ - ص ٣٣٧، ومسند الإمام أحمد - ج ٢ - ص ٨٠.

والأصل في الغبن أنه لا يعيب الإرادة إذا كان نتيجة استغلال أحد المتعاقدين في المتعاقد الآخر طيشاً بيناً أو هوى جامحاً، وفي هذه الحالة يجوز للمتعاقد المغبون، أن يطلب إبطال العقد أو نقص التزامته (م ١٣٩) مدنى.

ويبدو من خلال هذا النص أنه يشترط لإبطال العقد بسبب الغبن أن يتوافر عنصران:

أولهما: عنصر مادي؛ يتمثل في عدم التعادل بين الالتزامات نتيجة استغلال أحد الطرفين للآخر.

ثانيهما: عنصر معنوي؛ أو نفسي وهو كون عدم التعادل نتيجة طيش أو هوى جامح استغله أحد المتعاقدين وكان دافعاً للتعاقد لدى المتعاقد الآخر، ومن ثم لا يصلح الغبن وحده للطعن في العقد وفقاً للقواعد العامة^(١).

ومع ذلك فإن المشرع قد خرج على هذه القاعدة فيما يتعلق ببيع العقار لغير كامل الأهلية، فنص في المادة (٤٢٥) مدنى ، على أنه: "١- إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس للبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل، ٢- ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع".

(١) د. إسماعيل غانم - ص ٢٩١ وما بعدها.

وتنص المادة (٤٢٦) مدنى، على أنه: "١- أن تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن، إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الهلية، أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع، ٢- ولا تلحق هذه الدعوى ضرراً بالغير حسن النية إذا كسب حقاً على العقار المبيع".

كما تنص المادة (٤٢٧) مدنى، على أنه: "لا يجوز الطعن بالغبن في بيع ثم كنص القانون بطريق المزاد العلنى".

شروط صحة الطعن بالغبن:

ويبدو من نصوص تلك الواد أنه يشترط لصحة الطعن في عقد البيع بالغبن أن تتوافر الشروط التالية:

(١) أن يكون المبيع عقاراً:

ويكون كذلك إذا كان حقاً عينياً وارداً على عقار، كحق الانتفاع وحق الرقبة أو حق الحكر، ومن ثم فإن المبيع إذا كان منقولاً فإنه لا يجوز الطعن فيه مهما بلغت قيمته، إلا إذا توافرت شروط الاستغلال كعيب من عيوب الإرادة، والتفرقة بين العقار والمنقول في هذا الشرط منتقدة في عصرنا الحالى الذي ارتفعت فيه قيمة بعض المنقولات حتى أصبحت تفوق قيمة العقارات كثيراً، وكان من الأولى بالمشرع أن يقتدى بالشريعة الإسلامية الغراء في هذا الصدد، حيث لا تفرق بين العقار والمنقول في الأحكام، على اعتبار أن كلا منهما يمثل عيناً من الأعيان، وهى التى تقابل الدين في الفقه الإسلامى،

ومن العجيب أن تقسيم الفقه الإسلامي للأموال على هذا النحو، هو الذي أدركه الفقه الوضعي في فرنسا والدول التي تسير في ركابها تشريعياً بعد جهد جهيد، وبعد أن تقدم العلم وتطورت المخترعات بما أسفر عن تفوق ملموس لقيمة المنقول في كثير من الأحيان عن العقارات، خاصة في مجال الأجهزة الدقيقة، والآلات العلمية والطبية والحربية وغيرها، وتقسيم الفقه الإسلامي قائم منذ ما يزيد على ألف سنة ومع ذلك فإنه قد استوعب كل تلك التطورات التشريعية الوضعية الحديثة وتفوق عليها سبقاً وموضوعاً^(١).

(٢) أن يكون العقار مملوكاً لناقص الأهلية:

وناقص الأهلية كالصبي المميز، أو المحجور عليه لسفه أو غفلة وفي حكمه - من باب أولى - معدوم الأهلية كالصبي غير المميز والمجنون والمعتوه، فإذا كان البائع كامل الأهلية، بأن بلغ سن الرشد، ولم يكن محجوراً عليه بسبب جنون أو عته أو صفة أو غفلة، فإن بيعه يكون صحيحاً، ولا يجوز الطعن فيه بالغبن مهما كان فاحشاً، إلا إذا توافرت فيه شروط دعوى الاستغلال.

وإذا كان ناقص الأهلية هو الذي قام بالبيع بنفسه، فإنه يكون له أن يطلب الطعن في البيع بالغبن، وله فضلاً عن ذلك أن يطلب إبطاله بسبب نقص أهليته، وله أن يختار بين الدعويين، أما إذا كان

(١) راجع في هذا المعنى: رسالتنا للدكتورة من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - سنة ١٩٨٤ - ص ٢٥٠ وما بعدها.

البائع عديم الأهلية، فإن البيع يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، وبالتالي لا يكون هناك محل للطعن بالغبن.

أما إذا باشر البيع من ينوب عنه كالولى أو الوصى أو القيم فلا يكون هناك محل لرفع دعوى الإبطال لنقص الأهلية، ومما هو جدير بالذكر أن قانون الولاية على المال رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢م قد ضيق من سلطة الأولياء والأوصياء، والقيم، فاشتراط لصحة البيوع التى يقومون بها الحصول على إذن من المحكمة، وللمحكمة أن ترفض هذا الإذن، إذا كان في البيع غبن فاحش يزيد على خمس قيمة العقار، وذلك وفقاً لما تقضى به المادة (٧) من القانون المذكور.

ويلاحظ أن الغائب والمحجور عليه لعقوبة جنائية، ومن أقيم له مساعد قضائى لا يعتبر أى منهم ناقص الأهلية بسبب الغيبة أو العقوبة أو العاهة، ومن ثم فإنه يسرى عليهم ما يسرى على كامل الأهلية من أحكام في بيع العقار^(١).

(٣) أن يكون الغبن زائداً على خمس قيمة العقار وقت البيع:

ويشترط أن يقع في البيع غبن يزيد على خمس ثمن المثل للعقار، ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع (م ٤٢٥) مدنى، وبالتالي فإنه لا يعتد بتقدير قيمة العقار بوقت رفع الدعوى أو الحكم فيها^(٢).

(١) د. إسماعيل غانم - ص ٩٤ وما بعدها.

(٢) د. سمير تناغو - فقرة ٢٩.

(٤) أن يقع الغبن على البائع لا على المشتري:

والبائع المغبون هو الذي يجوز له أن يطعن بالغبن طبقاً لأحكام المادة (٤٢٥) إذا كان البيع قد تم بثمن يقل عن أربعة أخماس ثمن المثل، أما إذا كان قد تم بثمن يزيد عن ثمن المثل، فلا يكون للمشتري الطعن بالغبن، وإنما يجوز له أن يطعن على أساس أن إرادته قد شابها عيب الاستغلال إذا توافرت شروط دعوى الاستغلال^(١).

ولا تدخل العقود الاحتمالية في الطعن بالغبن، لأنها تقوم على الاحتمال الذي يعنى عدم معرفة مقدار ما سيأخذه كل واحد من المتعاقدين فيها، وإن كان من الأولى أن يترك التقدير فيها لقاضى الموضوع يفصل فيها على حسب الظروف والملايسات^(٢).

(٥) ألا يكون البيع قد تم بالمزاد العلنى:

وذلك في الحالات التى يوجب القانون فيها البيع بتلك الطريقة كما في حالة بيع أموال المدين بيعاً جبرياً وفاء لديونه، وبيع عقار القاصر بالمزاد العلنى، وفقاً للإجراءات المقررة في المواد من (٤٥٩ إلى ٤٦٢) من قانون المرافعات الحالى.

ووجه الحكمة من منع الطعن بالغبن في تلك البيوع أن القانون قد رسم لها إجراءات تكفل للبائع الحصول على أعلى ثمن ممكن، ومن

(١) د. محمد على إمام - فقرة ١٢٥.

(٢) الوسيط للسنهورى - فقرة ٢٢١.

ثم فلا محل للطعن في البيع بدعوى الغبن الفاحش بعد ذلك ولو أبيح للطعن فيه لأدى ذلك إلى الإحجام عن الدخول في المزاد وقلة الثمن الذي يرسى به المزاد، وفي هذا منافاة لقصد المشرع ومصادره على المطلوب، فإذا تم البيع بالمزاد، ولكن في غير الحالات التي يوجبها القانون، كما إذا دعا البائع من تلقاء نفسه إلى هذا المزاد، فإن الضمانات التي تكفل الحصول على أكبر ثمن ممكن لا تتحقق وبالتالي يجوز الطعن في البيع بالغبن في هذه الحالة^(١).

أثر وجود الغبن (دعوى تكملة الثمن):

إذا توافرت الشروط السابقة، كان للبائع أن يطعن في البيع بالغبن مطلقاً بتكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل، وترفع دعوى تكملة الثمن من الشخص الذي بيع عقاره، بعد أن يستكمل أهليته، أى بعد بلوغه سن الرشد أو رفع الحجز عنه، أو من ورثته بعد وفاته، كما يجوز أن يرفعها الولى أو الوصى أو القيم حالة ما إذا قام بالبيع ناقص الأهلية نفسه^(٢).

وتسقط دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن بانقضاء ثلاث سنوات من وقت اكتمال أهلية البائع، أو من وقت موته قبل أن تكتمل أهليته (م ١٤٦/١ مدنى).

(١) د. منصور مصطفى منصور - فقرة ٣٥.

(٢) د. عبد المنعم البدرأوى - فقرة ١٥٤.

وهذه المدة مدة تقادم، وليست مدة سقوط، ولهذا فإنه يسرى عليها انقطاع التقادم، ولكن هذه المدة لا يرد عليها الوقف لأن التقادم الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات لا يرد عليه الوقف بسبب عدم توافر الأهلية، ولو لم يكن للدائن نائب يمثله قانوناً (م ٢/٣٨٢) مدنى. ويجوز لمن اكتملت أهليته أن يتنازل عن الدعوى، ولا يجوز له التنازل قبل ذلك، كما لا يجوز للولى، ولا للمحكمة أيضاً، كما تسقط دعوى الإبطال بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من وقت موت البائع^(١).

وإذا رفعت الدعوى تكملة الثمن في ميعادها، وكانت مستوفية لشروطها، فإنه يجب على القاضى أن يحكم بتكملة الثمن إلى أربعة أخماس قيمة المبيع لا إلى الثمن كاملاً، هذا ويعتبر فرق الثمن المحكوم به على المشتري جزءاً من الثمن فيكون مصمونهاً بامتياز البائع، بشرط إجراء قيد له، وتكون مرتبة هذا الامتياز من تاريخ إجراء هذا القيد التكميلي، وللبيع كذلك أن يطلب فسخ البيع إذا امتنع المشتري عن الوفاء به طبقاً للقواعد العامة.

وإذا توصل البائع إلى فسخ البيع، فإن الفسخ بحسب الأصل يترتب عليه زوال العقد بأثر رجعى وعودة العقار المبيع، ولكن المشرع هنا قد حرص على حماية الغير حسن النية في المادة (٢/٤٢٦) التى تقضى بأنه: "لا تلحق هذه الدعوى (دعوى تكملة الثمن)، ضرراً بالغير

(١) د. السنهورى - المكان السابق - د. عبد الفتاح عبد الباقي - فقرة ٧٤.

حسن النية إذا كسب حقاً عينياً على العقار المبيع، وهذا الحكم يعتبر تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة (١٧) من قانون الشهر العقاري، وبالتالي فإنه إذا كان المشتري قد رتب حقاً عينياً على العقار المبيع كحق الرهن أو حق الانتفاع أو حق الارتفاق، فإن الفسخ لا يضر بصاحب الحق العيني، بشرط أن يكون حسن النية، وقت اكتساب حقه، وفي هذه الحالة يعود العقار إلى البائع محملاً بالحق العيني.

وإذا كان المشتري قد تصرف بدوره في العقار المبيع بالهبة أو البيع إلى شخص حسن النية سجل عقده، ففي هذه الحالة تستقر الملكية للمشتري حتى لو قضى له بالفسخ لصالح البائع. ومن المعروف أن المشتري يعتبر سيء النية بمجرد شهر دعوى فسخ البيع لعدم تكملة الثمن، ويجب حتى يحتفظ الغير بحقه العيني على العقار بالرغم من فسخ البيع، أن يكون قد أشهر حقه في تاريخ سابق على شهر دعوى الفسخ^(١).

(١) د. أنور سلطان وجلال العدوى - ص ١٦٩.

المبحث الثاني

بعض الصور الخاصة للتراضى في عقد البيع

التراضى في عقد البيع قد يقترن بأوصاف خاصة، كأن يكون مقترناً بالشرط، أو مضافاً إلى أجل، كما يجوز تعليقه على شرط فاسخ، وهذه الأوصاف تحكمها المبادئ العامة في نظرية الالتزام وليست هناك أحكام خاصة يختص بها عقد البيع في هذا الشأن، إلا أن هناك بعض صور التراضى التى قد تصاحب عقد البيع، كالوعد بالبيع أو الشراء، وهناك البيوع الموصوفة، ونبين ذلك في مطلبين:

المطلب الأول

الوعد بالبيع أو بالشراء

يلاحظ أن التقنين المدنى الحالى لم يعرض لتنظيم الوعد بنصوص خاصة، وذلك اكتفاء بما ورد بشأن الوعد بالتعاقد في النظرية العامة للالتزامات في المادتين (١٠١ ، ١٠٢) مدنى، وهما تنطبقان على البيع.

أما المادة (١٠١) مدنى، فقد بينت الوعد بالتعاقد بصفة عامة حيث قالت: "١- الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التى يجب إبرامه فيها.

٢- وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد".
وأما المادة (١٠٢) مدنى، فقد بينت حكم الوعد بالتعاقد فقالت: "إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً بتنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضى به مقام العقد".

صور الوعد بالبيع:

ويبدو من نص المادة (١٠١/١) مدنى، أن للوعد بالبيع ثلاث صور: حيث إن الوعد قد يكون بالبيع من جانب واحد، وقد يكون بالشراء من جانب واحد، كما قد يكون وعداً متبادلاً بالبيع والشراء.

أولاً: الوعد بالبيع من جانب واحد:

هو عقد يتضمن وعداً بالبيع من شخص لآخر، بأن يبيعه شيئاً معيناً بثمن معين وبشروط معينة، إذا ما عبر الموعد له عن رغبته في الشراء في خلال مدة معينة، ويلزم الوعد الواعد وحده، أما من صدر له الوعد فلا يلتزم بالشراء إلا إذا أبدى رغبته في ذلك، فيصبح الوعد بيعاً باتاً، والوعد بالبيع من جانب واحد لا يعتبر إيجاباً، لأن مصدر الالتزام في حالة الإيجاب هو إرادة المنفردة، أما في حالة الوعد فهو عقد الوعد^(١).

(١) د. عبد الرزاق حسن فرج - ص ٦٧.

وقد ضرب الفقه أمثلة عديدة للوعد بالبيع الملزم لجانب واحد ومنها: أن يريد شخص إنشاء مصنع على أرض معينة، فيستأجرها من صاحبها، ويقيم عليها هذا المصنع، ويحصل في لوقت نفسه من المالك لها على وعد بالبيع، إذا رغب هو في شراء هذه الأرض في خلال مدة معينة.

ولما كان الوعد بالبيع عقداً فإنه يجب أن تتوافر فيه الشروط العامة لانعقاد العقد، وهى تلاقى الإيجاب والقبول، وتطابقهما على ماهية الوعد بالبيع، وأن تعين جميع العناصر الجوهرية لاتعقاد البيع، وهى المبيع والثمن، والمدة التى يجب فيها إبرام البيع صراحة أو ضمناً^(١).

ويشترط لصحة عقد الوعد بالبيع أن تتوافر في طرفيه الأهلية وقت صدور الوعد، بأن يكون الواعد أهلاً للتصرف وقت الوعد^(٢). ويشترط في الوعد بالتمفضل توافر العناصر الجوهرية للبيع الموعود بالتمفضل فيه، كبيان الشيء الموعود بالتمفضل في بيعه، والمدة التى يجب على الواعد أن يعرض الشيء خلالها إذا أراد بيعه، وأما بالنسبة للثمن فإنه يجوز ان يحدد على ضوء ما يعرضه الغير.

(١) راجع في هذا المعنى: حكم محكمة النقض المدنى في ١٩٦٤/١/٢٣ - الجمعة ١٥ - ص ١١٥.

(٢) د. أنور سلطان وجلال العدوى - ص ١٣٤ وما بعدها.

ويختلف الوعد بالتفضيل عن الوعد بالبيع، فالواعد لا يلتزم بالبيع، بل يلتزم بأن يعرض على الموعد له أن يشتري منه إذا ما رغب في بيع ما يملكه، أى أن الالتزام قاصر على إلزام الواعد بتفضيل الموعد له في البيع^(١).

ثانياً: الوعد بالشراء من جانب واحد:

وقد يكون الوعد بالشراء من جانب واحد فقط، كما إذا وعد شخص آخر بأن يشتري منه شيئاً معيناً بثمن معين، إذا قبل الموعد له البيع في خلال مدة معينة، فالوعد هنا ملزم لجانب واحد هو الواعد بالشراء، أما صاحب الشيء فإنه لا يلتزم بالبيع فإذا ما أبدى رغبته انعقد البيع منذ اللحظة التى أبدى فيها هذه الرغبة^(٢).

وحتى يكون الوعد بالشراء صحيحاً، فإنه يجب أن تحدد فيه كافة العناصر الجوهرية للعقد المراد إبرامه، فيجب أن يتضمن تحديداً للمبيع والثمن، وأن يتضمن أيضاً بياناً بالمدة التى يجب على الموعد له (البائع) أن يبدي رغبته في أثائها، وليس هذا سوى تطبيق للقواعد العامة، الخاصة بالوعد بالتعاقد^(٣).

ثالثاً: الوعد المتبادل بالبيع والشراء:

وفي هذه الصورة يعد أحد المتعاقدين المتعاقد الآخر أن يبيعه شيئاً معيناً إذا ما أبدى رغبته في ذلك، ويعدده الآخر بأن يشتري هذا

(١) د. جميل الشرقاوى - فقرة ٣٣.

(٢) الوسيط للسهنورى - فقرة ٣٥.

(٣) د. محمد على عمران - المكان نفسه.

الشيء إذا ما أبدى هذه الرغبة، أى أن كلاً منهما يعد موعوداً له وواعداً في آن واحد معاً، وفي هذه الحالة يعتبر الوعد ملزماً لكل من الطرفين، فيلتزم الطرف الأول بالبيع إذا ما أبدى الآخر رغبته في الشراء، ويلتزم الآخر بالشراء إذا ما أبدى الأول رغبته في البيع، مع ملاحظته أنهما لم يقصدا إبرام العقد في الحال، وإلا كان العقد بيعاً لا مجرد وعد وإنما قصدا إرجاء انعقاده إلى حين إبداء كل منهما رغبته في هذا الانعقاد^(١).

البيع الابتدائي والوعد:

ويجب عدم الخلط بين عقد البيع الابتدائي الوارد على عقار والوعد بالبيع والشراء، فالبيع الابتدائي عقد بات، وبمقتضاه يلتزم أحد الطرفين بالبيع والآخر، بالشراء على أن يقوما بتحرير عقد البيع النهائي في خلال مدة معينة، وكل ما هناك أن نقل الملكية من البائع إلى المشتري لا يتم إلا بالتسجيل، ولهذا فإن البيع الابتدائي يختلف عن الوعد المتبادل بالبيع والشراء الذي لا يعتبر بيعاً نهائياً، ولا تترتب عليه آثاره في الحال، بل تترتب هذه الآثار عند إبداء الموعود له رغبته في إبرامه فلا يلتزم الواعد بالبيع بالتزامات البائع إلا عند إبداء الرأى الآخر رغبته في الشراء، وكذلك فإن الواعد بالشراء لن يلتزم بالتزامات المشتري إلا عند إبداء الطرف الآخر رغبته في البيع فعقد البيع الابتدائي يعتبر بيعاً، وليس وعداً تبادلياً بالبيع والشراء^(٢).

(١) د. جميل الشرقاوى - ص ٧٦.

(٢) د. أنور سلطان وجلال العدوى - فقرة ٢٠٦.

المطلب الثاني

البيع الموصوفة

والبيع الموصوفة نوع من البيع اعتراه وصف يؤثر في طبيعته أو يحد من آثاره، وذلك كالبيع بشرط التجربة، وبيع المذاق والبيع بالعينة، والبيع بالعربون، ونحدد لكل من تلك البيع فرعاً.

الفرع الأول

البيع بشرط التجربة

وهو نوع من البيع يحتفظ فيه بحقه في تجربة البيع لمعرفة مدى مناسبته له أو مدى صلاحيته للغرض الذي أعد له.

وقد يتفق المتعاقدان في العقد صراحة على حق المشتري في تجربة المبيع، وقد يستفاد شرط التجربة ضمناً من عادات وظروف التعامل أو طبيعة الشيء المبيع، كما هو الشأن بالنسبة لشراء الملابس الجاهزة المعدة للاستعمال الشخصي، حيث تجرى العادة بأن يقوم المشتري بارتدائها لمعرفة مقاسها، وهذا نوع من التجربة، وكما في شراء السيارات المستعملة، وغيرها حين يقوم المشتري بتجربتها للتأكد من صلاحيتها، وكما هو الحال في شراء الراديوهات والتلفزيونات^(١).

وقد نصت المادة (٤٢١) مدنى، على أنه: "في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه، وعلى البائع أن

(١) د. توفيق فرج - فقرة ١٠٠.

يمكنه من التجربة، فإذا رفضا لمشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة، ففي مدة معقولة يعينها البائع فإذا انقضت هذه المدة، وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً".

طبيعة البيع بشرط التجربة:

والأصل أن يكون البيع بشرط التجربة بيعاً معلقاً على شرط واقف هو قبول المشتري المبيع بعد تجربته، ما لم يتفق المتعاقدان صراحة أو ضمناً على اعتباره بيعاً معلقاً على شرط فاسخ، هو عدم قبول المشتري المبيع بعد تجربته، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (٤٢١) مدنى، بقولها: "ويعتبر البيع بشرط التجربة بيعاً معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع، إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ".

ومفاد ذلك أنه في البيع بشرط التجربة تتوقف كل آثار العقد إلى أن يقبل المشتري المبيع بعد تجربته، فإذا تحقق الشرط أصبحت كل آثار العقد نافذة من وقت اتلعاقد، ما لم يتفق المتعاقدان صراحة أو ضمناً على اعتبار البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط فاسخ، فتنترب على آثار العقد فور انعقاده، بحيث إذا رفض المشتري المبيع زال العقد بكل آثاره، ويكون لهذا الزوال أثر رجعى^(١).

(١) د. خميس خضر - ص ٦٣ وما بعدها.

حكم البيع بشرط التجربة:

وإذا ما ثبت حق المشتري في تجربة المبيع على هذا النحو فإنه يكون على البائع أن يبسر له القيام بهذه التجربة، حيث يقع على عاتق البائع التزام إضافي يتمثل في تمكين المشتري من تجربة المبيع، طبقاً لما يتفق عليه بينهما، أو وفقاً لما يقضى به العرف ومبادئ العدالة.

ويلتزم المشتري بالتجربة خلال المدة المحددة لذلك، فإن لم يتم بها كان للبائع أن يعذره بالقيام بها، ولما كان العقد في هذه الحالة معلقاً على شرط واقف بحسب الأصل، فإن عدم قيام المشتري بالتجربة خلال المدة المحددة مع تمكنه من ذلك، يؤدي إلى منع تحقق الشرط من جانبه ومن ثم يعتبر الشرط محققاً بمجرد مرور المدة، ويكون للبائع أن يعتبر البيع نهائياً، كما أن انقضاء الميعاد دون تحفظ يعتبر قبولاً^(١).

مدى حرية المشتري في القبول أو الرفض:

وقد أثير تساؤل في الفقه حول ما إذا كان للمشتري الحرية المطلقة في قبول المبيع أو رفضه أم أنه مقيد في ذلك؟ ووفقاً لما تقضى به المادة (١/٤٢١) مدنى، يجوز للمشتري في بيع التجربة أن يقبل المبيع أو يرفضه، وجاء في المذكرة الإيضاحية: "أن للمشتري حرية القبول أو الرفض فهو وحده الذي يتحكم في نتيجة

(١) د. توفيق فرج - فقرة ١٠٣.

التجربة، إذ المفروض أن يكون المبيع من الأشياء التي يتطلب فيها أن تتناسب المشتري مناسبة شخصية فهو وحده الذي يستطيع أن يقرر ذلك^(١).

وبناء على ذلك يكون للمشتري الحرية المطلقة في قبول المبيع أو رفضه، دون إبداء الأسباب إذا كان المبيع يستجيب لحاجة شخصية خاصة بالمشتري، كالملابس الجاهزة إذا ناسبت استعماله الشخصي، وليس للبائع إذا ما رفض المشتري المبيع بعد تجربته، أن يثبت أنه كان ملائماً للغرض الذي كان يريده المشتري^(٢).

أما إذا كان المقصود من التجربة هو استبيان مدى صلاحية المبيع للغرض المقصود منه لا مناسبته لحاجة المشتري الشخصي كأن يكون آلة ميكانيكية، فلا يجوز للمشتري رفض المبيع، إلا إذا بين وجه عدم صلاحيته، وإلا خضع هذا الرفض لرقابة القضاء ولقاضي أن يستعين بأهل الخبرة لمعرفة مدى ملائمة المبيع للأغراض المقصودة منه.

فإذا ثار الشك حول مقصدهما، فمن المفروض أن يعول على مناسبة المبيع لحاجة المشتري الشخصية، ويكون له الحرية المطلقة في القبول أو الرفض^(٣).

(١) مجموعة الأعمال التحضيرية - ج ٤ - ص ٢٦.

(٢) د. إسماعيل غانم - فقرة ٧٣.

(٣) الوسيط للسنيهورى - ج ٤ - فقرة ٦٩.

الفرع الثانى

بيع المذاق

من أنواع المذاق ما لا يمكن الحكم عليه إلا بعد تذوقه كالزيوت والخل وبعض المأكولات، ومن ثم لا يكون البيع في مثلها باتاً في معظم أحواله إلا إذا تذوقه المشتري، ووافق عليه، وأعلن هذه الموافقة إلى البائع في المدة المتفق عليها، وقد حرص المشرع المصري على أن يبين حكم بيع المذاق، فنص في المادة (٤٢٢) مدنى، على أنه: "إذا بيع الشيء بشرط المذاق، كان للمشتري أن يقبل المبيع إن شاء، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التى يعينها الاتفاق أو العرف، ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان".

وإذا اشترط المشتري على البائع ألا يتم البيع إلا إذا ذاق المبيع فإن البيع لا ينعقد إلا من الوقت الذي يعلن فيه المشتري، قبوله المبيع خلال المدة المحددة لذلك، ولا يكون للبيع أثر إلا منذ اللحظة التى يتم فيها هذا القبول، وقبل ذلك لا يوجد بيع وإنما مجرد وعد بالبيع من جانب البائع وحده^(١).

(١) يستفاد من ذلك من نص المادة ٤٢٢ مدنى، وراجع: مجموعة الأعمال التحضيرية - ج ٤ - ص ٢٨.

التفرقة بين بيع المذاق وبين التجربة:

ويقرر الفقه أن هناك فروقاً بين بيع المذاق وبيع التجربة،

وهذه الفروق تتمثل فيما يلي:

أولاً: في بيع التجربة:

إذا قبل المشتري المبيع تحقق ذلك بأثر رجعي، لأنه بيع معلق على شرط واقف، إلا إذا اتضح من الظروف أنه معلق على شرط فاسخ.

أما في البيع بشرط المذاق فهذه في حقيقته وعد بالبيع فلا ينعقد إلا في وقت إعلان قبول المشتري، دون أن يكون لذلك أثر رجعي يترد إلى يوم البيع.

ثانياً: في بيع التجربة:

يعتبر سكوت المشتري عن إبداء رغبته في المدة المحددة قبلاً منه للبيع، بينما السكوت في بيع المذاق يعتبر رفضاً للبيع وبمقتضاه يتحلل الواعد من وعده^(١).

ثالثاً: هلاك الشيء المبيع قبل مذاقه يقع على البائع.

رابعاً: إذا أفلس البائع قبل قبول المشتري في بيع المذاق، فإن المشتري لا يستأثر بالشيء وحده دون جماعة الدائنين على خلاف البيع بشرط التجربة، فإن التجربة يستأثر بالشيء المبيع دون جماعة الدائنين، لأنه يعتبر مالاً منذ إبرام البيع وليس من وقت قبوله للمبيع.

(١) د. عبد الرزاق حسن فرج - ص ٧٩ وما بعدها.

خامساً: إذا وقع حجز على الشيء من قبل دائن البائع في بيع المذاق قبل قبول البيع، فإن هذا الحجز يعتبر سارياً في مواجهة المشتري على خلاف الحكم في البيع بشرط التجربة^(١).

حكم بيع المذاق:

ووفقاً لما انتهى إليه الفقه في اعتبار بيع المذاق وعداً بالبيع فإنه لا يوجد بيع ما دام الموعود له لم يظهر رغبته في الشراء ولا يترتب على هذا الوعد آثار عقد البيع، وتظل ملكية الشيء الموعود ببيعه للواعد، ويتحمل تبعه هلاكه.

والذي يترتب على هذا الوعد التزام الواعد بتمكين الموعود له من المذاق، في الزمان وفي المكان، وبالكيفية التي يجرى عليها الاتفاق، أو وفقاً لما يقضى به العرف، فإذا أخل الواعد بالتزامه جاز للموعود له، أن يحصل على حكم بإلزامه بدفع غرامة تهديدية لحمله على التنفيذ، ويجوز له أن يطالب بالتعويض إن كان له محل.

وللموعود له الحق في قبول المبيع، إذ هو وحده الذي يقرر مدى مناسبته لذوقه الشخصي، وعليه أن يعلن البائع بقبوله في المدة التي يحددها الاتفاق أو العرف، فإذا رفض قبول المبيع أو ترك المدة المحددة لإعلان رغبته، تنقضى دون أن يعلن عن قبوله، اعتبر سكوته رفضاً للشراء وحالتتذ يتحلل الواعد من وعده بالبيع، وفي هذا يختلف

(١) الوسيط للسنهوري - ج٤ فقرة ٧٥.

البيع بشرط المذاق، عن البيع بشرط التجربة، حيث يعتبر سكوت المشتري فيه عن إبداء رأيه في المدة المحددة قبولاً للمبيع^(١).

الفرع الثالث

البيع بالعينة، أو النموذج

وقد يتم البيع بالعينة أو النموذج، وفيه يتفق كل من المتعاقدين على أن يكون البيع على أساس عينة يقوم البائع بتقديمها للمشتري، فإذا ما تم الاتفاق على أساس هذه العينة أو النموذج كان على البائع أن يسلم إلى المشتري الشيء المبيع مطابقاً لهذه العينة المتفق عليها. ويعرض هذا البيع كثيراً من العمل، فالذي يبيع التمر يقدم كمية صغيرة منه، والذي يبيع القماش يعرض قطعة صغيرة منه تكشف عن نوع المبيع.

والبيع بالعينة عند من يجيزونه من فقهاء الشريعة، كما أنه في القانون يعتبر طريقاً لتعيين المبيع يغنى عن وصفه كما يغنى عن رؤيته^(٢).

وفي البيع بالعينة تنص المادة (٤٢٠) مدني، على أنه:
" ١- إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون مطابقاً لها. ٢- وإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ، كان على المتعاقد بائعاً أو مشترياً، أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق".

(١) د. أنور سلطان وجلال العدوى - فقرة ٢٠٣.

(٢) الوسيط للسنهوري - فقرة ١٢٤.

حكم البيع بالعينة:

ويتضح من هذا النص أنه في حالة البيع بالعينة، يجب أن يكون المبيع مطابقاً لها، وأما عن حكم البيع بالعينة فإنه يعتبر بيعاً باتاً لدى بعض الفقهاء^(١)، بينما يرى جانب آخر من الفقه أن بيع العينة يعتبر بيعاً معلقاً على شرط فاسخ، أي أن المشتري يلتزم منذ البداية، ولكن اشتراط زوال العقد حاصل أن تبين عدم مطابقة المبيع للعينة.

والرأى الراجح في نظرنا؛ هو الرأى الأول، لأنه الموافق لقصد المتعاقدين وطبيعة العقد، وعليه فإنه يجب أن يكون المبيع مطابقاً للعينة على نحو تام، وللمشتري أن يرفض تسلم المبيع، إذا لم يجده موافقاً للعينة، حتى ولو أثبت البائع أن المبيع أفضل من العينة نوعاً أو أكثر منها قيمة، فالوفاء يتم بما التزم المدين به أصالة ولا يجبر العاقد على قبول شيء آخر، غيره حتى ولو كان أفضل منه^(٢).

أما في حالة مطابقة المبيع للعينة، فإن المشتري لا يستطيع رفضه، حتى لو وجده غير ملائم لحاجته، إلا أنه إذا كان الفرق بين المبيع والعينة تافهه بحيث لا يؤثر على صلاحية المبيع للغرض الذي اشترى عن النقص في جودة المبيع، وذلك بإنقاص الثمن^(٣).

(١) د. عبد المنعم البداروى - السابق.

(٢) د. السنهورى - فقرة ١٢٥.

(٣) د. منصور مصطفى منصور - فقرة ٢٦.

وإذا ادعى المشتري أن المبيع غير مطابق للعينه وكانت هذه العينة موجودة لديه أو لدى البائع، فإن هيقع على البائع عبء إثبات مطابقة المبيع للعينه، ويجوز في هذه الحالة الاستهذار برأى الخبير علماً بأن رأيه غير ملزم للقاضى.

الخلاف على العينة:

وإذا وقع الخرف بين البائع والمشتري على ذاتية العينة، فإنه يجب التفرقة بين حالتين:

الحالة الأولى:

عند وجود العينة لدى أحد المتعاقدين يكون هو المدعى عليه وفقاً لقواعد العامة ويكون الآخر هة المدعى وعليه يقع عبء إثبات أن الشيء الذي في يد الطرف الآخر ليس هو العينة المتفق عليها، إلا إذا كانت هناك علامات متفق عليها بين الطرفين، قد وضعت على العينة، فوجود تلك العلامات يكفى لإثبات ذاتية العينة^(١).

الحالة الثانية:

عند هلاك العينة أو تلفها لدى أحد المتعاقدين بخطأ منه، أو بدون خطأ، أو بسبب أجنبي لا يد لأحد منهما فيه، وفي هذه الحالة يجوز للمتعاقد الآخر بائعاً كان أو مشترياً أن يثبت مطابقة الشيء للعينة أو عدم مطابقته لها مادة (١/٢٤٠) مدنى، وبناء على ذلك فلو كانت العينة لدى البائع وهلكت وأدعى المشتري عدم مطابقة المبيع

(١) د. السنهورى - فقرة ١٢٧.

لها، كان على البائع أن يثبت هذه المطابقة، وإذا كانت العينة لدى المشتري^(١) وهلك، كان عليه أن يثبت عدم مطابقة المبيع للعينة، إذا ادعى ذلك بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن.

أثر عدم مطابقة المبيع للعينة:

وإذا كان المبيع غير مطابق للعينة يجوز للمشتري أن يطالب البائع بتسليم شيء مطابق لها، وهذا هو التنفيذ العيني ويجوز للمشتري طبقاً للقواعد العامة أن يحصل على هذا الشيء بنفسه من الأسواق على نفقة البائع بعد استئذان القضاء أو قبل استئذانه في حال الاستعجال مادة (٢٠٥) مدني، كما يجوز للمشتري أن يطالب بفسخ العقد لعدم قيام البائع بتنفيذ التزامه وهو تقديم شيء مطابق للعينة، ويخضع الفسخ لتقدير قاضي الموضوع مادة (٢/١٥٧) مدني، كما يجوز للمشتري أن يطالب بالتعويض وفقاً للقواعد العامة، كما أن له أن يطالب بإنقاص الثمن، إذا قلت قيمة المبيع عن قيمة العينة^(٢).

(١) وذلك هو الغالب في بيع العينة أو النموذج.

(٢) د. عبد الفتاح عبد الباقي - فقرة ٢٠.

الفرع الرابع

البيع بالعربون

يطلق العربون ويراد به المبلغ الذي يدفعه أحد المتعاقدين للآخر وقت انعقاد العقد في بعض العقود كالبيع والإيجار.

وقد يكون العربون تأكيداً لإبرام العقد عن طريق تعجيل جزء من الثمن كبدء في تنفيذه، كما قد يكون العربون دليلاً للعدول، حيث يفقد قيمته من يعدل عن العقد، فإذا كان المشتري هو الذي عدل عن البيع فإنه يفقد العربون، وإذا عدل البائع فإنه يلتزم برد المبلغ الذي قبضه ومثله معه، حتى ولو لم يترتب على العدول ضرر، لأن العربون ليس تعويضاً عن الضرر، وإنما هو مقابل للعدول^(١).

وقد عرض المشرع المصري لتقنين أحكام العربون في نظرية العقد، ومن ثم يكون هذا الحكم صالحاً لسائر العقود، ومنها البيع جاء ذلك في المادة (١٠٣) مدنى، والتي تنص على أنه: "١- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في دفع العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك. ٢- فإذا عدل من العربون فقده، وإذا عدل من قبضه رد ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أى ضرر".

(١) د. السنهورى - فقرة ٣٥، د. أنور سلطان وجلال العدوى - ص ١٤٨.

التوصيف القانوني للبيع بالعربون:

وقد أثار التكييف القانوني للبيع بالعربون خلافاً بين الفقهاء:

فذهب رأى إلى أن البيع بالعربون يعتبر بيعاً معلقاً على شرط واقف هو عدم العدول عن البيع خلال مدة معينة، حث تتوقف هذه الآثار خلال المدة المذكورة، ثم تترتب بأثر رجعي يستند إلى وقت انعقاد العقد عند انتهاء المدة بدون عدول^(١).

وذهب رأى آخر إلى أن البيع بالعربون يعتبر بيعاً معلقاً على شرط فاسخ، هو العدول، فينتج العقد آثاره من وقت انعقاده، ولكنه يكون مهدداً بالزوال طوال المدة التي يجوز فيها العدول، فإذا تحقق الشرط زال البيع بأثر رجعي.

ويعيب تكييف البيع بالعربون بأنه معلق على شرط واقف أو فاسخ، أنه متى تخلف الشرط الواقف، أو تحقق الشرط الفاسخ، وجب أن يترتب على ذلك زوال العقد بأثر رجعي فكيف يمكن مع هذا القول إلزام من عدل برد ضعف العربون إن كان هو الذي قبضه، وإلزام من قدم العربون بتركه إن كان هو الذي عدل^(٢).

(١) من هذا الرأى: د. عبد المنعم البداروى - فقرة ١٠٦.

(٢) د. سليمان مرقس - ص ٧٢.

الفصل الثانى

المبيع

الفصل الثانى

المبيع

يمثل المبيع محل التزام البائع، ذلك أن عقد البيع ينشئ التزامات في جانب البائع محلها هو المبيع، وينشئ التزامات مقابلة في جانب المشتري محلها الرئيسى هو الثمن.

والمبيع هو الحق المالى الذي يرد عليه البيع أياً كان طبيعته أى سواء كان حقاً عينياً كحق الملكية وهو الغالب، أم كان حقاً شخصياً أو ذهنياً، فمحل التزام البائع هو الحق المالى الذي يراد نقله، وهو التزام بالقيام بعمل، وأن الشيء محل الحق هو المبيع^(١).

شروط المبيع:

ووفقاً للقواعد العامة، فإنه يشترط في المبيع ما يشترط في محل العقد بصفة عامة، وذلك وفقاً لما تقضى به المواد (١٣١ ١٣٥) مدنى، وهذه الشروط هى:

أولاً: أن يكون المبيع موجوداً أو قابلاً للوجود.

ثانياً: أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين.

ثالثاً: أن يكون قابلاً للتعامل فيه.

رابعاً: أن يكون مملوكاً للبائع.

ونخصص لكل شرط منها بحثاً:

(١) راجع: د. منصور مصطفى منصور - فقرة ٢٠.

المبحث الأول

كون المبيع موجوداً أو قابلاً للوجود

والقواعد العامة في نظرية العقد تقضى بأن يكون محل الالتزام ممكناً أو غير مستحيل، وذلك وفقاً لما تقضى به المادة (١٣٢) مدنى، : "إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً"، والمراد بالاستحالة هنا هي الاستحالة المطلقة، وليست النسبية فهذه ليس من شأنها بطلان العقد^(١).

فإذا كان محل العقد غير موجود في الحال، ولا يقبل الوجود في المستقبل، كان ورود العقد عليه باطلاً، وحتى يكون المبيع موجوداً فإنه يتعين:

أولاً: وجود المبيع:

بمعنى أن يكون موجوداً وقت العقد أو قابلاً للوجود، وتختلف الوجود بترتب عليه بطلان العقد لاستحالة المحل، كمن باع شيئاً على أنه موجود ثم تبين عدم وجوده، ومثل تلك الحالة ما لو كان المحل موجوداً بالفعل ثم هلك قبل البيع، ذلك بالنسبة للأعيان أى الأشياء المعينة بذاتها، أما المثليات فيكفى فيها أن يكون المثل موجوداً عند تنفيذ العقد لا وقت الانعقاد، لأنها يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء، ومن ثم فهي لا تهلك معنى.

(١) د. محمد على عمران - فقرة ٣٦.

ثانياً: قابلية المبيع للوجود:

وقد تتجه إرادة المتعاقدين إلى التعاقد على شيء مستقبل وفي هذه الحالة يكفي أن يكون هذا الشيء ممكن الوجود أو قابلاً له، وقد نصت المادة (١/١٣١) مدنى، على أنه: "يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً".

ومن أمثلة ذلك بيع الشقق قبلها تشطيبها، وبيع المحاصيل قبل حصادها، وبيع حمل الماشية قبل ولادتها^(١).

والفقه الإسلامى لا يقر بيع المعدوم، لقول النبى - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبع ما ليس عندك"، وبيع المعدوم فيه غدر، وقد نهى النبى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، ولم يستثن من ذلك إلا ما ورد النص باستحسانه، كما فى بيع السلم، وكما فى الإجارة، وكما فى الاستصناع، والجمالة^(٢).

وبيع الأشياء المستقبلية يتضمن قدراً من المجازفة، ولكن قدر المجازفة يختلف باختلاف صور هذا البيع، حيث إن إرادة المتعاقدين قد تتجه إلى أن يلتزم المشتري بدفع الثمن، بصرف النظر عن وجود المبيع مستقبلاً، أو عدم وجوده، وبصرف النظر عن كميته، فيما لو وجد مستقبلاً، وذلك مثل بيع الصياد ضريبة الشبكة، فهنا يكون العقد صحيحاً باتاً، ويجب على المشتري أداء الثمن مهما كانت النتيجة، وجد المبيع أو لو يوجد، وإذا وجد فبأى قدر وهذا العقد يسمى

(١) د. منصور مصطفى منصور - فقرة ٢٣.

(٢) فى هذا المعنى: د. عبد الرزاق حسن فرج - ص ٩٥.

عقد غرر يجيزه القانون^(١)، وتحترمه الشريعة الإسلامية، لأن محله على خطر الوجود والعدم فيقع باطلاً للغرر المنهى عنه شرعاً. وقد تتجه الإرادة إلى عدم المجازفة لا في وجود المبيع ولا في كميته كمن يشتري محصول القمح الذي سينتج من أرض معينة بسعر الإردب عشرة جنيهات مصرية مثلاً، وقد تكون المجازفة مقصورة على الكمية كما لو بيع القمح في المثال السابق بسعر إجمالي محدود بصرف النظر عما ينتج من الأرض المعينة من القمح، ويتجه الفقه إلى اعتبار البيع في الصورتين السابقتين معلقاً على شرط واقف هو وجود المبيع^(٢).

حظر بيع الحق في التركة المستقبلية:

ولئن كان الأصل هو جواز بيع الأشياء المستقبلية في القانون المدني المصري، إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء، حيث تقضى المادة (٢/١٣١) مدنى، على أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه، إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون ومفاد ذلك أن البيع الذي يرد على التركة المستقبلية يكون باطلاً سواء أكان البيع واقعاً على التركة في مجموعها، أم في جزء منها، أم في مال معين بصفة كونه داخلاً ضمن أموال التركة، وتحريم التعامل في التركة المستقبلية يشمل البيع وغيره من ضروب التعامل، وبطلان التصرف هنا مطلق يحق لكل ذي مصلحة أن يتمسك به حتى المشتري، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها^(٣).

(١) د. خميس خضر - فقرة ٤٩.

(٢) د. منصور مصطفى منصور - فقرة ٢٤.

(٣) د. عبد الفتاح عبد الباقي - السابق، د. جميل الشرقاوى - فقرة ٣٨.

المبحث الثانى

كون المبيع معيناً أو قابلاً للتعين

تقضى القواعد العامة لنظرية الالتزام أن يكون محل الالتزام معيناً أو قابلاً للتعين وهذه المبادئ هى التى تحكم تعيين المبيع أو قابليته للتعين.

وقد نصت المادة (١٣٣) مدنى، على أنه: "١- إذا لم يكن محل الالتزام معيناً بذاته، وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً. ٢- ويكفى أن يكون المحل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره، وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أى ظرف آخر، التزم المدين بأن يسلم شيئاً م نصنف متوسط".

ويبدو من هذا النص، أن تعيين المبيع يختلف باختلاف الأحوال فإذا كان المبيع معيناً بالذات كالمنقول، وجب ذكر صفاته وخصائصه المميزة، وإذا كان عقاراً وجب ذكر ما يميزه من المساحات والحدود والموقع، وإذا كان منزلاً وجب بالإضافة إلى ما سبق بيان عدد طوابقه وموقعه.

أما إذا كان المبيع معيناً بالنوع وهو المثليات التى يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء، فإنه يجب أن يبين نوع المبيع ومقداره بالعدد أو الوزن أو الكيل، أو المقاس، فإذا لم يعين المقدار، يجب أن يتضمن

العقد ما يمكن من تعيينه مستقبلاً، بمعنى أن يكون قابلاً للتعيين، وإذا لم يحدد المقدار فيما سيوجد مستقبلاً، فمن اللازم أن يتضمن العقد الأسس التي يتحدد بمقتضاها، ويجب كذلك أن تحدد درجة الجودة، فإذا لم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من ظرف آخر اعتبر المبيع من الصنف المتوسط وذلك وفقاً لما تقضى به المادة (٢/١٣٣) مدنى^(١).

وقد يعين المبيع عن طريق البيع بالعينة، كما سبق أن رأينا.

(١) الوسيط للسنهورى - فقرة ١١٧.

المبحث الثالث

قابلية الشيء للتعامل فيه

وتقتضى المبادئ العامة لنظرية الالتزام بأن يكون محل الالتزام شيئاً يجوز التعامل فيه، وتطبيقاً لذلك تنص المادة (٨١) مدنى، على أنه: "١- كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية. ٢- والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها، هى التى لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، وأما الخارجة بحكم القانون فهى التى لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية".

كما تنص المادة (١٣٥) مدنى، على أنه: "إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام والآداب، كان العقد باطلاً".

ويستفاد من هذين النصين، أن الشيء محل التعاقد يجب أن يكون قابلاً للتعامل فيه، وأن يكون التعامل فيه مشروعاً، أي غير ممنوع لا بنص القانون ولا لمخالفته للنظام العام والآداب، مع ملاحظة أن القانون حين ينص على منع التعامل في شيء، فإن ذلك يكون مبنياً على اعتبارات ترجع أيضاً إلى النظام العام والآداب^(١).

وبناء على ذلك لا يجوز بيع المال العام، ولا يجوز بيع المخدرات إلا لأغراض طبية أو لأغراض البحث العلمى.

(١) د. خميس خضر - ص ٨٨.

ولا يجوز أن يبيع النائب صوته لمرشح، أو أن يبيع موظف عام وظيفته، أو أن يتنازل شخص عن جنسيته أو اسمه أو البنوة أو الأبوة، ولا يجوز بيع منزل بقصد إدارته للدعارة أو القمار^(١).

(١) الوسيط للسنهورى - فقرة ١٤٨.

المبحث الرابع

أن يكون المبيع مملوكاً للبائع

(أحكام بيع ملك الغير)

ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكاً للبائع، فإن كان غير مملوك له، فالأصل أن البيع يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لعدم وجود المحل، حيث أن البائع قد باع ما لا يملك، وبالتالي يكون محل الالتزام قد فات، بالإضافة إلى فوات السبب، لأن سبب التزام المشتري بدفع الثمن، قيام البائع بنقل ملكية المبيع، فإذا لم يقوم البائع بنقل الملكية لا يكون لالتزام المشتري بدفع الثمن سبب.

بيد أن المشرع قد خرج على هذا الأصل في عقد البيع، وأجاز أن يكون المبيع محتمل الوجود في المستقبل، ومن ثم أجاز بيع الأموال المستقبلية، وفقاً لما تقضى به المادة (١/١٣١) مدنى مصرى، من أنه يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً، ويترتب على ذلك أن يكون من الجائز أيضاً - طبقاً لتلك القواعد العامة - أن يلتزم شخص بنقل ملكية شيء مملوك لغيره ويكون بيع ملك الغير بيعاً صحيحاً لذلك، إلا أن المشرع قد خالف كل ذلك وقرر له حكماً خاصاً وهو البطلان النسبي، لأن التزام البائع بنقل الملكية بالنظر إلى الظروف الموضوعية التى تم فيها إبرام العقد^(١)، ولا يكفى لصحة العقد

(١) د. سمير تناغو - عقد البيع - ص ٣٨٣.

الوارد على مستقبل، أن يكون محله ممكناً في ذاته، ولو كان بعيد الاحتمال، بل يجب ان يكون محتملاً بدرجة كافية تتفق مع عقود المعاوضة ومع لظروف الموضوعية التي تتم فيها هذه العقود، فالاستحالة النسبية كالاستحالة المطلقة تؤدي إلى تخلف شرط من شروط المحل.

وبيع ملك الغير هو صورة من صور التصرفات الواردة على محل مستقل غير مستحيل استحالة مطلقة، إلا أنه غير محتمل الوجود بالنظر للظروف الموضوعية الملازمة إبرام العقد، ويكون الجزاء المناسب لهذا العقد هو البطلان النسبي، ويزول هذا البطلان إذا أجاز المشتري العقد، أو أقر المالك الحقيقي البيع فأصبح البيع نافذاً يفي حقه وصحياً في حق المشتري، أو تملك البائع المبيع بعد العقد، حيث يصبح في هذه الحالة قادراً على نقل ملكيته إلى المشتري، وهو نفس السبب الذي يتحقق إذا أقر المالك البيع^(١).

المقصود ببيع ملك الغير وشروطه:

ويقصد ببيع ملك الغير: البيع الذي يكون المبيع فيه معيناً بالذات، ولا يكون مملوكاً لأى من طرفى عقد البيع، ويبدو من هذا التعريف أنه يجب أن تتوافر ثلاثة شروط حتى نكون بصدد بيع ملك الغير، وهى:

(١) د. سمير تناغو - ص ٣٨٦.

أولاً: أن يكون المبيع معيناً بالذات:

يشترط في بيع ملك الغير، أن يكون المبيع معيناً بالذات، وليس معيناً بالنوع، لأنه إذا كان معيناً بالنوع فقط، فلا يقال بأنه مملوك للبائع، أو غير مملوك له، لأن الحق فيه يتعين بالمثل حتى ولو كان البائع غير مالك وقت العقد لأي مقدار من نوع ما التزم ببيعه، فالشيء المعين بالنوع لا يمكن وصفه بأنه مملوك أو غير مملوك^(١).

ثانياً: أن يكون المبيع غير مملوك للبائع ولا المشتري:

فلا يكفي لأعمال أحكام بيع ملك الغير التي يجعل العقد قابلاً للإبطال لمصلحة المشتري، أن يكون المبيع غير مملوك للبائع، بل يلزم فوق ذلك أن يكون المبيع غير مملوك للمشتري، إذ لو كان المبيع مملوكاً للمشتري فإن العقد في تلك الحالة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لاستحالة الحل استحالة مطلقة، لأنه يستحيل على الكافة نقل ملكية شيء إلى من هو مالك له فعلاً^(٢).

ثالثاً: أن يكون العقد بيعاً:

ويشترط بداهة أن يكون العقد بيعاً، فإذا تعهد شخص لآخر، بأن يجعل المالك يبيع له الشيء محل التعاقد، فإن هذا يعتبر تعهداً عن الغير، وليس بيعاً، فمحل التزام المتعهد ليس نقل الملكية بل القيام بعمل، هو الحصول على رضا المالك بأن يبيع الشيء.

(١) د. خميس خضر - العقود المدنية الكبيرة - ص ٢٩٥.

(٢) د. خميس خضر - السابق.

النصوص القانونية التي تنظم بيع ملك الغير:

وقد نظم المشرع بيع ملك الغير في المواد من (٤٦٦) إلى (٤٦٨) من التقنين المدني الجديد، فنصت المادة (٤٦٦) على أنه: "١- إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع، ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار سجل العقد أو لم يسجل. ٢- وفي كل الأحوال لا يسرى هذا البيع في حق المالك للعين المباعة ولو أجاز للمشتري العقد"

وتنص المادة (٤٦٧) على أنه: "إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري، وكذلك ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد".

وتنص المادة (٤٦٨) على أنه: "إذا حكم للمشتري بإبطال البيع، وكان يجهل أن المبيع مملوك للبائع، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية".

ويبدو من هذه النصوص، أنها تنظم بيع ملك الغير فيما بين المتعاقدين، وتبين حكمه بالنسبة للمالك الحقيقي، وبيانها لمسائل هذين الموضوعين يقتضى تأصيل أحكامه، وسوف نبين ذلك، على أنخصص لكل موضوع مطلباً:

المطلب الأول

حكم بيع ملك الغير فيما بين المتعاقدين

ويبدو من استعراض النصوص التى تبين حكم بيع ملك الغير أن المشتري يكون له حق طلب الإبطال، كما يكون له الحق إذا كان حسن النية، أن يطلب التعويض، ونبين ذلك:
أولاً: حق المشتري في طلب الإبطال:

يبين من نص المادة (٤٦٦) مدنى، أن المشتري هو الذي له حق طلب إبطال البيع إذا وقع على مال الغير، لأنه هو الذي تقرر الإبطال لمصلحته، وهو يستطيع أن يتمسك بالإبطال بدعوى يرفعها طالباً ذلك، أو بطريق الدفع، فهو يستطيع أن يرفع دعوى أصلية، حتى ولو لم يتعرض له المالك الحقيقى في المبيع، طالباً استرداد ما دفع من ثمن ما دام أن هذا الثمن قد دفع لشخص لا يستحقه، والمشتري يستطيع ذلك حتى ولو كان عالماً وقت البيع أن المبيع غير مملوك للبائع، لأنه إنما رضى بالبيع اعتقاداً منه بأن البائع يستطيع أن يحصل على ملكية المبيع فينقلها إليه، فإذا تأكد أن البائع: ليس في استطاعته ذلك، فإن له أن يبادر برفع الدعوى دون أن ينتظر حتى يتعرض له الملك الحقيقى في المبيع بأن يطلب إبطال البيع واسترداد الثمن الذي دفع للبائع^(١).

(١) د. محمد السعيد رشدى - السابق - ص ٢٠٠.

وللمشتري أن يتمسك بإبطال البيع قبل أن يتعرض له المالك الحقيقي، ويلاحظ أن ثبوت حق المشتري في طلب إبطال البيع لا يخل بحقه في طلب فسخ العقد، فله أن يستعمله أو لا يستعمله، وإذا تعرض له المالك الحقيقي، فله فضلاً عن حقه في الإبطال والفسخ أن يرجع بضمان الاستحقاق.

ويثبت حق الإبطال للمشتري حتى ولو كان سيء النية وقت التعاقد بأن كان يعلم أن المبيع مملوك للغير، كما يثبت له ولو كان البائع حسن النية، جهل أنه يبيع ملك غيره، ومما يدل على ذلك نص المادة (٤٦٨) مدني، الذي يخول المشتري حسن النية حق طلب التعويض ولو كان البائع حسن النية فتقييد حق المشتري في طلب التعويض بأن يكون حسن النية، يفيد حقه في طلب الإبطال ولو كان سيء النية، وبذلك النص على حق المشتري في طلب التعويض ولو كان البائع حسن النية، أن الحق في الإبطال يثبت للمشتري سواء كان البائع سيء النية أو حسن النية^(١).

وليس للبائع الحق في أن يطلب إبطال البيع، لأن الإبطال لم يتقرر لمصلحته بل لمصلحة المشتري.

ثانياً: حق المشتري حسن النية في المطالبة بالتعويض:

وإذا كان المشتري حسن النية، وحكم له بالإبطال بناء على طلبه، فإن يكون له أن يطالب بالتعويض مع حقه في الإبطال، ويكون

(١) د. خميس خضر - السابق.

للمشتري هذا الحق إذا كان حسن النية، أى لا يعلم وقت البيع أن المبيع غير مملوك للبائع، حتى ولو كان الأخير حسن النية، أى لا يعلم هو الآخر أن المبيع غير مملوك له فإذا كان المشتري سيء النية، فإنه لا يكون له حقاً في طلب التعويض، وإنما يكون له فقط مجرد الحق في طلب إبطال البيع، بيد أنه إذا لم يكن له الحق في طلب التعويض - حالته - فإنه يكون له أن يطلب ما دفع من الثمن نتيجة الحكم بالبطلان.

أساس حق المشتري في التعويض:

وقد اختلف الفقهاء حول الأساس الذي تبنى عليه مسئولية البائع عن التعويض، فذهب رأى إلى أن هذا الحكم تطبيق تشريعى لقاعدة الخطأ عند تكوين العقد بينما ذهب رأى آخر - هو الراجح في نظرنا - إلى أن أساس التزام البائع بالتعويض هو المسئولية التقصيرية، لأن بيع الشخص لشيء غير مملوك له يعتبر خطأ من البائع، لا سيما إذا كان سيء النية، لأنه في هذه الحالة يكون مغتصباً^(١).

سقوط حق المشتري في طلب الإبطال:

يحق للمشتري أن يطلب إبطال البيع في وقت إنعقاده، ولكن

حقه هذا يسقط بأحد الأسباب الآتية:

أولاً: إقرار المالك الحقيقي للعقد:

تنص المادة (١/٤٦٧) مدنى، على أنه: "إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه، وانقلب صحيحاً في حق المشتري"، ومفاد ذلك أن

(١) من هذا رأى: د. خميس خضر - السابق.

المشتري لا يستطيع بعد إقرار المالك الحقيقي للعقد أن يطلب إبطاله، ذلك أن المالك يصبح بإقراره للبيع ملتزماً بالتزامات البائع، ويحول المانع الذي كان يحول دون انتقال الملكية إلى المشتري والرأى السائد في الفقه: أن إقرار المالك الحقيقي الذي يجرد المشتري من طلب الإبطال، هو الذي يصدر قبل أن يرفع المشتري دعوى الإبطال، أما إذا صدر الإقرار بعد ذلك، فلا يحول دون الحكم بالإبطال على أساس أن المحكمة تنظر الدعوى بالحالة التي كانت عليها وقت رفعها.

ثانياً: أن يملك البائع المبيع بعد العقد:

كما يسقط حق المشتري في طلب إبطال البيع، إذا تملك البائع المبيع بعد صدور العقد، أيّاً كان سبب التملك، إذ أنه بصيرورة البائع مالكاً يزول المانع الذي كان يحول دون انتقال الملكية إلى المشتري، والتملك الذي يحول دون انتقال الملكية إلى المشتري، والتملك الذي يحول دون طلب الإبطال، يلزم أن يكون قبل رفع دعوى الإبطال، وفقاً للرأى السائد، كما هو الحال في قرار المالك الحقيقي للبيع^(١).

ثالثاً: إجازة المشتري للعقد:

إذا أجاز المشتري العقد، فإن حقه في طلب الإبطال يسقط، ذلك أ حق الإبطال مقرر لمصلحة المشتري، ولما كان الأمر كذلك، فإنه يكون له التنازل عنه صراحة أو ضمناً، بعد علمه بعدم ملكية

(١) د. محمد السعيد رشدي - ص ٢٠٢.

البائع للمبيع، فإجازة المشتري للعقد، تزيل قابليته للإبطال وتحوله إلى عقد صحيح فيما بين المتعاقدين.

رابعاً: التقادم

ويسقط حق المشتري في طلب إبطال البيع بالتقادم وفقاً للقواعد العامة، وبمقتضى ذلك تسقط دعوى طلب إبطال البيع بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت علم المشتري بعدم ملكية البائع، وتسقط في جميع الأحوال بإنقضاء خمس عشرة سنة من وقت العقد، وقد اتجه الرأي الغالب في الفقه إلى ذلك، نظراً لأن المشرع لم ينص على أحكام خاصة بالتقادم في شأن دعوى إبطال بيع ملك الغير^(١).

ويلاحظ أن سقوط حق المشتري في طلب العقد بالإجازة أو بالتقادم لا أثر به على حقوق المالك، لأن البيع غير سار في حقه على أى الأحوال.

(١) د. سمير تناغو - ص ٣٦٨ وما بعدها.

المطلب الثنى

حكم بيع ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقى

إذا تم بيع ملك الغير، فإنه لا يسرى في حق المالك إلا إذا أقره، فإذا أقره فإن هذا الإقرار تترتب عليه آثار هامة ونبين ذلك: أولاً: لا يسرى بيع ملك الغير في حق المالك إلا إذا أقره:

يعتبر المالك الحقيقى - في بيع ملك الغير - أجنبياً بالنسبة للبيع الصادر من سواه، ومن ثم فإن هذا البيع لا يسرى في حقه، سواء حكم بإبطاله أم لم يحكم، وسواء ظل حق المشتري في طلب إبطاله قائماً أم سقط بإجازة المشتري للعقد أو للتقادم، ويترتب على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع إلى المشتري، فإن المالك الحقيقى يستطيع أن يرجع على المشتري بدعوى الاستحقاق، ويرجع المشتري من جانبه على البائع، بضمان الاستحقاق، أو بدعوى الفسخ، أو بدعوى الإبطال ومع ذلك يستطيع المالك الحقيقى أن يقر البيع فيسرى في حقه، طبقاً للمادة (١/٤٦٧) مدنى^(١).

ثانياً: أثر إقرار المالك لبيع ملك الغير:

إذا أقر المالك الحقيقى البيع، فإن الأمر يختلف هنا عن الوضع السابق، إذ تنص المادة (١/٤٦٧) مدنى، على أنه: "إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري"،

(١) د. خميس خضر - السابق - ص ٣٠٢.

ومعنى ذلك أن إقرار المالك الحقيقى للبيع يجعله صحيحاً وإذا كان العقد يسرى في حق المالك من وقت الإقرار، فإن مما يترتب على ذلك أن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا من تاريخ هذا الإقرار، أو من تاريخ تسجيله إذا كان المبيع عقاراً، ومعنى ذلك أن الإقرار لا يؤثر على الحقوق التى يكون المالك قد قررهما للغير قبل صدور الإقرار، فلو أن المالك كان قد رهن العقار المبيع، أو رتب عليه حق ارتفاق قبل أن يقر البيع الصادر من لغير، وكان الدائن المرتهن أو مكتسب حق الارتفاق قد شهر قبل تسجيل الإقرار انتقلت الملكية إلى المشتري محملة بالرهن أو الارتفاق^(١).

ويترتب على إقرار المالك للبيع الصادر من غيره، حلوله محل البائع من وقت صدور الإقرار في جميع حقوقه والتزاماته في العقد، وهذا ما يتجه إليه الرأى الغالب في الفقه، فتقوم العلاقة بينه وبين المشتري مباشرة، وتبرأ ذمة البائع من الالتزامات الناشئة عن البيع، ولهذا يجوز للمالك أن يطالب المشتري بالثمن، وأن يطالب البائع بما قد قبضه منه، وللمشتري مطالبة المالك المقر بالتسليم، وله الرجوع عليه بضمان التعرض والاستحقاق، وضمان العيوب الخفية^(٢).

(١) د. خميس خضر - السابق.

(٢) في هذا المعنى: د. عبد المنعم البدرأوى - السابق - فقرة ٤٠١.

المطلب الثالث

تأصيل أحكام بيع ملك الغير

اختلفت آراء الفقهاء حول أساس بطلان بيع ملك الغير، ويمكن إرجاع هذا الخلاف إلى الأقوال الآتية:
أولاً: بيع ملك الغير ليس باطلاً:

ذهب جانب من الفقه إلى أن بيع ملك الغير ليس بيعاً باطلاً، وإنما هو عقد صحيح سرى عليه الفسخ، وترجع قابليته للفسخ إلى أن البائع لم يتم بتنفيذ التزامه بنقل الملكية إلى المشتري، فيكون لهذا الأخير أن يطلب فسخ البيع، وقد بالغ بعض الفقهاء فقال: إن بيع ملك الغير بيع صحيح طبقاً للقواعد العامة، وهذا ما يقول به البعض فعلاً، حتى إن بعض كبار الفقهاء، قد وصف النص الذي يقرر بطلان بيع ملك الغير في القانون المدني الفرنسي، بأنه لغو تشريعي، ووصفه البعض الآخر بأنه من أشد النصوص غموضاً في التقنين.
ويؤخذ على هذا الرأي، أنه يخالف حكم القانون الذي نص صراحة على البطلان النسبي، ولو أخذنا بنظرته الفسخ لكان نص بيع ملك الغير تزيد^(١).

ثانياً بيع ملك الغير باطل بطلاناً مطلقاً:

وذهب رأي آخر في الفقه إلى أن بيع ملك الغير باطل بطلاناً مطلقاً، وذلك لتخلف المحل والسبب، لأن سبب التزام المشتري بدفع

(١) في هذا المعنى: د. إسماعيل غانم - السابق - ص ٢١ وما بعدها.

التمن هو التزام البائع بنقل الملكية، فإذا لم يتم بنقل ملكية المبيع لا يكون لالتزام المشتري سبب، وفي الوقت ذاته يكون التزام البائع بدون محل^(١).

ويؤخذ على هذا الرأي أنه قد تجاهل أن بيع ملك الغير وإن كان لا يؤدي إلى نقل الملكية، إلا أن البائع يلتزم بنقلها، فإذا لم يتم بذلك فإنه يكون في مركز المتعاقد الذي تخلف عن تنفيذ التزام رتبة على عاتقه عقد صحيح، وليس في مركز متعاقد غير ملتزم لأن العقد باطل، كما لا ينبغي أن يقال إنه لطالما أن الالتزام لم ينفذ، فإنه يكون بدون محل وأن الالتزام المقابل له بدون سبب، والقول بالبطلان المطلق لتخلف السبب والمحل على النحو السابق يتعارض مع ما يترتب من آثار على هذا البيع، ومنطقه يؤدي إلى جعل طلب البطلان لكل ذي شأن مع أن المادة (٤٦٦) مدني، لم تعط هذا الحق إلا للمشتري^(٢).

ثالثاً: أساس البطلان هو الغلط الذي يقع فيه المشتري:

وثمة رأي آخر في الفقه يرى أن المشتري قد اعتبر ملكية البائع للمبيع صفة جوهرية على نحو دفعه للتعاقد، ومن ثم كان هذا الغلط عيباً في الرضا، كما أن المشتري قد وقع في الغلط بالنسبة لشخص

(١) د. محمد السعيد رشدي - السابق - ص ٢٠٦ وما بعدها.

(٢) د. توفيق فرج - عقد البيع والمقايضة - فقرة ٧٥.

البائع، حيث توهم أنه المالك، ثم فوجئ بأنه ليس كذلك، فما يؤثر في الرضا^(١) فالمشتري قد وقع في غلط يتعلق بشخص البائع أو المبيع. ويؤخذ على هذا الرأي أنه يؤدي إلى أن البيع ملك الغير لا يكون قابلاً للإبطال إلا إذا كان المشتري حسن النية، أى يجهل وقت العقد أن البائع غير مالك، في حين أن للمشتري أن يطلب إبطال العقد، ولو كان قد أقدم على العقد، وهو يعلم أن البائع غير مالك، كما لا يجوز أن نتجاهل أن القانون قد نص هنا - وفي تلك الحالة بالذات - على أن البطلان نسبي، ولمصلحة المشتري وحده، وهو بطلان لا يستند إلى أى أساس من القواعد العامة، وإنما هو مستثنى منها بالنص، وفي هذا الصدد تقرر المذكرة الإيضاحية: "أن البطلان هذا خاص بإنشاء النص"^(٢)، وهو ما يترجح لدى جمهور الفقهاء.

(١) د. محمد السعيد رشدى - ص ٢٠٧.

(٢) مجموعة الأعمال التحضيرية - ج ٤ - ص ١٩٢.

الفصل الثالث

الضمن في عقد البيع

الفصل الثالث

الثمن في عقد البيع

يعتبر الثمن ركناً رئيسياً من أركان البيع لا ينعقد بدونه وهو محل التزام المشتري الأساسى، وهو الذي يميز البيع عن غيره من العقود الأخرى، كالهبة التى تقوم على إعطاء المال بدون مقابل، والثمن يجب أن تتوافر فيه شروط، وهى:

أولاً: أن يكون الثمن من النقود:

يختص الثمن في البيع بأنه نقدي، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة (٤١٨) مدنى، بقولها: "البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي"، ومن ثم يشترط في الثمن أن يكون مبلغاً من النقود، فلو لم يكن الثمن نقوداً بأن كان عيناً كقطعة أرض أو كمية من الحبوب، كان العقد مقايضة. وإذا كان بعض الثمن نقوداً والبعض الآخر من غير النقود، يكون تكيف العقد خاضعاً للعنصر الغالب، فلو غلب النقد يكون العقد بيعاً، ولو غلبت العيم من غير النقود يكون مقايضة^(١).

ثانياً: أن يكون الثمن مقدراً أو قابلاً للتقدير:

الأصل أن يتم تقدير الثمن بمعرفة المتعاقدين صراحة عند إبرام عقد البيع، وقد يتحدد الثمن ضمناً، إذا اتضح من الظروف أن نية

(١) الوسيط للسهنورى - فقرة ٢٠٤.

المتعاقدين قد انصرفت إلى اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه عليه التعامل بينهما، وقد نصت على هذا المادة (٤٢٤) مدنى، بقولها: "إذا لم يحدد المتعقدان ثمناً للمبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف، أن المتعاقدين قد نويّا اعتماد السعر المتداول في التجارة، أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما".

ولا يشترط أن يكون الثمن محدداً في عقد البيع، وإنما يكفي أن يبين فيه الأسس التى تجعله قابلاً للتحديد فيما بعد، وقد نصت المادة (٤٢٣) مدنى، على ذلك بقولها: "يجوز أن يقتصر الثمن على بيان الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد"، ومن ثم يجوز أن يحسب الثمن على أساس التكلفة، أو بسعر السوق أو أن يتفقا على البيع الذى اشترى به البائع، أو على أساس التسعيرة الرسمية في تاريخ البيع أو في تاريخ التسليم^(١)، ويجب أن تكون الأسس التى يتم على أساسها تحديد الثمن مما ينأى بالعقد عن إثارة النزاع مستقبلاً.

ومن ثم لا يكفي أن يكون الاتفاق على البيع بالثمن المناسب، أو الثمن العادل، كما لا يجوز الاتفاق على أن يكون تحديد الثمن لمحض إرادة أحد المتعاقدين، لأنه سيغبن الطرف الآخر.

وقد يقدر الثمن بواسطة أجنبي عن العقد يتفقان عليه فيما بعد، كما قد يتعهد المتعقدان إلى القاضى بأمر تعيينه، على أنه إذا تم

(١) د. منصور مصطفى منصور - فقرة ٢٩.

الاتفاق على أن يقوم بتحديد الثمن أجنبي عن العقد يتفقان عليه فيما بعد، فإن البيع لا ينعقد إلا عند حصول هذا الاتفاق اللاحق أن يجبره عليه، وللقاضى أن يستعين في ذلك بالغرامة التهديدية، وإذا تعذر الاتفاق كان للمتعاقد المضرور أن يطالب بالتعويض، على أساس المسؤولية العقدية الناشئة عن عقد غير مسمى قد تم بينهما يلتزم كل منهما بموجبه، أن يعمل كل ما يلزم لتعيين مفوض^(١).

ويلتزم المتعاقدان بالثمن الذي يحدده المفوض، ولكن يجوز لمن يتضرر من هذا التحديد أن يطعن فيه، إذا تم نتجية تواطؤ مع الطرف الآخر، كما في بيع النجش في الفقه الإسلامي أو إذا خرج المفوض عن الحدود المرسومة له في الاتفاق، أو إذا وقع المفوض في خطأ جسيم، نتيجة لغلط في صفة جوهرية للمبيع جعلته يقدره بثمن غير مناسب^(٢).

القيود الواردة على حرية المتعاقدين في تحديد الثمن:

والأصل أن للمتعاقدين حرية تحديد الثمن من ناحية نوع

النقود ومقدارها، ولكن هذا الأصل يرد على قيدان:

الأول: السعر الإلزامي للنقود الورقية:

وبمقتضى هذا الشرط لا يجوز اتفاق المتعاقدين على أن يكون

تحديد الثمن الذهب في المعاملات الداخلية وذلك وفقاً للأمر العالى

(١) د. عبد الرازق حسن فرج - ص ١١٨.

(٢) د. عبد المنعم البدرأوى - فقرة ١٤٠.

الصادر في ١٩١٤/٩/٢، والذي فرض سعراً إلزامياً للعملة الورقية التي يصدرها البنك الأهلي، ونص على بطلان شرط الذهب إذا كان قد اتفق على الدفع بالذهب، أو بما يعادل قيمة الذهب وقت الوفاء، وكذلك الأمر بالنسبة للمعاملات الخارجية (بناء على التفسير بالمرسوم بقانون ٣٥ لسنة ١٩٣٥) والذي نص على بطلان شرط الدفع بالذهب في المعاملات الخارجية.

فيكون للمشتري أن يوفى بالثمن نقوداً ورقية مصرية على أساس قيمة الذهب المشروط في العقد لا وقت الوفاء، ولا يبطل عقد البيع كله نتيجة لبطلان شرط الذهب إلا إذا اتضح أن هذا الشرط كان هو الدافع للتعاقد^(١).

الثاني: السعر الإلجباري لبعض السلع:

إذا فرض المشرع سعراً إلزامياً لبعض السلع فلا يجوز البيع بسعر يزيد عنه، وغالباً ما يقترن مثل هذا الفرض إجراء جنائي على من يخالفه، وحكم العقد مع تلك المخالفة عدم البطلان مراعاة للمشتري الذي قد يكون في حاجة إلى تلك السلعة، ومن ثم يرجح الفقه أن يقتصر البطلان على ما يجاوز السعر الجبري للسلعة، فليلزم البائع برد ما قبضه من الزيادة ويحتفظ المشتري بالسلعة المباعة^(٢).

(١) د. إسماعيل غانم - فقرة ٥٥.

(٢) د. محمد على عمران - فقرة ٥٣.

ثالثاً: أن يكون الثمن جدياً:

والثمن الجدي: هو الذي تتجه إرادة المتعاقدين إلى إلزام المشتري بدفعه على أساس أنه مقابل حقيقى لنقل ملكية المبيع إليه، ومن ثم لا يكون الثمن جدياً، إذا كان صورياً، أو تافهاً أو بخساً، وذلك ما نوضحه فيما يلي:

(١) الثمن الصورى:

ويكون الثمن صورياً إذا ذكر في العقد أن المشتري قد التزم بدفعه استيفاء للشكل فقط، دون أن تتجه إرادة المتعاقدين إلى إلزام المشتري بدفعه، والصورية قد تكون مطلقة إذا اتفقا على ألا يدفع المشتري من الثمن أى شيء، وقد تكون نسبية إذا خالف الثمن المذكور في العقد الثمن الحقيقى المتفق عليه زيادة أو نقصاً، وفي هذه الحالة ينعقد البيع بالثمن الحقيقى لا بالثمن الصورى وعلى من يدعى الصورية أن يثبتها، فلو كان طرفاً في العقد تعين عليه إثبات الصورية بالكتابة، وإذا كان من الغير جاز له إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات.

وإذا كان الثمن صورياً لا يكون العقد بيعاً، وإنما يكون عقد هبة لا تتم إلا بورقة رسمية^(١).

(١) وفي هذا حكم النقض المدنى بتاريخ ١٩٣٨/٦/٩ - مجلة المحاماة ١٩ - ٣٥٦ - ١٥٣.

(٢) الثمن التافه:

وهو الثمن الذي يصل من القلة إلى درجة لا تتناسب البتة مع قيمة المبيع، مثل أن يبيع سيارة تساوي مائة ألف جنيه بمبلغ مائة جنيه، والثمن التافه في حكم الثمن المعدوم، ومن ثم يكون البيع معه باطلاً باعتباره بيعاً.

ويذهب الفقه إلى أن الثمن التافه على النحو المذكور يعتبر معه العقد هبة مكشوفة لا تصح إلا بورقة رسمية، وفقاً لأحكام المادة (١/٤٨٨) مدنى.

(٣) الثمن البخس:

وأما الثمن البخس فإنه هو الذي يقل كثيراً عن قيمة المبيع، ولكنه لا ينزل إلى حد الثمن التافه الذي يعتبر ثمناً غير جدى، وغالباً ما يكون البائع قد قبله لظروف اضطرارية، أو لحاجته الماسة أو لعدم خبرته.

وهو على خلاف الثمن الصورى والثمن البخس، يعتبر ثمناً جدياً يكفى لانعقاد البيع.

والثمن البخس يعطى للبائع الحق في طلب إبطال العقد أو زيادة الثمن، أو نقص مقدار المبيع في حال الاستغلال مادة (١٢٩) مدنى، وقد يعطى للبائع الحق في طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل، كما في حالة بيع عقار ناقص الأهلية مادة (٤٢٥) مدنى.

الباب الثانى

آثار عقد البيع

الباب الثانى

آثار عقد البيع

إذا تم عقد البيع صحيحاً، فإنه ينتج الآثار التى تترتب عليه، وهذه الآثار تمثل التزامات تقع على عاتق كل من البائع والمشتري، وينبغى أن نعرض لبيان التزامات البائع في فصل أول، ثم تنهى ببيان التزامات المشتري في فصل ثانى.

الفصل الأول

التزامات البائع

الفصل الأول

التزامات البائع

يقع على عاتق البائع في عقد البيع ثلاثة التزامات، هي:

(١) الالتزام بنقل الملكية^(١):

وهذا الالتزام تظهر أهميته بصفة خاصة في نقل الملكية، ولهذا يطلق عليه الالتزام بنقل الملكية.

(٢) الالتزام بتسليم المبيع.

(٣) الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية، وسوف نخصص لكل واحد من هذه الالتزامات مبحثاً.

(١) أو الالتزام بنقل الحق في المبيع، كما يرى أستاذنا الدكتور عبد الرزاق حسن فرج - ص ١٢٧.

المبحث الأول

التزام البائع بنقل الملكية

يعتبر نقل الملكية هو جوهر البيع وغايته، ولا يتصور وجود عقد البيع إلا إذا ترتب عليه نقل الملكية في الحال أو في المآل، وقد عرض المشرع في التقنين المدني لنقل الملكية والحقوق العينية الأخرى في نصوص متفرقة في المواد (٢٠٤، ٢٠٧، ٤٢٨ إلى ٤٢٠)، والمواد (٩٣٢ إلى ٩٣٤).

والتزام البائع بنقل ملكية المبيع يقتضى منه القيام بالأعمال اللازمة التي يترتب عليها نقل المبيع إلى المشتري، وقد نصت على هذه المادة (٤٢٨) مدنى بقولها: "يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشتري، وأن يكف عن أى عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً".

وطبقاً لهذا النص فإن التزام البائع قد يكون:

إيجابياً: كقيامه بفرز الأشياء المثلثة المباعه، والعمل على التصديق على إمضائه، وتقديم المستندات اللازمة للتسجيل في حالة بيع العقار.

أو سلبياً: يتمثل في الكف عن أى عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق إلى المشتري مستحيلاً أو عسيراً كقيامه ببيع العقار مرة ثانية إلى مشتري ثان يسبق في تسجيل عقده، فيجعل انتقال الملكية إلى المشتري الأول مستحيلاً^(١).

(١) في هذا المعنى: د. جميل الشرقاوى - فقرة ٤٨.

وقد لا يقتضى نقل الحق المبيع قيام البائع بعمل ما، بل ينتقل الحق المبيع بالعقد ذاته، إذا كان المبيع حقاً عينياً وارداً على منقول معين بالذات مملوك للبائع مادة (٢٠٤) مدنى.

والتزام البائع بنقل الحق في المبيع يختلف في حالة العقار عنه في المنقول وذلك ما يجب بيانه في مطلبين:

المطلب الأول

نقل ملكية المنقول المعين بالذات

والقاعدة التى تحكم نقل الملكية فيه تقضى بانتقالها بمجرد تمام العقد، وذلك وفقاً لما تقضى به المادة (٢٠٤) مدنى، بقولها: "الالتزام بنقل الملكية، أو أى حق عينى آخر، ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل"، كما تنص المادة (٩٣٢) مدنى على أنه: "تنقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد، متى ورد على محل مملوك للمتصرف، طبقاً للمادة (٢٠٤) مدنى، وذلك مع مراعاة النصوص الآتية..".

ويبدو من هذين النصين أنه إذا كان المبيع منقولاً معيناً بالذات وتوافرت شروط معينة، فإن الملكية تنتقل إلى المشتري فوراً بمجرد تمام العقد وعقد البيع ذاته هو الذي ينقل الملكية، بعد أن ينشئ التزاماً بنقلها يتم تنفيذه فوراً بمجرد نشوئه إذا توافرت الشروط الآتية:

أولاً: أن يكون المبيع منقولاً معيناً بالذات:

وهذا الشرط مما يقتضيه الحال، لأن الحق العيني لا يمكن تصويره إلا على شيء معين بالذات، ولهذا كان من اللازم في الشيء المعين بالذات، ولهذا كان من اللازم في الشيء المعين بالنوع، لكي ينتقل الحق المبيع إلى المشتري أن يحصل الإفراز، فلو ورد البيع على مائة إردب من القمح غير معينة إلا بنوعها ومقدارها، كان عدم تعيين القمح المبيع بذاته مانعاً من انتقال ملكيته بمجرد عقد البيع، ولو نص في العقد صراحة على أن يصبح المشتري مالكاً القدر المبيع من وقت العقد.

إلا أنه إذا كان المبيع من القمح الموجود في مخزن معين، فهذا تنتقل ملكيته بمجرد العقد، لأنه يعتبر معيناً بالذات، ويسمى بيعاً جزافياً، ويتميز عن البيع العادي للمثلثات أن محله يتعين بظروف من الزمان والمكان تفرزه عن بقية جنسه وتحدده تحديداً ذاتياً^(١).

وقد نصت المادة (٤٢٩) مدنى، على أنه: "إذا كان البيع جزافياً انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنقل به في الشيء المعين بالذات".

ثانياً: أن يكون المبيع مملوكاً للبائع:

ويشترط أن يكون البائع مالكاً للحق المبيع، وهذا ما نص عليه المشرع في المادتين (٢٠٤ ، ٩٣٢) لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن

(١) د. سليمان مرقس - عقد البيع - الطبعة الرابعة - ص ٢٦١.

ثم فإن الشخص لا يستطيع أن ينقل إلى غيره حقوقاً أكثر من حقوقه على الشيء، ومن ثم لا يمكن للمشتري أن يصبح مالكا للمبيع إذا لم يكن البائع مالكا له، وقد سبق بيان ذلك في حكم بيع ملك الغير.

ثالثاً: أن يكون المبيع موجوداً وقت العقد:

ويشترط لانتقال الملكية بمجرد العقد أن يكون الشيء محل العقد موجوداً وقت العقد، فإذا كان محل البيع شيئاً مستقبلاً، فإن الملكية لا تنتقل بمجرد العقد، لأن الشيء لم يوجد بعد، فإذا باع شخص لآخر ما تنتجه حديقة من ثمار، فإن الملكية لن تنتقل إلى المشتري من وقت العقد، بل ومن وقت نضج هذه الثمار^(١).

رابعاً: عدم الاتفاق على إرجاء نقل الملكية:

ويجب ألا يتفق الطرفان على مخالفة حكم القانون الذي يقضى بانتقال الملكية في الشيء بالذات بمجرد العقد، وذلك لأن بانتقال الملكية في الشيء المعين بالذات بمجرد العقد، وذلك لأن الحكم ليس من النظام العام، بل هو حكم مكمل لإرادة المتعاقدين، ومن ثم فلهما الحق في الاتفاق على مخالفته، فإذا حصل مثل هذا الاتفاق، فإن الملكية لا تنتقل فور العقد بل يكون انتقالها طبقاً للاتفاق، ومن أمثلة ذلك:

أن يتفق الطرفان على تعليق نقل الملكية على شرط واقف، فلا تنتقل الملكية إلا بعد تحققه أو يتفقان على إضافتها إلى أجل واقف، كما لو بيعت سيارة على ألا تنقل ملكيتها إلا بعد شهر^(٢).

(١) د. عبد الفتاح عبد الباقي - فقرة ٨٤.

(٢) د. إسماعيل غانم - فقرة ٨٩.

آثار انتقال الملكية بمجرد العقد:
ويترتب على انتقال الملكية في المنقول المعين بالذات بمجرد العقد
عدة آثار، هي:

أولاً: يصبح الشيء المبيع ملكاً للمشتري، وبالتالي يكون له حق
التصرف فيه باعتباره مالاً.

ثانياً: يكون للمشتري أن يطلب تسليم المبيع عند إفلاس البائع، دون
أن يكون لدائني هذا الأخير أن يعترضوا على ذلك، كما يكون لدائني
المشتري الحق في الحجز على المبيع تحت يد البائع.

ثالثاً: يكون للمشتري ثمر المبيع ونماؤه منذ اتمام العقد، فجميع
منتجات المبيع وجميع زياداته المدنية والطبيعية تصبح ملكاً له من
تاريخ تمام البيع، ويجب أن تسلم غلته من المبيع، ما لم يكن ناك
اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.

رابعاً: يجعل للمشتري تكاليف المبيع منذ تمام البيع، ما لم يوجد اتفاق
أو عرف يقضى بغير ذلك.

خامساً: تبعة هلاك الشيء المبيع تقع على عاتق البائع قبل التسليم
إلا إذا كان الهلاك بعد إعدار المشتري تسليم المبيع فتقع تبعة الهلاك
على هذا الأخير^(١).

(١) د. محمد السعيد رشدي - ص ٩٨ ما بعدها.

المطلب الثانى

نقل ملكية المنقول المعين بالنوع

وملكية المنقول المعين بنوعه، كبيع عشرين أردباً من القمح من نوع معين، تنتقل بالإفراز ولا يقتصر الأمر فيها على مجرد العقد وقبل الإفراز الذي ينتقل به الملك يقتصر أثر العقد على مجرد إنشاء التزامات شخصية يلتزم البائع بمقتضاها بأن يقوم بما هو ضرورى لنقل الملكية، طبقاً لحكم المادة (٤٢٨) مدنى.

وقد نصت على ذلك المادة (١/٢٠٥) مدنى، فقالت: "إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه، فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء، كما تنص المادة ٩٣٣ مدنى على أن المنقول الذي لم يعين بنوعه لا تنتقل ملكيه إلا بإفرازه، طبقاً للمادة (٢٠٥) مدنى.

تعريف المنقول المعين بالنوع:

والمنقول المعين بنوعه يتمثل في الأشياء التى يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء، والتى تقدر بالكيل أو بالوزن أو بالعد أو بالقياس مادة (٨٥) مدنى، وذلك كأن يقع البيع على خمسين إردباً من القمح أو على عشرين قنطاراً من القطن، وفي هذه الأشياء لا تنتقل الملكية بالعقد، وإنما لابد أن يتحدد المبيع تحديداً كافياً بإفرازه.

والمراد بالإفراز: هو العمل على تحويل الشيء المعين بنوعه إلى شيء معين بذاته، أو هو العمل على تحديد المبيع وتمييزه عن بقية الأشياء المماثلة^(١).

ويتم الإفراز بالطريقة التي تتفق مع طبيعة المبيع، فقد يتم بالوزن أو العد، أو بالكيل أو بالقياس، أو بتجنيب المبيع وفصله عن غيره، أو بوضع علامة مميزة عليه^(٢)، ويتم الإفراز في الوقت الذي يجب التسليم فيه وفي مكانه، ما لم يوجد اتفاق بين المتعاقدين يقضى بغير ذلك، والملكية تنتقل من البائع إلى المشتري من وقت حصول الإفراز دون أثر رجعي، وإذا تم الإفراز فإن الملكية تنتقل له ولو لم يتم تسليم المبيع، ولا يشترط لصحة الإفراز حضور المشتري، وذلك لعدم وجود نص في القانون يقضى بذلك، كما أن له حق الرفض إذا وجد المبيع غير مطابق للصنف أو العينة التي تم الاتفاق عليها^(٣).

وتبعية الهلاك مرتبطة بالتسليم، ومن ثم يظل البائع متحماً لها رغم الإفراز حتى يتم التسليم، كما أن البائع هو الذي يتحمل نفقات الإفراز لأنه مدين بما يلزم لنقل الملكية، والإفراز من ضروراته.

(١) د. عبد الفتاح عبد الباقي - فقرة ٨٦.

(٢) د. إسماعيل غانم - فقرة ٩٥.

(٣) د. عبد الرازق حسن فرج - ص ١٣٦.

جزاء الامتناع عن الإفراز:

وإذا امتنع البائع عن إفراز المبيع يكون مخالفاً بالتزام يجب على أدائه، ويكون للمشتري أن يلزمه بالقيام به^(١)، وإلا كان له أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة البائع بعد استئذان القاضي، أو دون استئذانه في حالة الاستعجال، كما يكون له أن يطالب بقيمة الشيء، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض مادة (٢/٢٠٥) مدنى.

المطلب الثالث

نقل الحقوق العقارية

والملكية في العقار تنتقل بالتسجيل، فلكى تنتقل الملكية فيما بين المتعاقدين، أو بالنسبة للغير، يجب تسجيل عقد البيع على الوارد على العقار أو على الحقوق العينية بصفة عامة. وقد حرص المشرع على الإشارة لضرورة القواعد المتعلقة بالتسجيل في المادة (٢٠٤) مدنى، حيث ذكر في نهايتها: "وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل، كما حرص على الإشارة إلى الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقارى" في المادة (٩٣٤) مدنى، والتي تقضى بأنه: "١- في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى، سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان

(١) وذلك عن طريق رجال السلطة العامة أو بواسطة خبير، د. عبد الرازق حسن فرج - ص ١٣٧.

في حق الغير، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون الشهر العقاري. ٢- ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر، التصرفات والأحكام، والسندات التي يجب شهرها، سواء أكانت ناقلة للملكية، أم غير ناقلة لها، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر".

وبناء على ذلك: نصت المادة (٩) من قانون الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦، والمعمول به ابتداء من أول يناير سنة ١٩٤٧ وحتى الآن^(١)، على أن: "التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العينية الأصلية على عقار، أو التي من شأنها نقل حق من هذا النوع أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل، ويترتب على عدم تسجيلها أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن، ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن".

ويستفاد من هذا النص أن كل تصرف من شأنه نقل الملكية يجب أن يشهر، أى أن تسجل وفقاً للطرق المقررة في قانون الشهر العقاري، ولما كان عقد البيع من العقود التي تؤدي إلى نقل الملكية، فإنه يجب تسجيله، وليس من شأن هذا التسجيل أن يجعل عقد البيع عقداً شكلياً لا ينعقد إلا إذا تم تسجيله، لأن عقد بيع العقار في حد

(١) المعدل بالقانون ١٥ لسنة ١٩٧٦م.

ذاته عقد رضائي، يتم بمجرد التراضي بين الطرفين، وإنما يلتزم التسجيل لكي يترتب على العقد الأثر الناقل للملكية.

مراحل عقد بيع العقار:

وبناء على ذلك فإن عقد بيع العقار يمر بمرحلتين:

المرحلة الأولى: مرحلة عقد البيع الابتدائي.

المرحلة الثانية: مرحلة العقد بعد شهره وتسجيله.

ونبين آثار العقد في كل من هاتين المرحلتين:

أولاً: آثار عقد بيع العقار الابتدائي:

وعقد بيع العقار الابتدائي الذي لم يسجل، لا نقل الملكية للمشتري، وإنما تترتب عليه التامات وحقوق شخصية بين كل من البائع والمشتري، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (٩) من قانون الشهر العقاري، بعد أن بينت أن التصرفات غير المسجلة لا تترتب أثراً فيما يتعلق بنقل الملكية حتى يبين المتعاقدين إلا من تاريخ تسجيلها، فقال: "إن التصرفات غير المسجلة تترتب التزامات شخصية دون ذوى الشأن".

ويترتب على ذلك: أن البائع يلتزم بكل ما يترتب على عقد البيع الابتدائي من التزامات شخصية تقع على عاتقه، ومن أهم تلك الالتزامات الالتزام بنقل الملكية إلى المشتري، وبناء على ذلك يكون عليه القيام بكل ما هو ضروري لاتمام عملية التسجيل، كما يلتزم بتسليم الشيء المبيع وضمانه، ويلتزم المشتري بالثمن ويتسلم المبيع، ويكون لكل من طرفي العقد أن يجبر الآخر على تنفيذ التزاماته التي

يولدها العقد، إذا لم يَقم بتنفيذها اختياراً^(١)، وذلك عن طريق دعوى صحة التعاقد، ودعوى صحة التوقيع، ونلقى الضوء على مضمون كل من هاتين الدعويتين:

(١) دعوى صحة التعاقد:

إذا امتنع البائع عن القيام بالإجراءات اللازمة للتسجيل، ففي هذه الحالة يكون للمشتري أن يطلب إليه القيام بذلك، كما يكون له أن يجبره على ذلك عن طريق دعوى صحة التعاقد، حيث يطلب المشتري من المحكمة الحكم له بصحة ونفاذ البيع، فإذا قضى له بذلك وقام بتسجيل الحكم فإنه يكتسب الملكية.

ويستند حق المشتري في رفع هذه الدعوى إلى القواعد العامة التي تقضى بإجبار المدين على تنفيذ التزامه عيناً إذا كان ذلك ممكناً، حيث نصت المادة (٢١٠) مدنى، على أنه: "في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام".

كما ذكرت هذه الدعوى المادة (١٤٥) من قانون تنظيم الشهر العقارى الصادر سنة ١٩٤٦، بين الدعاوى التى ينظم قيدها في السجل العينى، مادة (٣٢) من قانون السجل العينى رقم ١٤٣ لسنة ١٩٦٤.

طبيعة دعوى صحة التعاقد:

ودعوى صحة التعاقد دعوى شخصية عقارية، يكون الاختصاص بنظرها للمحكمة التى يقع في دائرتها العقار المبيع، فهى

(١) الوسيط للسنهورى - فقرة ١٥٧.

شخصية، لأن المشتري يرفعها بصفته دائناً للبائع لا مالكاً، حيث لم يصبح بعد صاحب حق عيني، وهى دعوى عقارية ، لأن محلها عقار، وهى تهدف إلى كسب حق عيني عقارى، ويقوم لرفعها المشتري أو ورثته على البائع، أو ورثته (١)، ليواجه بها امتناع البائع عن إنجاز الأعمال اللازمة لتسجيل البيع، سواء كان هذا البائع منكرأً أصل صدور البيع منه، أم معترفاً بهذا البيع، ويطلب المشتري فيها الحكم له بثبوت البيع أو بصحته ونفاذه، فإذا ما حكم له في هذه الدعوى استطاع أن يسجل الحكم باعتباره سنداً قاطعاً على وقوع البيع، ولا يحتاج تسجيله في هذه الحالة إلى تدخل من البائع، وتنتقل إلى المشتري ملكية العقار المبيع بتسجيل الحكم الصادر لمصلحته (٢)، وهى دعوى موضوعية تنصب على حقيقة البيع، فتتناول صحته ومداه ونفاذه، ويكون الحكم الصادر فيها مقررأً لكل ما ورد عليه الرضا بين المتعاقدين، دون حاجة إلى الورقة التى تم فيها التعاقد أولاً، وعلى القاضى أن يتحقق من عدم وجود سبب من أسباب البطلان أو عدم التنفيذ.

شروط نجاح المشتري في دعوى صحة التعاقد:

ويشترط لى ينجح المشتري في مسعاه ويكسب دعوى صحة التعاقد ضد البائع أن يتوافر شرطان:

(١) أنور سلطان وجلال العدوى - فقرة ٢٨٥.

(٢) د. محمود جمال زكى - السابق - ص ٢٠٤، مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى - ج ٢ - ص ٥٢٩.

أولهما: أن يكون تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية ما يزال ممكناً:

فإذا كان تنفيذ التزامه غير ممكن بأن كان قد تصرف في العقار وسجل المتصرف إليه عقده وانتقلت إليه الملكية، فلا يكون التنفيذ العيني ممكناً، ولا يجاب المشتري إلى طلب ويتعين الحكم برفض دعوى صحة التعاقد، إذ أن الحكم فيها لصالحه لن يكون مجدياً ويستطيع المشتري أن يرجع على البائع بالتعويض^(١).

ثانيهما: وفاء المشتري بالتزاماته:

يشترط أن يكون المشتري قد نفذ التزامه بالنسبة للوفاء بالثمن، أو أودعه خزينة المحكمة، بعد عرضه عرضاً حقيقياً، لأن عقد البيع من العقود التبادلية، ولا يجبر البائع على تنفيذ التزامه إذا لم يكن المشتري قد وفى بالتزامه بدفع الثمن، والقاعدة أن البائع وحده هو الذي يستطيع أن يحتج بعدم دفع الثمن، فلا يجوز لغيره أن يطعن في أن المشتري لم يودع الثمن، أو ما تبقى منه خزانة المحكمة.

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد:

ولتلافى ما قد يلجأ إليه البائع من التصرف في العقار المبيع ببيعه، أو بترتيب حق عيني عليه في الفترة ما بين رفع الدعوى وصدر الحكم فيها، حيث إن التصرف الصادر من البائع للغير في تلك الفترة يعتبر نافذاً في مواجهة المشتري، حيث لا يزال الأول مالكاً للعقار، فإن المشرع قد أجاز تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد،

(١) نقض مدني في ١٩٦٨/١١/٢١، المجموعة س ١٩ - ص ١٣٩٩.

مادة (٢/١٥) من قانون الشهر العقاري، كما نصت المادة (٢/١٧) من نفس القانون، على أن: "حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤثر به طبق القانون، يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى^(١)."

وبناء على ذلك: يجب على المشتري أن يقوم بتسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، ويكون ذلك بتسجيل صحيفة افتتاح الدعوى بعد إعلانها إلى البائع، وقيدها بجدول المحكمة، فإذا ما صدر الحكم لصالح المشتري وجب عليه أن يقوم بالتأشير بمضمونه، على هامش تسجيل صحيفة الدعوى، ويترتب على هذا التأشير أن حق المشتري يكون حجة على كل من ترتب له حق عيني ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، كما يلاحظ أن الملكية لا تنتقل إلى المشتري بتسجيل صحيفة الدعوى، وإنما تنتقل إليه من وقت التأشير بالحكم الصادر له^(٢)، ومن ثم لا يكون له قبل ذلك أن يطالب بالشفعة كمالك للعقار^(٣).

(٢) دعوى صحة التوقيع:

إذا كان عقد البيع ثابتاً في ورقة عرفية، وامتنع البائع عن التصديق على توقيعه عليها أمام الموظف المختص تمهيداً لتسجيل

(١) أنور سلطان وجلال العدوى - فقرة ٢٨٧.

(٢) د. السنهوري - فقرة ٢٧٤.

(٣) د. عبد المنعم البدرأوى - ص ٣٧١ وما بعدها.

عقد البيع، كان للمشتري أن يرفع عليه دعوى صحة التوقيع، فإذا صدر الحكم بصحة التوقيع، فإن هذا الحكم يقوم مقام التصديق على التوقيع، ويكون للمشتري أن يسجل عقد البيع مرفقاً به الحكم بصحة توقيع البائع.

وجوه التفرقة بين دعاوى صحة التوقيع ودعوى صحة التعاقد:

ويمكن بيان وجوه التفرقة بين الدعويين على النحو التالي:

أولاً: دعوى صحة التوقيع ليست دعوى موضوعية كدعوى صحة التعاقد، وإنما هي دعوى تحفظية يقتصر أمرها على مجرد التثبت من صحة توقيع البائع على عقد البيع العرفي، وليس للقاضي فيها أن يتعرض لموضوع التصرف المدون في المحرر العرفي من حيث انعقاده أو صحته أو نفاذه، ومن ثم فليس هناك ما يحول في دعوى صحة التعاقد من قيام البائع بالطعن في البيع بالإبطال، أو عدم النفاذ أو الفسخ.

ثانياً: لا يمكن الالتجاء لدعوى صحة التوقيع إلا إذا كان عقد البيع مكتوباً في محرر عرفي، فلو أن العقد قد تم مشافهة فلا يمكن الالتجاء إليها.

ثالثاً: دعوى صحة التوقيع من الدعاوى التي لا تسجل صحيفتها فيحتج بالحكم الصادر فيها منذ تسجيل صحيفة الدعوى، وهي في هذا تختلف عن دعوة صحة التعاقد، كما أن تسجيل العقد العرفي مصحوباً بالحكم الصادر بصحة التوقيع لا يكون له أثر رجعي، ومن ثم فإن

البائع إذا قام بالتصرف أثناء نظر الدعوى إلى شخص آخر، وقام المتصرف إليه بتسجيل عقده قبل أن يسجل المشتري الأول عقده، بناء على الحكم الصادر بصحة التوقيع، فإن المشتري الثاني هو الذي يفضل^(١)، ومن ثم فإن هذه الدعوى لا تحقق للمشتري الحماية التي تحققها دعوى صحة التعاقد، ولذلك فإن الدعوى الأخيرة قد غلبت يفي التعامل على دعوى صحة التوقيع^(٢).

ثانياً: آثار عقد البيع بعد تسجيله:

ملكية العقار لا تنتقل إلا بعقد مسجل، سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير وما لم يحصل هذا التسجيل فإن الملكية تبقى على ذمة المتصرف، ولا يكون للمتصرف إليه في الفقرة من تاريخ العقد إلى وقت التسجيل، سوى مجرد أمل في الملكية دون أى حق فيها، ولكن ليس معنى ذلك أن التسجيل بذاته هو الذي ينقل الملكية، دون أن يكون للبيع نفسه أى أثر في هذا النقل، فالواقع أن عقد البيع هو الأساس في نقل الملكية، ومن ثم فإن ثبوت الحق للمشتري نهائياً لا يقوم على حصول كجرد التسجيل وإنما يتوقف على مصير عقد البيع نفسه، ولا بد أن يكون هذا العقد في ذاته صحيحاً صادراً من مالك وإلا فإن التسجيل لا يترتب عليه أى أثر في نقل

(١) نقض مدنى في ٢١/٤/١٩٥٥، المجموعة ٦ - ص ١٠٢٣ رقم ١٣٤.

(٢) د. السنهورى - فقرة ٢٧٥.

الملكية، وكذلك الأمر فيما إذا كان العقد صورياً، لأن العقد الصوري غير موجود، وبالتالي لا يترتب عليه أثر حتى ولو سجل^(١).
طبيعة التسجيل:

ويثور تساؤل في الفقه حول الطبيعة القانونية للتسجيل، ذلك أن المشرع يجعل له دوراً فعالاً في نقل ملكية العقار المبيع، مع أنه ليس عنصراً أو شرطاً شكلياً في عقد البيع يتوقف على تخلفه بطلان العقد، فكيف يفسر تعليق انتقال الملكية عليه؟.

لم يحاول الفقه أن يقدم الإجابة الواضحة التي تبرر هذا الارتباط بين نقل الملكية والتسجيل، على اعتبار أنه ركن من أركان العقد، وهذا ما يجب أن يكون، وإنما اكتفى بما يفيد أنه شرط لنفاذ العقد، يترتب على تخلفه عدم سريانه.

ليس للتسجيل أثر رجعي:

والملكية في العقار المبيع تنتقل بالتسجيل، إذا كان عقد البيع صحيحاً نافذاً صادراً من مالك بمجرد تسجيله، أو منذ تسجيل الحكم الصادر لصالح المشتري بصحة العقد ونفاذه سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير، وليس من وقت العقد، أي ليس للتسجيل أثر رجعي، وهذا ما ذهب إليه الرأي السائد في الفقه والقضاء^(٢).

التنازع بين مشترين بعقدين مسجلين:

الراجح في الفقه والقضاء أن الملكية لا تنتقل فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، ومن تاريخ التسجيل، ولكن

(١) د. عبد الرازق حسن فرج - ص ١٦٨.

(٢) د. عبد المنعم البدرأوى - فقرة ٢١٩.

قد يحدث أن يقوم البائع ببيع العقار إلى مشتر ثان ويقوم هذا الأخير بالتسجيل قبل المشتري الأول، والحكم في هذه الحالة أن الملكية تنتقل إلى المشتري الثانى الي قام بالتسجيل، وهنا يثور تساؤل حاصله: هل تثبت الأفضلية للمشتري الثانى في تلك الحالة بصفة مطلقة؟
رأيان في المسألة:

ذهب رأى إلى الاعتداد بالأسبقية في التسجيل مطلقاً، حتى ولو كان المشتري الثانى يعلم بوجود البيع الأول، وحتى ولو كان متواطئاً مع البائع، ذلك أن العبرة في نظره بالتسجيل مع صحة العقد وقد حصل للمشتري الثانى، ومن الواجب أن يتم وضع حد للمنازعات التى تثار حول حسن النية أو سوءها، وهذا القول من شأن العمل به أن يؤدي إلى استقرار الملكية العقارية، ويتمشى مع ما هو مرغوب فيه من الأخذ بنظام السجلات العينية^(١).

وذهب رأى آخر إلى عدم الاعتداد بالأسبقية في التسجيل على سبيل الإطلاق وإنما يحد منها اتجاهان:
أولهما: ضرورة توافر حسن النية لدى المشتري:

وقد قرر أصحاب هذا الاتجاه أنه يلزم أن يكون المشتري الثانى الذي سبق في التسجيل حسن النية حتى يفضل على المشتري الأول الذي لم يسجل، ويتمثل حسن النية في عدم علم المشتري الثانى بسبق البيع، فإذا كان المشتري الثانى يعلم وقت شرائه أنه يشتري من بائع

(١) من هذا رأى: د. إسماعيل غانم - فقرة ١٢٢.

سبق له التصرف في المبيع ذاته إلى مشتري سابق، فإنه يعد سيء النية، ولا يستفيد من أسبقيته في التسجيل ويكفى العلم البسيط دون أن يكون هناك تواطؤ^(١).

ثانيهما: يرى ضرورة عدم وجود تواطؤ:

ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن العلم بسبق التصرف لا يتنافى مع حسن النية، ولكن الذي يعول عليه، هو وجود التواطؤ، فلو أن المشتري الثاني كان يعلم بوجود البيع وكان صحيحاً، فإن مجرد العلم بسبق البيع لا أثر له في تفضيل المشتري الثاني، طالما لم يكن متواطئاً مع البائع على الإضرار بالمشتري الأول، أما لو كان متواطئاً مع البائع على الإضرار بحقوق المشتري الأول، فلا يكون له التمسك بأسبقيته في التسجيل.

وأساس هذا الرأي: القاعدة العامة التي تقضى بأن الغش يبطل كل التصرفات، فالعقد المسجل إذا جاء نتيجة غش وتواطؤ يكون باطلاً ولا يصحح التسجيل، والغش عمل غير مشروع يلزم فاعله بتعويض الضرر الناتج عنه، وخير تعويض في تلك الحالة هو عدم الاعتراف بالتسجيل^(٢).

(١) من هذا الرأي: د. أنور سلطان - عقد البيع - فقرة ١٨٣.

(٢) الوسيط للنهوى - فقرة ٢٩٠.

وجدير بالذكر أن اتجاه القضاء في مصر يأخذ بمبدأ الأسبقية المطلقة للتسجيل حتى ولو كان المشتري الثانى متواطئاً مع البائع على الإضرار بحقوق الغير^(١).

وفي نظرنا أن مسلك القضاء هو الراجح، حيث يجب الاعتداد بسبق التسجيل بصفة مطلقة، فذلك هو الأجدلاً بالاعتبار، تقوية لأثر التسجيل اتفاقاً مع قصد المشرع، فضلاً عن استقرار الملكية وثباتها، ومعيار حسن النية أو تواطؤ المشتري الثانى مع البائع معيار غير منضبط، ويسهل التلاعب فيه من خلال وسائل الإثبات لحساب أى من الطرفين، وعلى حساب المبدأ المقرر قانوناً وهو الاعتداد بالتسجيل، ولذلك فإننا نرجح هذا الاتجاه.

(١) نقض مدنى في ١٩٦٦/٢/٢٥.

المبحث الثانى

التزام البائع بتسليم المبيع

يعتبر الالتزام بتسليم المبيع من الالتزامات المهمة التى يترتبها عقد البيع في ذمة البائع وهو التزام مهم بالنسبة للمشتري حيث يتمكن بمقتضاه من الانتفاع بالعين المبيعة، كما أن الملكية في بيع المنقول المعين بالنوع لا تنتقل إلا بالإفراز، وهو يتم عادة بالتسليم، كما أن التسليم في المنقولات المادية يحمى المشتري المنقول ملكيته التى يكتسبها بمجرد العقد، دون أن يحتج الغير في مواجهته بقاعدة الحيابة في المنقول سند الحائز.

ولأهمية التسليم في عقد البيع عن المشرع بتنظيم أحكامه في المواد من (٤٣١ إلى ٤٣٨) مدنى، وسوف نتناول دراسته من خلال مطلبين: نخصص أولهما: لبيان مضمون الالتزام بالتسليم، وثانيهما: لبيان أحكامه.

المطلب الأول

مضمون الالتزام بتسليم المبيع

ودراسة مضمون الالتزام بتسليم المبيع يقتضى بيان معنى التسليم وكيفيته، ونطاق الالتزام به، والحالة التى يتم عليها التسليم ونخصص لكل موضوع منها فرعاً.

الفرع الأول

معنى التسليم وكيفيته

وتسليم المبيع هو إجراء يؤدى إلى تمكين المشتري من المبيع بحيث يستطيع أن يمارس سلطاته عليه كمالك، دون أن يمنعه من ذلك مانع^(١).

وقد نصت المادة (٤٣٥) مدنى، على أنه: "١- يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته البائع قد أعلمه بذلك، ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع. ٢- ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضى المتعاقدين، إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع، أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع بسبب آخر غير الملكية".

(١) د. جميل الشرقاوى - فقرة ٥٩.

ويبدو من نص المادة (٤٣٥) مدنى، أن هناك طريقتين للتسليم؛ الأولى: تتمثل في التسليم الفعلى، والثانية: تتمثل في التسليم الحكمى، وينبغى بيان ذلك.

أولاً: التسليم الفعلى للمبيع:

والتسليم الفعلى يتمثل في وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق، ويتحقق التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري، أيأ كانت الوسيلة التى يتم بها ذلك^(١).

ولا يتحقق التزام بالتسجيل إذا وجد عائق يحول بين المشتري وحيازة المبيع والانتفاع به، يستوى أن يكون ذلك العائق من جهة البائع نفسه، كما لو استمر في زراعة الأرض المبيعة، أو في استعمال السيارة وعدم نقل ملكيتها، ووضع جميع الأوراق اللازمة لذلك تحت تصرف المشتري أو كان الذي يعوق التسليم شخص غير البائع، فإن الالتزام بالتسليم لن يتم في كلتا الحالتين.

ووفقاً لما تقضى به المادة (٤٣٥) مدنى، فإنه لا يكفى أن يقوم البائع بوضع المبيع تحت تصرف المشتري، بل يلزم أن يكون المشتري على علم بما قام به البائع من خلال إخطاره به، وقد وضحت ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون، حين قررت: أن التسليم يتم بتوافر عنصرين هما: وضع المبيع تحت تصرف المشتري، وعلم المشتري

(١) د. جميل الشرقاوى - المكان نفسه.

بهذا الوضع، والمفروض ان البائع هو الذي يعلمه بذلك^(١)، ولا يلزم لهذا الإعلان شكل خاص، فيتم بكافة الطرق، كما لا يلزم فيه إعلان رسمي.

وإذا تم التسليم على هذا النحو تبرأ ذمة البائع من الالتزام به، حتى ولو لم تسلمه المشتري، لأن الالتزام بالتسليم يقع على عاتق المشتري كما سنرى.

ثانياً: التسليم الحكمي:

ويكون التسليم الحكمي باتفاق الطرفين على تغيير صفة الحياة، وذلك كما لو كان المبيع تحت يد المشتري لأي سبب آخر كأجرة أو إعاره، فلو اشتراه وهو تحت يده على هذا النحو، فإن تسليمه لا يستلزم القيام بأي عمل خارجي، بل يكفي أن يغير المشتري نيته في حياة المبيع من حياة مستأجر إلى حياة مالك.

وقد يبقى المبيع في حياة المالك بعد البيع، ولكن بقاؤه يكون بصفة أخرى كمستأجر له - مثلاً - من المشتري، أو مستعير، فتسليم المبيع لا يتم فعلاً إلى المشتري بل يبقى في حياة البائع من اعتبار أن التسليم قد تم حكماً بعد أن صار حائزاً لحساب المشتري لا لحساب نفسه، ففي كلتا الحالتين يكون التسليم قد تم بمجرد الاتفاق على تغيير صفة الحياة.

(١) مجموعة الأعمال التحضيرية - ج ٦٨ وما بعدها.

الفرع الثانى

نطاق الالتزام بالتسليم

ولا يقتصر نطاق الالتزام بالتسليم على الشيء المبيع فحسب، بل يمتد إلى ملحقاته.

وقد نصت على ذلك المادة (٤٣٢) مدنى، بقولها: "يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع، وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

ويبدو من هذا النص أنه لم يحدد المقصود بالملحقات، لكن يمكن القول أنها تشمل كل ما أعد بصفة دائمة ليكون تابعاً للصّل وملحقاً به، بحيث لو فصل عنه فإنه لن يؤدى الغرض الذي قصد المشتري إليه بشرائه^(١).

وتطبيقاً لذلك:

فإنه إذا كان المبيع عقاراً يعتبر من ملحقاته، مفاتيح المنزل ومستندات الملكية وعقود التأمين، والحقوق والدعاوى المرتبطة به كحقوق الارتفاق، ودعوى الضمان التى للبائع ضد المهندس والمقاول الذين قاما ببناء المنزل، كما يعتبر من ملحقاته الأفران الملحقة بها، والمغاسل، ولكن لا يدخل في الملحقات المنقولات التى لا يمكن فصلها دون تلف كالمرايا غير المثبتة، والنجف المعلق^(٢).

(١) الوسيط للسنهورى - فقرة ٣٠٢.

(٢) د. السنهورى - فقرة ٣٠٣.

وإذا كان المبيع أرضاً فإنه يعد من ملحقاته البناء المقام عليه فإذا كان أرضاً زراعية اعتبر من ملحقاته حقوق الارتفاق، والعقارات بالتخصيص، كالمواشى والآلات الزراعية.

وإذا كان المبيع بستاناً دخل في ملحقاته الأشجار المغروسة والثمار التي لم تتضج، أما الثمار الناضجة فلا تدخل في الملحقات، وإذا كان المبيع مصنعاً اعتبر من ملحقاته المخازن التي تودع فيها المصنوعات، وكذلك السيارات المخصصة لنقل البضائع، وإذا كان المبيع حيواناً اعتبر من ملحقاته صغاره التي يرضعها، وكذلك الصوف ولو كان مهياً للجز، وهذه المثلة كما تقول المذكرة الإيضاحية للبيان وليست للحصر.

ويكون للمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت إتمام البيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت، ما لم يوجد اتفاق، أو عرف يقضى بغير ذلك، مادة (٢/٤٥٨) مدنى^(١).

الفرع الثالث

حالة المبيع وقت التسليم

يجب على البائع أن يقوم بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع، وذلك وفقاً لما تقضى به المادة (٤٣١) مدنى، وهذا النص يلقي على عاتق البائع التزاماً آخر يسبق التسليم، وهو

(١) مجموعة الأعمال التحضيرية - المكان السابق.

الالتزام بالمحافظة على المبيع إلى حين التسليم، وقد جاء هذا النص في سطره الأول تطبيقاً للقاعدة العامة الواردة في المادة (٢٠٦) مدنى، والتي تنص على أن: "الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء، والمحافظة عليه حتى التسليم"، وهذا الحكم يشمل المبيع وملحقاته، لأن الملحقات تعتبر في الواقع من المبيع، ومن ثم ينصرف الالتزام بالمحافظة على المبيع إليها، حتى يتم تسليمه للمشتري. وتسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت التعاقد مسأل واقع مستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها دون رقابة عليه من محكمة النقض.

المبيع العين بالذات:

وتطبيقاً لذلك، فإنه إذا كان المبيع معيناً بذاته، يجب على البائع أن يحافظ عليه، فإذا تصرف البائع على خلاف ذلك، بأن قام لالبناء في الأرض المبيعة قبل التسجيل فإنه يعتبر مخلاً بالتزامه بالتسليم بالحالة التي كان عليها المبيع وقت العقد، ويكون كأنه قد بنى في ملك غيره بسوء نية، وتطبيق عليه أحكام البناء في ملك الغير فيلتزم بإزالة البناء إذا طلب المشتري ذلك، كما أن له أن يستبقه نظير تعويض المشتري له.

المبيع المعين بالنوع:

أما إذا كان المبيع معيناً بنوعه، فقد نصت المادة (١/١٣٣) مدنى على أنه: "إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث

جودته، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أى ظرف آخر،
التزم البائع بان يسلم شيئاً من صنف متوسط"، فالحالة التى يجب
تسليم المبيع عليها في عذا الفرض بيعنها الاتفاق، فيسلم البائع الذي
يقضى به العرف أو أية ظروف أخرى ملابسة، فإذا لم يوجد هذا
ولا ذاك يجب أن يسلم المبيع من صنف متوسط^(١).

تسليم المبيع بنفس القدر:

كما يجب تسليم المبيع بنفس القدر المتفق عليه في العقد،
فالبائع ضامن لهذا القدر، وقد ينقص المبيع أو يزيد، ويكون للمشتري
المطالبة بالفسخ، أو بإنقاص الثمن، إذا حدث نقص في القدر المسلم
إليه عن القدر المتفق عليه في عقد البيع، وقد يلتزم المشتري بتكملة
الثمن، إذا كانت هناك زيادة في القدر المتفق عليه في عقد البيع، وفقاً
لما نصت عليه المادة (٤٣٤) مدنى، بقولها: "إذا وجد في المبيع عجز
أو زيادة، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن، أو في طلب فسخ
العقد، وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منها بالتقادم إذا
انقضت سنة من وقت تسليم للمبيعت تسليمياً فعلياً".

وبناء على هذا النص فإن الدعاوى الناشئة عن العجز من
المبيع أو زيادته تتقادم بمضى سنة^(٢).

(١) د. خميس خضر - فقرة ٩٥.

(٢) د. محمد على عمران - ص ٢٢١ وما بعدها.

المطلب الثانى

أحكام الالتزام بتسليم المبيع

ومن مقتضى بيان أحكام الالتزام بتسليم المبيع، إلقاء الضوء على زمان ومكان التسليم ونفقاته، وحق البائع في حبس المبيع، وبيان على من تقع هلاك المبيع قبل التسليم، ونخصص لكل موضوع من تلك الموضوعات فرعاً:

الفرع الأول

زمان التسليم ومكانه ونفقاته

أولاً: زمان التسليم:

لم تتضمن القواعد الخاصة بعقد البيع وأحكاماً خاصة بزمان التسليم، ومفاد ذلك أن المشرع قد ترك هذه المسألة للقواعد العامة الواردة في باب الالتزام، وبمقتضى هذه القواعد يجب على البائع أن يقوم بتسليم المبيع في الوقت الذي يحدده الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يحدد للتسليم وقت يتعين زمانه بانعقاد العقد مادة (٣٤٦)، مدنى، وذلك مع ملاحظة أن العرف قد قضى بمنح البائع مهلة للتسليم خاصة في مجال المعاملات التجارية، كما أن الاتفاق على تأجيل التسليم، قد يكون ضمناً، يستخلص من الظروف، ما لو كان موجوداً بمخازن بعيدة، وليس في حيازة البائع، فيعطى البائع مهلة معقولة للتسليم^(١).

(١) د. عبد الرازق حسن فرج - ص ٢١١.

ثانياً: مكان التسليم:

كما يجب أن يتم التسليم في المكان الذي يتفق عليه المتعاقدان، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف فيتم التسليم في المكان الذي يوجد فيه المبيع، وقت إبرام البيع إذا كان معيناً بالذات، وأما إذا كان المبيع بالنوع، ففي المكان الذي يوجد فيه موطن إقامة البائع أو مركز إدارة أعماله، إذا كان المبيع متعلقاً بهذه العمال ذلك أن الدين مطلوب لا محمول، وهذا ما تقضى به القواعد العامة، وأما إذا كان هناك اتفاق على تصدير المبيع، فإن التسليم لا يتم إلا إذا وصل المبيع إلى المشتري، فمكان التسليم في هذه الحالة هو الذي يتفق على أن يتم فيه إرسال المبيع إلى المشتري مادة (٤٣٦) مدنى^(١).

ثالثاً: نفقات التسليم:

ونفقات التسليم المبيع تقع على عاتق البائع، فهو المدين بالالتزام إلا إذا اتفق على غير ذلك، مادة (٣٤٨) مدنى، فإذا كان المبيع معيناً بالنوع، فيقع على البائع نفقات إفرازه، كما يقع على البائع - بصفة عامة - نفقات على المبيع إلى المكان الذي يتم فيه التسليم، كما يقع على عاتق البائع - في حالة المنقول واجب التصدير - نفقات شخص المبيع^(٢)، أما نفقات نقل المبيع من مكان إلى آخر

(١) د. محمد على عمران - ص ٢٢٦.

(٢) د. إسماعيل غانم - ص ١٨٥.

يريد المشتري ورسوم المرور، فهي على المشتري ما لم يوجد اتفاق أو عرف يجعلها على البائع^(١).

الفرع الثاني

حق البائع في حبس المبيع

وحق البائع في حبس المبيع يقتضى بيان أسباب ثبوت هذا الحق وأحكامه.

أولاً: أسباب ثبوت حق الحبس للبائع:

أشارت المادة (٤٥٩) مدنى، إلى بعض أسباب ثبوت الحق للبائع في حبس المبيع بقولها: "١ إذا كان الثمن كله أو بعضه خو مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع، حتى يستوفى ما هو مستحق له، ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة، هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد البيع. ٢- وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن، إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقاً لأحكام المادة (٢٧٣) مدنى".

كما تنص المادة (٤٦٠) مدنى، على أنه: "إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع".

(١) د. السنهورى - فقرة ٣١٣.

ويبدو من هذه النصوص أن هناك حالات فيها الحق للبائع في حبس المبيع، كما أن هناك حالات لا يكون له فيها هذا الحق.

(أ) حالات ثبوت حق حبس المبيع للبائع:

للبيع أن يتمتع عن تنفيذ التزامه بالتسليم رغم حلوله، فيحبس المبيع، إذا كان المشتري لم يدفع ما هو مستحق عليه من الثمن، وهذا الحكم يعتبر تطبيقاً للقواعد العامة في الحبس، وفقاً لمادة (٢٤٦) مدنى، وفي الدفع بعدم التنفيذ وفقاً لمادة (١٦١) مدنى، ولكن من ذلك ينطوى على مخالفة لتلك القواعد العامة، وذلك من خلال نص المادة (٤٥٩) مدنى، على إعطاء البائع الحق في الحبس حتى ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة، مع أن المادة (١/٢٤٦) مدنى، تقضى بأن للمدين أن يجبر الحابس على تسليم الشيء إذا قام بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه، ولعل حكمة هذه المخالفة أن كل ما يهم البائع هو حصوله على الثمن، فإذا لم يتم ذلك كان له أن يستعمل حقه في الحبس، ولكن يجب على البائع حتى يكون له حق الحبس أن يثبت لأنه لم يستوف الثمن كاملاً.

والحق في الحبس لا يتجزأ، ومن ثم يجوز للبائع أن يحبس المبيع بأكمله، حتى يستوفى الثمن كله، وذلك في حدود عدم التعسف في استعمال حقه، وبالتالي لا يجوز له التمسك بحق الحبس، إذا لم يبق له من الثمن إلا جزء بسيط لا يبرر استعمال حق الحبس أو استمراره^(١).

(١) الوسيط للسهنورى - فقرة ٤٠٤.

(ب) سقوط الحق في حبس المبيع:
وإذا تقرر حق البائع في حبس المبيع فإن هذا الحق يسقط في
الحالات الآتية:

(١) إذا استوفى ابائع الثمن أو تنازل عنه.
(٢) إذا سكت البائع عند رؤية المشتري وهو يأخذ المبيع وكان قادراً
على منعه من ذلك، وبمعنى آخر إذا خرج المبيع من حيازة
البائع باختياره.

أما إذا كان المبيع قد خرج من تحت يد البائع خلصة أو بدون
إرادته، فإن حقه في الحبس لا يسقط، ويكون له حق استرداد المبيع
في خلال ثلاثين يوماً من وقت علمه بخروج المبيع من تحت يده،
وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه (م ٢٤٨) مدنى.

(٣) إذا حول البائع حقه في الثمن إلى آخر، فإن الثمن ينتقل إلى
المحال له بضماناته، ومن بينها حق حبس المبيع، أما إذا أحال
المشتري البائع على أحد (في حالة حوالة الدين)، فلا يُعد قبول
البائع للحوالة؟ نزولاً عن حقه في حبس المبيع، بل إن له حبسه
حتى يستوفى حقه، إما من المحال أو من المحال عليه.

(٤) إذا منح البائع المشتري اجلاً جديداً بعد البيع للوفاء بالثمن فإن
حقه في حبس المبيع يسقط، مادة (١/٤٥٩) مدنى، إذ أن مثل
هذا المسلك من قبل البائع يُعد تنازلاً ضمناً منه عن حقه في
الحبس، وذلك بخلاف نظرة الميسرة التى يمنحها القاضى للوفاء
بالثمن، فإنها لا يترتب عليها سقوط حق الحبس^(١).

(١) مجموعة الأعمال التحضيرية - ج ٤ - ص ١٣٥.

(٥) هلاك المبيع المحبوس، كما ينقضى الحق في حبس المبيع بهلاك المبيع المحبوس، ويتحمل المشتري في هذه الحالة تبعة الهلاك، فيظل ملتزماً بالوفاء بالثمن ما لم يكن الهلاك بفعل البائع، مادة (٤٦٠) مدنى، ويعتبر هذا الحكم استثناء من القاعدة العامة المقررة بالمادة (٤٣٧) مدنى، والتي تقضى بأن تبعة هلاك المبيع قبل التسليم تقع على عاتق البائع، ولعل الحكمة من هذا الاستثناء ترجع إلى هلاك المبيع تحت يد البائع، وهو حابس له، مرده إلى تقصير المشتري في الوفاء بالثمن فيتحمل تبعة الهلاك^(١).

ثانياً: أحكام ثبوت الحق في حبس المبيع:

للبائع الحق في حبس المبيع حتى يستوفى الثمن كله، إذ لحق في الحبس غير قابل للتجزئة، وليس للمشتري إذا دفع جزءاً من الثمن الذي حل أن يطالب البائع بتسليمه جزءاً يقابله من المبيع، ولو كان المبيع مما يمكن تجزئته ما دام أنه قد بيع صفة واحدة^(٢).

وللبائع ان يحتج بحقه في الحبس في مواجهة الغير، فإذا باع المشتري الشيء المبيع وأراد المشتري الثانى تسلمه من البائع الأول، كان لهذا الأخير أن يتمسك بحقه في الحبس ويرفض التخلي عن الشيء في مواجهة المشتري الثانى، إذ هو من الغير بالنسبة للبائع الأول حتى يستوفى حقه.

(١) د. أنور سلطان وجلال العدوى - فقرة ٣٢٥.

(٢) د. السنهورى - فقرة ٤٠٤.

ويشمل الحق في الحبس أصل البيع ونماؤه وثماره الناتجة عنه بعد البيع، مع مراعاة أن ثمار المبيع خلال فترة حبسه ملك المشتري، وعلى البائع أن يقدم حساباً عن غلته في فترة حبسه فضلاً عن التزامه بالمحافظة على المبيع أثناء حبسه وفقاً لأحكام رهن الحيازة^(١).

الفرع الثاني

تبعة هلاك المبيع قبل التسليم

موضوع تحمل التبعة، أو تحمل تبعة هلاك الشيء المبيع لا تثور في عقد البيع إلا إذا كان المبيع معيناً بالذات، أما إذا كان المبيع معيناً بالنوع، أي مثلياً، فإنه قبل إفرازه لا تكون له ذاتية محددة، حتى يقال أنه قد هلك، ويستطيع البائع في تلك الحالة أن يقدم شيئاً من مثله، ولهذا يقال: المثليات لا تهلك، لكن لو تم إفرازه وهلك فإنه يصبح معيناً بذاته، وتسرى عليه القولعد العامة في هلاك المبيع. لذلك لا تثور تبعة الهلاك إذا كان هلاك المبيع راجعاً إلى سبب أجنبي لا يد للبائع أو للمشتري فيه، قبل التسليم، مادة (١٥٩) مدني، أما إذا كان الهلاك راجعاً إلى تقصير البائع، فإنه يكون مسئولاً ويتحمل تبعة هلاكه، ويفسخ البيع ويكون للمشتري الحق في استرداد الثمن، مع عدم الإخلال بحقق في التعويض، وإذا هلك بفعل امشتري فإنه يكون مسئولاً عن الوفاء بالثمن ويتحمل تبعة الهلاك.

(١) د. محمد السعيد رشدي - ص ١٤٠.

ذلك ما تقضى به القواعد العامة، وقد طبق المشرع هذه الأحكام في عقد البيع، في المادتين (٤٣٧، ٤٣٨) وهاتان المادتان تعتبر أن تطبيقاً للمبادئ العامة.

وهلاك المبيع قد يكون كلياً، وقد يكون جزئياً، ونبين تبعة الهلاك في كلتا الحالتين.

أولاً: تبعة الهلاك الكلى للمبيع:

نصت المادة (٤٣٧) مدنى، على أنه: "إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا غدا كان الهلاك بعد إعدار المشتري لتسليم المبيع.

ويبدو من هذه المادة أن المقصود بالهلاك هو زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية.

وقد ربط المشرع تبعة الهلاك بالتسليم، والمراد به هو التسليم القانونى لا الفعلى^(١)، فيكفى أن يضع البائع المبيع تحت يد المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به، وأن يعلمه بذلك، فتنقل تبعة الهلاك إلى المشتري، حتى ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً.

فتبعة الهلاك في التشريع المصري ترتبط بالتسليم، فإذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد للبائع فيه، كما إذا هلك بقوة قاهرة، أو بفعل أجنبي، فإن البيع ينفسخ بقوة القانون ويتحلل كل من البائع والمشتري من التزاماته، فإذا كان المشتري قد دفع ثمن المبيع كان له

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - فقرة ٢٧٨.

أن يسترده ويتحمل البائع بذلك تبعة الهلاك قبل التسليم، أما إذا تم الهلاك بعد لتسليم فإن هلاكه يقع على المشتري ولا يستطيع أن يتحلل من التزامه بالوفاء بالثمن^(١)، ويلاحظ ان جعل تبعة الهلاك مرتبطة بالتسليم يتفق مع اتجاه الفقه الإسلامي في هذه المسألة.

ثانياً: تبعة الهلاك الجزئي للمبيع:

وإذا كان الهلاك جزئياً، بأن نقصت قيمة قبل تسليمه لتلف أصابه، جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، وأما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن، مادة (٤٣٨) مدنى.

وتقدير حسامة الهلاك الجزئي يعتبر امراً موضوعياً، ومن ثم لا يجوز للمشتري أن يستقل بفسخ العقد، بل يتقرر بحكم القاضي، وذلك بخلاف الهلاك الكلى حيث يقع الفسخ بقوة القانون، وتبعة الهلاك تقع على البائع قبل التسليم، ويتحمل المشتري تبعة الهلاك إذا حدث بعده^(٢).

حالات تحمل المشتري لتبعة الهلاك قبل التسليم:

ولئن كانت القاعدة في التقنين المصرى أن تبعة الهلاك قبل التسليم تقع على عاتق البائع، إلا ان هناك حالات يتحمل المشتري فيها تبعة الهلاك قبل التسليم، هى:

(١) د. عبد الفتاح عبد الباقي - فقرة ١٢٨.

(٢) يستوى أن يكون الهلاك كلياً أو جزئياً، د. عبد الفتاح عبد الباقي - فقرة ١٢٩.

- (١) الاتفاق بين البائع والمشتري على تحمل الأخير لتبعة الهلاك قبل التسليم، لأن القاعدة ليست أمره، فيجوز الاتفاق على خلافها.
- (٢) إذا أعذر المشتري لتسلم المبيع في الأجل المتفق عليه وامتنع المشتري مع هذا الإعذار عن استلامه، مادة (٤٣٧) مدنى.
- (٣) إذا هلك المبيع تحت يد البائع، وهو حابس له بسبب عدم قيام المشتري بالوفاء بالثمن، فإن تبعة الهلاك تقع على عاتق المشتري، مادة (٤٦٠) مدنى.
- (٤) إذا وضع المشتري يده على المبيع - حتى ولو كان هذا بدون إذن من البائع أو بدون حكم القضاء - وهلك تحت يده، فإنه ليس له في هذه الحالة أن يحتج بعدم التسليم وإلا كان هذا تمسكاً منه بفعله الخاطئ، والمخطئ لا يستفيد من خطئه فتقع تبعة الهلاك عليه ويلزم بدفع الثمن.
- (٥) في القانون التجارى تنص المادة (٩٤) منه على أن: "البضائع التى تخرج من مخزن البائع أو المرسل يكون خطرها في الطريق على من يملكها، ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك".
- وبناء على هذا النص ترتبط تبعة العلاك بنقل الملكية، حيث يتحمل المشتري تبعة الهلاك ولو لم يكن قد تسلم البضائع^(١).

(١) د. حميس خضر - فقرة ١٠٧.

المبحث الثالث

التزام البائع بالضمان

إذا كان من التزامات البائع أن يقوم بنقل الحق المبيع إلى المشتري، ويضعه تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق، وفقاً لما تقضى به قواعد الالتزام بتسليم المبيع، فإنه يجب عليه أن يضمن للمشتري بقاء ملكية المبيع والانتفاع به على نحو كامل دون منازعة من أحد.

فيجب على البائع أن يمتنع شخصياً عن كل فعل يكون من شأنه تعكير حيازة المشتري، أو حرمانه من مباشرة سلطاته القانونية على المبيع بلا معارضة، كما يجب عليه أن يدفع أى تعرض يصدر من الغير، وإذا استحق المبيع لغير المشتري وجب على البائع أن يعرضه عن ذلك.

ولا يشترط لنشوء الضمان أن يكون عقد البيع مسجلاً، ذلك أن التزام البائع بالضمان التزام شخصي ينشأ من عقد البيع، كما يلتزم البائع بضمان العيوب الخفية التى تحول بين المشتري والغاية المقصودة من الشراء.

والحق في الضمان لا يقتصر على عقد البيع، وإنما يشمل جميع عقود المعاوضات الناقلة للحقوق كالمقايضة، مادة (٤٨٥) مدنى، والقرض، مادة (٥٤٠) مدنى، والشركة، مادة (٥١١) مدنى.

كما يوجد في العقود الكاشفة كالقسمة، مادة (٨٤٤) مدنى، وفي الإيجار، المواد (٥٧١ - ٥٨٧) مدنى، مادة (٦٣٨) مدنى.

وفي الهبة إذا كانت بعوض أو تكليف، ففي هذه الحالة يكون الواهب مسئولاً عن الاستحقاق على قدر قيمة العوض والتكليف المادتان (٤٩٤ - ٤٩٥) مدنى.

وقد حرص المشرع على تنظيم أحكام الضمان في عقد البيع تقديراً لأهميته، دون سائر العقود الأخرى، حيث اكتفى بالنسبة لها بالإحالة على ما ورد في عقد البيع من أحكام الضمان، مع بيان وجوه الاختلاف في الضمان عن البيع في كل منهما إذا لزم.

ونتناول في دراستنا بيان أحكام الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق في مطلب اول، وبيان التزام بضمان العيوب الخفية في مطلب ثان، ثم نبين الاتفاق على تعديل أحكام الضمان في مطلب ثالث.

المطلب الاول

ضمان التعرض والاستحقاق

يجب على البائع أن يمتنع عن التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو في حيازته أو ملكيته، وهذا ما يسمى بضمان التعرض الشخصي، كما يجب عليه أن يدفع عن المشتري التعرض الصادر من الغير إذا ادعى حقاً على المبيع يعتبر البائع مسئولاً عنه، ومن ثم يكون التزام البائع بضمان التعرض شاملاً لتعرضه الشخصي، ولتعرض الغير فنخصص لكل نوع من هذين الالتزامين فرعاً.

الفرع الأول

ضمان التعرض الشخصي

لا يجوز للبائع أن يتعرض بنفسه للمشتري في حيازة المبيع تعرضاً قانونياً، أو مادياً حيث لا يتصور أن يأتي البائع من الأفعال ما يتنافى مع التزامه مع المشتري، ومن ثم يجب عليه أن يمتنع عن كل عمل من شأنه أن يحرم المشتري من أى ميزة يرتبها له عقد البيع، والقاعدة أن من عليه الضمان لا يجوز له التعرض، ولئن كان من الواجب على البائع أن يدفع تعرض الغير للمشتري، فمن باب أولى أن يمتنع هو عن هذا التعرض^(١).

(١) د. جميل الشرقاوى - فقرة ٥٦٦.

ومصدر التزام البائع بضمان التعرض الشخصي يتمثل في النصوص القانونية التي أوردها المشرع في هذا الصدد، وخاصة ما تقضى به المادة (٤٣٩) مدنى، والتي تقضى بأنه: "يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي، يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري، ويكون البائع ملزماً بالضمان، ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل عليه من البائع نفسه".

وهذا النوع من الضمان يُعد أمراً طبيعياً، لأن البيع من عقود المعاوضات، والتزام البائع بالضمان مما يتفق مع طبيعته، بل إنه لا يجوز اشتراط عدم ضمان البائع لتعرضه الشخصي، وهذا ما تقضى به المادة (١/٤٤٦) مدنى، حين قالت: "إذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولاً عن أى استحقاق ينشأ عن فعله، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضى بغير ذلك".

وتطبيقاً لذلك:

يعتبر تعرضاً قانونياً من قبل البائع استعمال حق إدعاه من شأنه، أن يؤدي إلى نزع المبيع من يد المشتري، كأن يكون غير مملوك للبائع وقت البيع، ثم يمتلكه بعد البيع لأى سبب من أسباب كسب الملكية، كالميراث أو الشراء من المالك الحقيقى أو التقادم المكسب، فاستناد البائع إلى ما آل إليه من حق الملكية، يُعد تعرضاً

قانونياً للمشتري، ومن ثم لا تقبل دعواه، كما لا يجوز لبائع العقار قبل التسجيل أن يرفع دعوى على المشتري يطالبه باسترداد المبيع على أساس أنه لا يزال مالكا، وأن الملكية لم تنتقل بعد إلى المشتري، لأن الضمان والاسترداد لا يجتمعان^(١).

كما يعتبر تعرضاً مادياً: قيام البائع باغتصاب العين المبيعة أو أن يبيع شخص محلاً تجارياً، ثم يقوم بفتح متجر مجاور، يمارس فيه نفس التجارة التي كان يزاولها في المتجر المبيع، فذلك يمثل منافسة غير مشروعة.

كما يعتبر تعرضاً مادياً: قيام البائع بالتصرف في العقار مرة ثانية إلى مشتر ثان ومبادرته إلى تسحيل البيع الثاني قبل الأول، فالبرغم من أن هذا التصرف يمثل علاقة قانونية بين البائع والمشتري الثاني، إلا أنه يعتبر عملاً مادياً بالنسبة للمشتري الأول واعتباره من الغير، وبالتالي تعرضاً له في انتفاعه بالمبيع كما أنه يعتبر تعرضاً غير مباشر من جانب البائع، لأنه قد أنشأ بفعله المشتري الثاني حقاً على المبيع^(٢).

ولكن هذا لا يعنى ان البائع يحرم من المطالبة بأى حق قانونى له لمجرد أن المطالبة تقتضى هدم البيع، فلا تعارض بين ضمان البائع للتعرض، وبين قيام البائع بالتنفيذ الجبرى على الشيء المبيع

(١) د. السنهورى - فقرة ٣٣١.

(٢) د. السنهورى - فقرة ٣٣٠.

استيفاء الثمن، أو ما تبقى منه، كما أنه لا يعتبر تعرضاً طلب البائع الحكم ببطلان البيع بطلاناً مطلقاً، أو بإبطاله أو بفسخه واسترداد المبيع^(١).

خصائص التزام بضمان التعرض الشخصي:

يتسم الالتزام بضمان التعرض الشخصي، بخصائص هي أنه غير قابل للانقسام، كما أنه التزام مؤبد، ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء منه، ونبين ذلك:

أولاً: عدم القابلية للانقسام:

من خصائص الالتزام بضمان التعرض الشخصي عدم القابلية للانقسام، فلو باع عدة أشخاص مالا مملوكاً على الشيوع دون أن يشترطوا تقسيم المسؤولية عن الالتزام بالضمان، أصبح الالتزام بالضمان غير منقسم بالنسبة لكل واحد منهم، فيسأل عنه بالنسبة للمبيع بأكمله لا في حدود نصيبه، وكذلك لا يقسم الضمان بالانتقال إلى الورثة^(٢).

ثانياً: تأييد الالتزام:

والالتزام بعدم التعرض الشخصي التزام مؤبد، بمعنى أنه لا يجوز للبائع أن يتعرض للمشتري في أى وقت، ولو مضى على البيع أكثر من خمس عشرة سنة، ومع هذا فإن دعوى الضمان التي

(١) د. خميس خضر - فقرة ١١٠.

(٢) د. عبد المنعم البدرأوى - السابق.

تنشأ عن حصول التعرض للمشتري بالفعل تسقط غيرها من الدعاوى بإنقضاء خمس عشرة سنة من وقت حصول التعرض.

ومع ذلك فإنه إذا حدث التعرض من جانب البائع بوضع اليد على المبيع يُعد بيعه، وسكت المشتري عن هذا التعرض بعد وقوعه، ومضى على وضع اليد خمس عشرة سنة، انقلب سبباً مشروعاً لتملك لا يحول دونه ضمان البائع^(١).

ثالثاً: عدم جواز الإعفاء من ضمان التعرض:

وإذا شرط البائع على المشتري إعفاءه من الضمان الناتج من تعرض الشخص، فإن هذا الاتفاق يكون باطلاً، وذلك وفقاً لما تقضى به امادة (١/٤٤٧) مدنى، ولميجز المشرع هذا الشرط لأنه كالاتفاق على إعفاء البائع من مسؤوليته عن غشه أو خطئه الجسيم، فإذا قام البائع بالتصرف في العقار إلى مشتر ثان وبادر بتسجيل عقده أولاً، فإنه يضمن تصرفه حتى ولو اشترط عدم الضمان.

لكن يلاحظ ان شرط إعفاء البائع من الضمان لا يبطل، إذا إذا كان الإعفاء كلياً، فلو اتفق على قصر الضمان على عمل معين يكون البائع غير مسئول عنه، مثل أن يتفق بائع المتجر مع المشتري على أن يحتفظ الأول بحقه في فتح محل يتعامل في بعض السلع التي كان يتعامل فيه المتجر الذي تم بيعه، فهذا الاتفاق صحيح، لافتراض أن

(١) د. السنهورى - فقرة ٣٣١.

المشتري قد أدخل تقديره عند تحديد الثمن وقوع هذا التعرض الجزئي^(١).

كما يجوز الاتفاق على تشديد الضمان، كأن يشترط مشتري المتجر على البائع أن يمتنع عن منافسته في بيع السلع التي تباع في المتجر وغيرها مما يريد المشتري أن يتاجر فيه.

جزاء الإخلال بالالتزام بضمان التعرض الشخصي:

وإذا أخل البائع بالتزامه بضمان التعرض الشخصي، كأن قام بفتح محل تجارى يزاول فيه نفس التجارة التي يزاولها المحل المبيع، كان للمشتري أن يطالب بوقف التعرض، أى إغلاق المحل، وله أن يطلب من المحكمة الحكم بالتعويض على البائع، كما أن للقاضي أن يفرض عليه غرامة تهديدية لإجباره على الامتناع عن التعرض للمشتري.

وإذا كان التعرض قانونياً بأن رفع البائع دعوى مطالباً فيها باستحقاق المبيع، كان للمشتري أن يرفع هذه الدعوى بالدفع بالضمان. وللمشتري أن يطالب بفسخ عقد البيع بدلاً من التنفيذ العيني ويخضع طلب الفسخ لتقدير القاضي - وإذا تم الفسخ جاز للمشتري - أن يطالب البائع بالتعويض عما أصابه من ضرر طبقاً للقواعد العامة.

(١) الوسيط للسنهوري - فقرة ٣٣٦.

الفرع الثانى

ضمان التعرض الصادر من الغير

من المقرر قانوناً أن البائع يلتزم بضمان التعرض الصادر من الغير للمشتري، وإذا كان التزام البائع بضمان التعرض الشخصى الصادر منه يعتبر التزاماً سلبياً للامتناع عن عمل، وهو عدم التعرض للمشتري، فإن التزامه بضمان التعرض الصادر من الغير يعتبر التزاماً إيجابياً مفاده دفع كل تعرض يصدر من الغير للمشتري، فهو التزام بتحقيق نتيجة، وليس التزاماً ببذل عناية، بمعنى أن البائع إذا لم ينجح في دفع التعرض، واستحق المبيع كله أو بعضه للغير، كان على البائع أن يقوم بدفع تعويض للمشتري عن الضرر الذي أصابه وهو ما يعرف بضمان الاستحقاق، ونبين شروط هذا الضمان وأحكامه.

أولاً: شروط ضمان التعرض الصادر من الغير:

تقضى المادة (٣٩) مدنى، لأنه: "يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه، سواء كان التعرض من فعله هو، أو من فعل أجنبي، يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به المشتري، ويكون البائع ملزماً بالضمان، ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه".

ووفقاً لهذا النص:

يشترط أن يكون تعرض الغير قانونياً، وأن يكون التعرض راجعاً إلى سبب سابق على البيع، أو راجعاً إلى فعل البائع، وأن يكون حالاً:

الشرط الأول: أن يكون التعرض قانونياً:

ولئن كان البائع يضمن للمشتري التعرض الشخصي الصادر منه سواء كان تعرضاً مادياً أم قانونياً، إلا أنه لا يضمن التعرض الصادر من الغير للمشتري إلا إذا كان تعرضاً قانونياً، كأن يقوم الغير بإدعاء حق على المبيع، كحق الملكية مثلاً أو الانتفاع أو الارتفاق، أما التعرض المادي الصادر من الغير كالاغتصاب والسرقة، فإن البائع لا يسأل عنه، وعلى المشتري أن يدفع هذا التعرض بالطرق القانونية، والتعرض المادي الذي لا يسأل البائع عنه هو الذي يقع بعد تسليم المبيع، وقبل حصوله يقع عبء الالتزام به على البائع، وإلا كان مخالفاً بالتزامه بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق^(١).

الشرط الثاني: استناد التعرض إلى سبب سابق على البيع أو راجعاً إلى فعل البائع:

ويشترط لضمان التعرض الصادر من الغير للمشتري أن يكون سبب التعرض موجوداً وقت البيع، كأن يستند المتعرض إلى أنه كان

(١) د. توفيق حسن فرج - فقرة ٨٤.

يملك العقار المبيع قبل البيع، وأن البائع قد باع ما لا يملك، أو أن يستند الغير في تعرضه إلى وجود حق ارتفاق، أو انتفاع أو سكنى، أو حكر أو رهن كان موجوداً قبل البيع، أو كان الغير واضعاً يده على المبيع، واكتملت مدة التقادم المكسب قبل الوقت الذي تم فيه انعقاد البيع.

أما التعرض الصادر بعد البيع فإن البائع لا يضمنه بحسب الأصل إلا إذا كان راجعاً إلى فعله، مثل أن يقوم ببيع العقار مرقتانية إلى مشتر ثان، يسبق في تسجيل عقده، فهذا الحق قد ثبت بعد البيع الأول، ومرجعه لفعل البائع نفسه، وهنا يلتزم بالضمان^(١).

فالبائع يضمن كل حق يستند إليه الغير بسبب سابق على البيع أو لاحق عليه وكان بفعله، فلو كان بفعل المشتري نفسه فلا ضمان على البائع، كما لو أهمل قطع التقادم الذي بدأه الغير، وكذلك لو كان بفعل قوة قاهرة، أو حادث عرضي لا يسأل عنه البائع، مثل نزع ملكية العقار لمنفعة العامة، فالمخاطر بعد البيع تقع على عاتق المشتري.

الشرط الثالث: أن يكون التعرض حالات:

والمراد بالتعرض الحال: أن يكون الغير قد اتخذ موقفاً إيجابياً استناداً إلى حقه، ويكون من شأنه أن يحول بين المشتري وبين الانتفاع بالمبيع، أو يقلل من هذا الانتفاع، ويتم هذا في الغالب في صور دعوى يرفعها الغير على المشتري مطالباً فيها بالحق الذي يدعيه على المبيع

(١) د. السنهوري - فقرة ٣٤٠.

باعتباره مالكا له، فيدفع الغير بأن له حقاً على المبيع كحق انتفاع أو رهن مثلاً^(١).

ومجرد الخشية من حصول التعرض لا تعتبر تعرضاً، ومع ذلك فإن هذا لا يعنى حرمان المشتري من كل حماية مع وجود خطر التعرض والاستحقاق قبل وقوع التعرض بالفعل، فالقانون يعطيه وسائل يتوقى بها ما ينجم عن ذلك من مضار مثل حبس الثمن حتى يزول الخطر، مادة (٢/٤٥٧) كما أن له ان يطلب بالفسخ طبقاً للقواعد العامة، وله أن يطعن في البيع باعتباره أنه بيع لملك الغير، مادة (٤٦٦) مدنى، وذلك إذا اكتشف أن المبيع لم يكن مملوكاً للبائع^(٢).

ثانياً: أحكام ضمان التعرض الصادر من الغير:

إذا تعرض الغير للمشتري تعرضاً قانونياً، يترتب عليه إخلال فعلي للانتفاع بالعين المبيعة وتوافرت شروط الالتزام بالضمان وجب على البائع دفع هذا التعرض، أى أن يقوم بتنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً، فإذا نجح في ذلك كان موفياً لالتزامه، وإذا لم ينجح واستحق المبيع لغير استحقاق كلياً أو جزئياً، كان للمشتري أن يرجع على البائع بالتعويض، أى بالتنفيذ عما لحقه من أضرار، ونبين أولاً: التنفيذ العيني، وثانياً: ضمان الاستحقاق.

(١) د. السنهورى - فقرة ٣٤٠.

(٢) د. جميل الشرقاوى - فقرة ٦٧.

(أ) التنفيذ العيني:

إذا حدث تعرض للمشتري وجب على البائع أن يدفع هذا التعرض، ويختلف نطاق حقوق المشتري عند حصول التعرض في حالة إخطار البائع بالتعرض، عنه في حالة عدم الإخطار.

(١) حالة إخطار البائع بالتعرض:

إذا أخطر المشتري البائع بدعوى الغير، وجب على البائع أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري لدفعها، أو يحل محله فيها إذا لم يرغب المشتري في السير فيها، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٤٤٠) مدنى بقولها: "إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع، وأخطر بها البائع، كان على البائع بحسب الحوال وفقاً لقانون المرافعات أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري، أو يحل فيها محله، فإذا حصل الإخطار، فإما أن يتدخل البائع أو لا يتدخل، فإذا تدخل في الدعوى فقد يؤدي تدخله إلى رفض دعوى المعارض، ويكون البائع في هذه الحالة قد نفذ التزامه بدفع التعرض تنفيذاً عينياً، أما إن حكم للمدعى بالاستحقاق، كان البائع مخلاً بالتزامه، لأنه لم يحقق النتيجة، فيكون ضامناً للاستحقاق أى ملتزماً بالتعويض.

وإذا لم يتدخل المشتري في الدعوى رغم إخطاره، وتولى المشتري الدفاع وحده، وانتهى الأمر بالاستحقاق للمدعى، وجب الضمان على البائع، إلا إذا ثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري، أو خطأ جسيم منه، وهذا ما ذكرته الفقرة الثانية من المادة (٤٤٠) مدنى، بقولها: "فإذا تم الإخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى وجب عليه الضمان، إلا إذا ثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري أو خطأ جسيم منه".

فإذا رفع الغير دعوى على المشتري باستحقاق المبيع، كان على المشتري أن يخطر البائع بها في الوقت المناسب حتى يستطيع أن يتبصر في وسائل الدفاع عن الحق الذي باعه^(١).

وليس لهذا الإخطار شكل خاص، فقد يتم بإنذار رسمي على يد محضر، أو بخطاب مسجل أو غير مسجل، وقد يتم مشافهة في هذه الحالة يجب على المشتري أن يتحمل عبء إثبات حصوله.

كما أن للمشتري أن دخل البائع في الدعوى بدلاً من إخطاره بها عملاً بأحكام المادة (١١٧) مرافعات.

(٢) حالة عدم إخطار البائع بالتعرض:

فإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم، وسار فيها وحده فخرها، بأن حكم للأجنبي بالاستحقاق، فإنه مع ذلك يكون

(١) مجموعة الأعمال التحضيرية - ج٤ - ص ٨٥.

للمشتري حق الرجوع بالضمان على البائع، رغم أنه لم يخطره، إلا أنه يكون للبائع أن يتخلص من الضمان بإثبات أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفضها، وهذا ما قرره المادة (٤٤٠) مدنى، بقولها: "وإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضى به، فقد حقه في الرجوع بالضمان، إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى، كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق^(١).

تصالح المشتري مع الغير أو اعترافه بحقه:

وقد أجاز المشرع للمشتري إذا قدر أحقية الغير في دعواه، أو تزامى له أن السير في الدعوى غير مجد، وأراد أن يتجنب النفقات ومضاق الاستمرار في التقاضى، أن يعترف بحق الغير، أو يتصالح معه، وفي هذه الحالة فإن حق المشتري - طالما أنه كان حسن النية - يظل قائماً قبل البائع في الضمان، ومع ذلك فإنه يكون معرضاً لفقدان حقه في مطالبة البائع بضمان الاستحقاق إذا استطاع البائع أن يثبت أن الغير لم يكن محقاً في دعواه بالاستحقاق، وهذا ما قرره المادة (٤٤١) مدنى، بقولها: "يثبت حق المشتري في الضمان، ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه فإذا تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائى، متى كان قد أخطر البائع

(١) د. السنهورى - فقرة ٣٥٠.

بالدعوى في الوقت الملائم، ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل، كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق في دعواه".

توفى المشتري استحقاق المبيع:

وقد يرغب المشتري في توفى استحقاق المبيع، بدفع مبلغ من المال للمتعرض، وهنا تقضى العدالة بأن يعوضه البائع عما دفعه في توفى استحقاق الغير للمبيع أو ثبوت حقه عليه، خاصة وأن البائع في النهاية سيلتزم بتعويض المشتري لو استحق المبيع، وقد نصت على هذا المادة (٤٤٢) مدنى، بقولها: "إذا توفى المشتري استحقاق المبيع كله أو بعضه، بدفع مبلغ من النقود، أو بأداء شيء آخر، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان، بأن يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات".

وهذه الرخصة تقتصر على حالة توفى المشتري الحكم بالاستحقاق باتفاقه مع المتعرض، أى قبل صدور الحكم، أما إذا كان الحكم قد صدر للأجنبي باستحقاقه للعين المبيعة، ثم اتفق معه المشتري على أن يترك له العين في مقابل مبلغ معين، فإن للمشتري أن يرجع بضمان الاستحقاق على البائع، وليس للبائع أن يتخلص من الضمان برد المبل الذي دفعه المشتري^(١).

(١) د. السنهورى - فقرة ٣٤٣.

الفرع الثالث

ضمان الاستحقاق

إذا استحق المبيع، فإنه يجوز للمشتري أن يرجع على البائع بقيمة الاستحقاق، وهى تختلف بالطبع في حالة الاستحقاق الكلى عنها في حال الاستحقاق الجزئى، وقد بين القانون الأحكام التى يتم بمقتضاها التعويض في هذه الحالة، وذلك في المادتين (٤٣٣، ٤٤٤) مدنى، ونبين كلاً من هذين الموضوعين:

الموضوع الأول

التعويض في حالة الاستحقاق الكلى

يراد بالاستحقاق الكلى: حرمان المشتري على نحو كامل من الحق المبيع كله، كما إذا اتضح أن البائع قد باع ما لا يملك حكم للمالك الحقيقى باستحقاق المبيع، وقد يثبت هذا الحكم بحكم قضائى أو بدون حكم.

ومن أمثلة الاستحقاق الكلى، قيام الدائن المرتهن بالتنفيذ على العقار المبيع تحت يد المشتري، مادة (١/٨٠) مدنى، أو صدور حكم بإبطال البيع أو فسخ سند ملكية البائع^(١).

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - فقرة ٣١٧.

وقد عرض المشرع في المادة (٤٤٣) مدنى، لبيان عناصر التعويض الذي يلتزم البائع بالقيام بأدائه للمشتري في حالة الاستحقاق الكلى للمبيع، توفى تعويض المشتري على نحو كامل عما لحقه من ضرر، وما فاتته من كسب بسبب استحقاق المبيع، وذلك حين نصت على أن المبيع إذا استحق كله كان للمشتري أن يطلب من البائع:

- (١) قيمة المبيع وقت الاستحقاق، والفوائد القانونية منذ ذلك الوقت.
- (٢) قيمة الثمار التى ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع.
- (٣) المصروفات النافعة التى لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق، وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية.
- (٤) جميع مصروفات دعوى الضمان والاستحقاق، عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة (٤٤٠).

(٥) وبوجه عام؛ تعويض المشتري عمل لحقه من خسارة أو فاتته من كسب بسبب استحقاق المبيع، كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.

ومن هذا النص يستبين أن عناصر التعويض تتمثل فيما يلى:

أولاً: قيمة المبيع وقت الاستحقاق وفوائده القانونية:

فيلتزم البائع بان يدفع للمشتري قيمة المبيع وقت رفع دعوى الاستحقاق، لأن الحكم بالاستحقاق يستند إلى وقت رفع الدعوى، سواء أكانت هذه القيمة أكثر أم أقل من الثمن الذي دفعه للبائع، حيث إننا

لسنا بصدد دعوى إبطال أو فسخ، فيطالب المشتري البائع باسترداد الثمن، وإنما بصدد ضمان الاستحقاق، الذي يرجع أساسه إلى حرمان المشتري من البيع، فيكون من العدل أن يتم التعويض على أساس قيمته في الوقت الذي حرم فيه وقت الاستحقاق^(١).

كما أن للمشتري أن يطالب بالفوائد القانونية من وقت الاستحقاق خروجاً على ما تقضى به القواعد العامة من استحقاق الفوائد من وقت المطالبة القضائية، مادة (٢٢٦) مدنى، ووجهة الذين قرروا الفوائد بهذا النص، أما المشتري سيحرم من المبيع من وقت الاستحقاق، فمن الملائم أن يستعاض عنه بالفوائد القانونية من هذا الوقت، حتى ولو كان المبيع غير مثمر، وسواء كان يعلم بسبب الاستحقاق وقت البيع أم كان لا يعلم، ومن المعروف أن الفوائد المستحقة عن الديون المؤجلة، زيادة في غير مقابل وهى تمثل رباً تحرمه الشريعة الإسلامية، وفي حالتنا فإن قيمة المبيع تمثل ديناً ثابتاً في ذمة البائع للمشتري من وقت الاستحقاق، فما زاد عليها يعتبر في مقابل ائتمن وهو لذلك يعتبر رباً محرماً.

ثانياً: قمية ما التزم المشتري برده لمن استحق المبيع من ثمار:

كما يرجع المشتري على البائع بقيمة بالثمار التى التزم بردها لمن استحق المبيع، والثمار التى يلتزم المشتري بردها هى كافة الثمار

(١) د. السنهورى - فقرة ٣٥٢.

التي قبضها وهو سيء النية، أى وهو يعلم بحق المستحق على المبيع، مادة (٩٧٩) مدنى.

ومن ثم فإنه إذا كان المشتري بعلم أن للغير حقاً في المبيع قبل رفع دعوى الاستحقاق فإنه يرد الثمار إلى المستحق من وقت علمه بهذا الحق، ويكون له أن يرجع على البائع بقيمة هذه الثمار، أما ثمار المبيع من وقت رفع الدعوى فلا رجوع بقيمتها على البائع، وإن كان ملزماً بردها للمستحق باعتباره شيء النية، لأنه بعد رفع دعوى الاستحقاق يكون عالماً على كل حال بحق المدعى بالاستحقاق، مادة (٢/٩٦٦) مدنى.

ثم إنه لا يرجع بها على البائع، لأنه قد استعاض عن هذه الثمار بالفوائد القانونية لقيمة المبيع، وهى تسرى من وقت الاستحقاق^(١).

ثالثاً: المصروفات التى أنفقها المشتري على المبيع:

وقد يقوم المشتري بإنفاق بعض المصروفات على المبيع قبل أن يحكم عليه باستحقاقه للغير، فما مدى استحقاقه لرد تلك المصروفات؟

الثابت أن الحكم يختلف بحسب نوع المصروفات، وما إذا كانت ضرورية أو نافعة أو كمالية.

(١) مجموعة الأعمال التحضيرية - ج٤ - ص ٩٦.

(أ) المصروفات الضرورية:

وهي المصروفات اللازمة لحفظ المبيع وصيانته، وهذه يكون المشتري أن يرجع بها على المستحق، ولا يطالب بها البائع وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (١/٦٨٠) مدنى، التى تقضى بأنه: "على المالك الذي يرد إليه ملكه ان يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية، ويستوى في هذا الخصوص أن يكون المشتري حسن النية أم سيء النية.

(ب) المصروفات المنفعة:

وهي التى تؤدى إلى زيادة قيمة المبيع، كابناء في العين والغراس فيها، وهذه يسرى بشأنها أحكام الالتصاق، ويفرق فيها بين ما إذا كان الحائز حسن النية أو سيئها.

(١) فإذا كان المشتري حسن النية:

يخير المستحق بين يرد قيمة المصروفات (قيمة المواد وأجرة العمل) أو قيمة ما زاد في ثمن العيب بسبب هذه المصروفات، مادة (٩٢٥) مدنى، وطبيعي أن المستحق سيختار أقل القيمتين ومن ثم يكون للمشتري حق الرجوع على البائع بالفرق^(١).

(٢) وإذا كان المشتري سيء النية:

بأن كان عالماً وقت إنفاقها بسبب الاستحقاق، كان للمستحق أن يطلب إزالة المنشآت خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامتها،

(١) د. إسماعيل غانم - فقرة ١٦٠.

أو أن يطلب استبقاءها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة، أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في الأرض بسبب إقامة هذه المنشآت، مادة (٩٢٤) مدنى، ووضح أن المشتري لن يسترد جميع ما أنفقه فيكون له أن يرجع على البائع بالفرق.

(ج) المصروفات الكمالية:

وهى ما ينفق على الشيء بقصد الزينة والزخرفة، وهذه لا تجب على المستحق طبقاً للمادة (٣/٩٨٠) مدنى، والتى تقضى بأنه إذا كانت المصروفات كمالية، فليس للحائز ان يطالب بشيء منها، ومع ذلك يجوز للمشتري أن ينزع ما ستحدثه من منشآت، إلا إذا اختار المستحق استبقاءها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة، وليس للمشتري أن يرجع على البائع بهذه المصروفات إلا إذا كان سيء النية، أى يعلم سبب الاستحقاق وقت البيع، مادة (٤٤٣) مدنى^(١).

رابعاً: مصروفات دعوى الاستحقاق:

كما أن للمشتري أن يرجع على البائع بمصروفات دعوى الاستحقاق التى رفعت عليه من قبل المستحق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى.

خامساً: تعويض المشتري عما لحقه من خسارة وما فاتته من كسب:

والمقصود من التعويض في هذه الحالة تعويض المشتري عن كل خسارة لحقت به أو كسب فاتته، مما لا تسجله أى حالة من الحالات السابقة، فيستطيع أن يطالب البائع بمصاريف تحرير العقد

(١) راجع: مجموعة الأحكام التحضيرية - ج٤ - ص ٩٦.

والسمسرة ورسوم التسجيل، وغير ذلك مما يلحقه من أضرار بسبب استحقاق المبيع وفقاً للقواعد العامة في المسؤولية العقدية.

الموضوع الثانى

التعويض في حالة الاستحقاق الجزئى

وقد بينت المادة (٤٤٤) مدنى، أحكام التعويض بسبب الاستحقاق الجزئى بقولها: " ١- إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلاً بتكاليف، وكانت خسارة المشتري من ذلك بلغت قدرًا لو علمه لما أتم العقد، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة، على أن يرد له المبيع وما أفاد منه. ٢- فإذا اختار المشتري استيفاء المبيع، أو كانت الخسارة التى لحقت به لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق".

ويبدو من هذه المادة أنه يجب التفرقة بين الخسارة الجسيمة والخسارة غير الجسيمة، في حالة تعويض المشتري عن الاستحقاق الجزئى.

أولاً: الخسارة الجسيمة:

وتقدير جسامه الخسارة متروك لقاضى الموضوع، دون رقابة عليه من محكمة النقض، ومن أمثلته: استحقاق جزء من أرض اشتراها شخص لإقامة شمرع عليها، أو يثبت للغير حق انتفاع بالسكنى على المنزل الذي اشتراه المشتري ليسكن فيه.

وفي هذه الحالة يكون المشتري بالخيار بين رد المبيع ونا أفاده منه للبائع، ومطالبته بالتعويض كما لو كان الاستحقاق كلياً طبقاً لمادة (٤٤٣) مدنى، وبين أن يستبقى المبيع بحالته على أن يرجع على البائع بالتعويض عما أصابه بسبب الاستحقاق الجزئى^(١).

ثانياً: الخسارة غير الجسيمة:

وفيها يتعين على المشتري أن يستبقى المبيع وبطالب البائع بالتعويض عن الجزء المستحق مع مراعاة أن يشمل التعويض كل ما أصاب المشتري من أضرار بسبب الاستحقاق الجزئى، أى على أساس ما لحقه من خسارة وما فاتته من كسب، طبقاً للمادة (٢٢١) مدنى.

الاتفاق على تعديل أحكام الضمان:

من المعروف أن قواعد الضمان ليست آمرة تطبق حتماً في كل حالة، وإنما هى قواعد مكملية يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ما يخالفها، ولهذا يجوز للمتعاقدين تنظيم أحكام الضمان بالزيادة أو النقص بقواعد اتفاقية يمكن أن يسمى الضمان معها بالضمان الاتفاقى.

والأصل في هذه الحالة أن الضمان سيخضع للاتفاق، فإذا لم يوجد سرت أحكام النصوص القانونية المقررة في المواد (٣٤٩) وما بعدها.

(١) مجموعة الأعمال التحضيرية - ج٤ - ص ١٠١.

وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (٤٤٥) مدنى، صراحة على أنه يجوز للمتعاقدین باتفاق خاص أن یزیداً فی ضمان الاستحقاق أو ینقصاً منه، أو أن یسقطاً هذا الضمان، وقد وضعت الفقرة الثانية حكماً خاصاً بحقوق الارتفاق، أنشأ المشرع فیة قرينة قانونية على أن البائع قد اشترط عدم الضمان فیما یتعلق بحق الارتفاق المرتب على العین المبیعة، إذا كان هذا الحق ظاهراً، أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري.

وإذا اشترط البائع إعفاءه من الضمان كله أو بعضه، وكان قد تعدد إخفاء حق لأجنبي، فإن هذا الشرط یقع باطلاً، ولا یعفى البائع من شيء عملاً بالفقرة الثالثة من المادة (٤٥) مدنى.

هذا ویلاحظ أنه إذا استوفى الإعفاء شروطه وكان صحيحاً، فإنه لا یترتب علیه بأى حال إعفاء البائع من المسؤولية عن أى استحقاق ینشأ من فعله، ویقع باطلاً كل اتفاق یقضى بغير ذلك، مادة (١/٤٤٦) مدنى.

أما إذا كان الاستحقاق قد نشأ عن فعل الغير، فإن الاتفاق على عدم الضمان یعفى البائع من التزامه بالتعويضات التى یتستحقها المشتري، ولكنه لا یعفيه من دفع قيمة المبيع وقت الاستحقاق إلا إذا أثبت أن المشتري كان یعلم وقت البيع سبب الاستحقاق، أو أنه قد اشترى ساقط الخيار (أى مخاطراً بتحمل نتائج استحقاق المبيع للغير).

المطلب الثانى

ضمان العيوب الخفية

لا يقتصر ضمان البائع على ضمان التعرض والاستحقاق، وإنما يشمل أيضاً ضمان العيوب الخفية التى تجعل المبيع غير صالح لتحقيق غاية المشتري من شرائه، وقد نظم المشرع ضمان العيوب الخفية في المواد (٤٤٧ - ٤٥٥) مدنى، ويبدو من خلال تلك المواد أن المشرع قد جعل للمشتري دعوى خاصة بضمان العيوب، ولم يشأ أن يتركه للقواعد العامة في هذا الشأن، والكلام عن ضمان العيوب الخفية يتناول شروط العيب الموجب للضمان، وأحكام الضمان، والاتفاق على تعديل أحكام الضمان، ونخصص لكل موضوع فرعاً.

الفرع الأول

شروط العيب الموجب للضمان

يجب حتى يكون العيب موجباً للضمان أن تتوافر فيه شروط معينة نص المشرع في المادتين (٤٤٧ ، ٤٤٨) مدنى.

وقد نصت المادة (٤٤٧) مدنى، على أنه: "يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التى كفل للمشتري وجودها فيه، وإذا كان بالمبيع عيب ينقض من قيمته، أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد، أو مما

هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.

ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه، لو أنه فحص البيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من العيب، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه".
كما تنص المادة (٤٤٨) مدنى، على أنه: "لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه".

ويبدو من هاتين المادتين أنه يشترط في العيب الموجب لضمان البائع، أن يكون قديماً وأن يكون مؤثراً، وأن يكون خفياً، وألا يكون في البيوع التي لا ضمان فيها، ونبين هذه الشروط:
أولاً: أن يكون العيب قديماً:

والعيب القديم هو الذي يكون موجوداً في المبيع وقت تسليمه من البائع، كإصابة الحيوان بجرثومة العرض وهو في يد البائع، أو وجود السوس في الخشب قبل التسليم ولا تظهر آثاره إلا بعده، فالبائع لا يضمن إلا العيب الموجود بالمبيع عند انعقاد العقد، وكذلك العيب الذي يطرأ عليه بعد البيع وحتى وصول التسليم، أما إذا حدث العيب بعد التسليم فإنه لا يدخل في ضمان البائع وإنما يتحمل المشتري تبعته، أو يرجع على من يكون مسؤولاً عن إحداثه^(١).

(١) د. السنهورى - فقرة ٣٦٦.

ثانياً: أن يكون العيب مؤثراً:

ووفقاً لما ورد في نص المادة (٤٤٧) مدنى، يعتبر العيب مؤثراً إذا كان ينقص من قيمة المبيع أو نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو الغرض الذي أعد له. وبناء على ذلك، فإن البائع لا يضمن العيب إلا إذا كان مؤثراً، أى على قدر معين من الجسامة، وتقدير جسامة العيب متروك لقاضى الموضوع، يفصل فيها بحسب المعايير السابقة، وكلها معايير موضوعية لا شخصية، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة (٤٤٨) مدنى، من أنه: "لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه"، وأساس ذلك أن جريان العرف على التسامح في العيب، دليل على أن النقص فيه يسير، أو غير مؤثر، كإحتواء القمح مع قليل من الأتربة، أو وجود بعض املواد الغريبة في السمسم بنسبة لا تزيد عن النسبة المتفق عليها بين المتعاقدين^(١).

ثالثاً: أن يكون العيب خفياً:

والعيب الخفي هو الذي يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع، أو لا يتبينه الشخص العادى، أو لا يكشفه غير خبير، أو لا يظهر إلا بالتجربة، ومن ثم يعتبر العيب خفياً إذا لم يكن باستطاعة المشتري أن يتبينه وقت البيع، إذا فحص المبيع بعناية الرجل العادى، والمعيار الذي يتبينه المشرع معيار شخصي لا موضوعى، فلا يعتد بقدره

(١) د. منصور مصطفى منصور - فقرة ٨٩.

المشتري نفسه، بل بقدرة الرجل العادى، ولو كان المبيع من الأشياء التى يقتضى فحصها خبرة خاصة، فيجب على المشتري أن يلجأ إلى أهل الخبرة للاستعانة بهم، فلو كان المبيع منزلاً وجب أن يستعين المشتري بمهندس معمارى، وإذا كان المبيع آلة بخارية فإن الخبرة المطلوبة في هذه الحالة هى خبرة من له إلمام بالآلات البخارية وهكذا، وبالنسبة لهذه الأشياء التى يقتضى فحصها الالتجاء إلى أهل الخبرة، ولا يعتبر العيب خفياً إلا إذا كان الرجل العادى لا يستطيع أن يتبينه، ولو قعد المشتري عن الاستعانة بأهل الخبرة مكتفياً بالفحص الشخصي مع نقص خبرته فلم يكتشف ما في المبيع من عيب، فلا يكون له أن يرجع على البائع بضمان العيب.

ويضمن البائع العيب الخفى سواء كان يعلم به أو لا يعلم، كما يضمن العيب الخفى الوجود وقت البيع، ومع ذلك فإن البائع يلتزم بضمان العيب ولو كان من العيوب الظاهرة في حالتين نصت عليهما المادة (١/٤٤٧) مدنى، وهما:

(١) إذا أكد البائع للمشتري خلو المبيع من العيب:

حيث يعتمد المشتري على ذلك ولا يقوم بفحص المبيع، ولذلك يظل البائع ملتزماً بالضمان بالرغم من ظهور العيب.

(٢) أو إذا أثبت المشتري أن البائع قد تعدد إخفاء العيب غشاً منه، مثل أن يتعمد بائع السيارة إخفاء كسر بموتورها، وهذين

الاستثناءين لا يردان إلا في حالة ما إذا كان العيب ظاهراً، وبشرط يخطره به خلال مدة معقولة، فإذا لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع.

(٣) وأما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري وجب عليه أن يخطره به البائع بمجرد ظهوره، وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.

وفيد هذا النص أنه: يجب على المشتري أن يبادر إلى التحقق من حالة المبيع متى تسلمه، وبمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا ما بدا له عيب يوجب الضمان - وفقاً للشروط السابق ذكرها - وجب عليه أن يبادر إلى إخطار البائع به خلال مدة معينة، وتحديد تلك المدة المعينة مسألة موضوعية يقدرها قاضى الموضوع في ضوء ظروف كل حالة، فإذا لم يفعل ذلك اعتبر قابلاً للمبيع ولا يكون له أن يرجع على البائع بالضمان، والمراد بالتسليم هنا، هو التسليم افعلى، وليس الحكمى، أى حيازة الشيء، والاستيلاء عليه مادياً^(١).

ولم يحدد القانون شكلاً معيناً للإخطار، فيجوز أن يكون بإخطار على يد محضر، وبخطاب مسجل أو بخطاب عادى، ويجوز أن يكون شفوياً بشرط إمكان إثباته، وعبء الإثبات يقع على عاتق المشتري، ويجوز له إثباته بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك البيئة والقرائن.

(١) د. عبد الفتاح عبد الباقي - فقرة ١٦٩.

ثانياً: الحقوق المقررة للمشتري في دعوى الضمان:

وإذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم، كان له أن يرجع بالضمان على النحو الموضح بالمادة (٤٤٤) مدنى، ذلك ما نصت عليه المادة (٤٥٠) مدنى، وبهذا يكون المشرع قد أحال بالنسبة لأحكام ضمان العيوب الخفية على المادة (٤٤٤) مدنى، الخاصة بالاستحقاق الجزئى على نحو ما سبق.

وهذه المادة تفرق بين جسامة العيب وعدم جسامته، والخسارة الجسيمة هى التى بلغت قدرًا لو علمه المشتري لما أتم العقد، وحالتئذ يكون له الحكم بتعويض الاستحقاق الكلى بشرط أن يرد المبيع وما أستفاده منه، أو أن يستبقى المبيع مع المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب العيب.

وإذا كان العيب غير جسيم، فليس للمشتري أن يطلب الفسخ ولكن يكون له المطالبة بالتعويض العينى المتمثل في قيام البائع بإصلاح العيب إن قبل ذلك، أو الحكم بالتعويض النقدى، والخيار في كلا الأمرين أمر متروك لتقدير المحكمة^(١).

ثالثاً: هلاك المبيع وأثره على الرجوع بالضمان:

وإذا ظهر في المبيع عيب نشأ بمقتضاه حق للمشتري في الرجوع بالضمان العيب على البائع، فإن هلك المبيع بعد ذلك، فإن هلاكه لا يؤدي إلى سقوط حق المشتري في مطالبة البائع بالضمان

(١) د. إسماعيل غانم - فقرة ١٧٧.

مهما كان سبب الهلاك، يستوى أن يكون الهلاك بسبب العيب ذاته، أو بسبب أجنبي، أو بفعل المشتري، ولكن حقوق المشتري ستختلف بالطبع باختلاف سبب الهلاك.

وبداية فقد نصت على ذلك المادة (٤١٥) مدنى، بقولها: "تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأى سبب كان".

فإذا كان الهلاك بسبب العيب نفسه:

كتهدم منزل واه، او موت حيوان مريض، هنا يكون للمشتري ان يرجع على البائع بالتعويض الكامل دون أن يرد له شيئاً إذا كان الهلاك بسبب العيب كلياً، أما إذا كان الهلاك جزئياً كان على المشتري أن يرد ما بقى من المبيع.

ويبدو من هذا النص:

أن المدة التى تسقط بها دعوى ضمان العيب الخفى هى سنة من تاريخ تسليم المبيع، ومدة السنة هذه قصيرة نسبياً، ولكن القصد من هذا التقصير العمل على استقرار الصفقة، ومن ثم استقرار التعامل.

والعبرة بالتسليم الذي يعتبر تمامه بدءاً للتقادم هو التسليم الفعلى وليس الحكمى، لأن الأول هو الذي يهيئ الفرصة للمشتري لفحص المبيع على النحو الذي يتمكن معه من كشف العيب^(١)، ويجوز للبائع والمشتري أن يتفقا على مدة أطول من مدة السنة للضمان مادة (١/٤٥٢) مدنى.

(١) د. أنور سلطان وجلال العدوى - فقرة ٤٠٦.

أما الاتفاق على مدة أقصر من مدة السنة للضمان، فالراجح في الفقه انه لا يجوز، لأن الاتفاق على إطالة المدة استثناء يجب ألا يتوسع فيه.

ويراعى أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بسقوط دعوى المشتري بمضى سنة في التشريع المصري، ويلاحظ أن جعل تبعة الهلاك مرتبطة بالتسليم يتفق مع اتجاه الفقه الإسلامي في هذه المسألة.

شروط صحة الاتفاق على نقصان أو إسقاط الضمان:

ويشترط لصحة الاتفاق على إسقاط أو نقصان الضمان، ألا أن يكون البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشاً منه، فلو كان البائع قد تعمد ذلك فإن الاتفاق يكون باطلاً، فيظل ضامناً للعيب ولا يكفى مجرد علم البائع لوجود عيب معين في المبيع، ما دام أنه لم يتعمد إخفاءه عن المشتري.

ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة:

وإذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من تاريخ ظهوره، وأن يرفع الدعوى في مدة ستة أشهر من هذا الإخطار، وإلا سقط حقه في الضمان، هذا ما لم يتفق على غير ذلك مادة (٤٥٥) مدنى.

وهذا الحكم يعتبر صورة من صور تعديل أحكام الضمان، وهو كثير الوقوع في الحياة العملية، وخاصة في بيع الآلات الدقيقة كالراديو والساعات والسيارات وآلات التصوير، وغيرها. وقد يتفق على زيادة مدة الضمان بخمس سنوات مثلاً أو على نقصانها لمدة ستة أشهر.

الفصل الثانى

التزامات المشتري في عقد البيع

الفصل الثانى

التزامات المشتري في عقد البيع

يقع على عاتق المشتري في عقد البيع ثلاثة التزامات هى:
الالتزام بدفع الثمن، والالتزام بمصاريف عقد البيع، والالتزام بتسليم
المبيع، ونبين هذه الالتزامات الثلاثة في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول

التزام المشتري بدفع الثمن

ويقع على عاتق المشتري الالتزام بدفع الثمن، وهو التزام يقابل في أهميته التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري.

والثمن يعينه المتعاقدان، وقد يحدد في العقد، وقد يحدد بعد ذلك تبعاً لأسس التقدير التي يتم الاتفاق عليها، وعلى المشتري نفقات دفع الثمن، كمصاريف إرساله إلى البئع في مكان الوفاء به مادة (٣٨٤) مدنى، كما يلحق به الفوائد القانونية، مادة (١/٤٥٨) مدنى، مع مراعاة أن الفوائد الربوية حرام في الشريعة الإسلامية ويستحق البائع فوائد قانونية على الثمن في حالتين:

الأولى: إذا كان الثمن مستحق الأداء، وقام البائع بإعذار المشتري للوفاء به، فإنه يستحق من وقت هذا الإعذار على الثمن فوائد لمصلحة البائع، وهذا مخالف للقواعد القانونية التي تقضى باستحقاق الفوائد من وقت المطالبة القضائية^(١).

الثانية: أن يكون البائع قد قان بتسليم المبيع للمشتري، وأن يكون الشيء الذي ورد عليه البيع قابلاً لأن ينتج ثمراً، أو يغل أى إيراد آخر، ويلزم أن يكون الثمن مستحقاً، كما هو الحال في الحالة الأولى حتى تحتسب فوائد عليه من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج الثمار،

(١) د. جميل الشرقاوى - ص ٢٣٧.

وعلى إلزام المشتري بالفوائد القانونية من هذا الوقت يتمثل في الرغبة في تجنب جمع المشتري بين فائدة المبيع من الإيرادات والثمار، وفائدة الثمن، مع العلم بأن الفوائد على الديون تعتبر رباً محرماً في الشريعة الإسلامية، كما سبق ذكر ذلك مراراً.

مكان الوفاء بالثمن:

تقضى المادة (٤٥٦) مدنى، بأنه: "١- يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك. ٢- فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن".

وهذا النص يفرق بين حالتين

الأولى: حالة استحقاق دفع الثمن وقت تسليم المبيع:

وفي هذه الحالة يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، وهذا مخالف للقاعدة العامة التى توجب الوفاء بالثمن في موطن المدين، وقت الوفاء، أو المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين، إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال، مادة (١/٣٤٧) مدنى، وذلك إذا كان محل الالتزام شيئاً غير معين بالذات، حتى ينفذ العقد جملة واحدة فيدفع الثمن وقت تسليم المبيع.

الثانية: حالة عدم استحقاق دفع الثمن وقت تسلم المبيع:

وقد يتفق على دفع الثمن قبل تسليم المبيع أو بعد تسليمه، وفي هذه الحالة لا يرتبط الوفاء بالتسليم، ويجب العودة إلى القاعدة العامة التي تقضى بأن الوفاء بالثمن يكون في موطن المدين به، وهو المشتري وقت الوفاء، أو في مركز أعماله، إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال، مادة (١/٣٤٧) مدنى.

جزاء إخلال المشتري بالتزامه بالوفاء بالثمن:

وإذا اخل المشتري بالتزامه بالوفاء بالثمن يجوز للبائع أن يجبره على الوفاء به، وذلك بحبس المبيع إذا لم يكن قد سلمه له، وقد قرر القانون له أولوية في استيفاء الثمن من المبيع على دائنى المشتري الآخرين، من خلال الامتياز المقرر للبائع على المبيع عقاراً كان أو منقولاً مادة (١٤٥ ، ١٤٧) مدنى، كما أن للبائع أن يطلب فسخ البيع، إذا لم يقم المشتري بدفع الثمن، مادة (٢/١٥٧) مدنى، هذا الفسخ يقع بقوة القانون دون حاجة إلى حكم من القضاء لتقريره ودون حاجة إلى إعدار المشتري، وذلك بالمخالفة للقواعد العامة، مراعاة لأن عروض التجارة كثيراً ما تتقلب أسعارها، وغالباً ما تتلف بسرعة فلا تتحمل طول الإجراءات، ويقع الفسخ في بيع المنقول طبقاً للمادة (٤٦١) مدنى، إذا توافرت ثلاثة شروط:

١. ان يكون المبيع منقولاً كالسلع والبضائع وغيرها.

٢. أن يكون هناك اتفاق على ميعاد واحد لدفع الثمن وتسلم المبيع،
ويتحدد الميعاد بالاتفاق، أو العرف، ولو اختلف ميعاد التسليم عن
ميعاد دفع الثمن لا يسرى هذا الحكم، ويرجع للقواعد العامة^(١).
٣. وأن يخل المشتري بالتزامه بدفع الثمن في موعده، وليس تمسكاً
بحقه في الحبس بسبب عدم تسليم البائع للمبيع.
والحق في الفسخ مقرر لمصلحة البائع وحده، فله أن يتغاضى
عن وقوعه، ويطلب إلى المشتري الوفاء بالثمن بعد الموعد المحدد إن
وجد مصلحته في ذلك، ولا يجوز للمشتري أن يتمسك باعتبار العقد
مفسوخاً من تلقاء نفسه، لأنه هو المقصر، فلا يجوز أن يستفيد من
تقصيره، كما أن هذا الحكم ليس آمراً فيجوز الاتفاق على خلافه.

(١) د. السنهوري - فقرة ٤١٦.

المبحث الثانى

التزام المشتري بالمصروفات

نصت المادة (٤٦٢) مدنى، على أن: "نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة والتسجيل وغير ذلك من المصروفات تكون على المشتري ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك".

وهذا النص يعتبر تقنياً لما يجرى عليه العمل من تحمل المشتري لمصاريف إعداد العقد وأتعاب المحامى، والكاتب العمومى ورسوم التصديق على التوقيعات، ورسوم التسجيل وغيرها مما يتصل بتحرير العقد وتسجيله من المصروفات، وغالباً ما تدفع مصلحة المشتري صاحبها للقيام بتلك الإجراءات حتى تتم بالسرعة التى يتوخاها، وقد يقضى العرف باقتسام تلك المصروفات بين البائع والمشتري، ومن ثم إذا دفع البائع ما يخص المشتري من هذه القسمة يكون له أن يرجع عليه^(١)، وتكاليف المبيع تقع على عاتق المشتري من وقت المبيع، كما أنه له الحق في ثماره من هذا الوقت عملاً بقاعدة الغرم بالغرم.

(١) د. محمد السعيد رشدى - ص ١٩٤.

المبحث الثالث

التزام المشتري بتسلم المبيع

رأينا أن من التزامات البائع أن يقوم بتسليم المبيع للمشتري، وهو يكون بوضع الشيء المبيع تحت تصرفه، وهذا الالتزام يقابله التزام المشتري بتسليم المبيع، وهو يتحقق بأن يقوم المشتري بحيازة المبيع والاستيلاء عليه.

ووفقاً لما تقضى به المادة (٤٦٣) مدنى، فإنه إذا كان الشيء المبيع منقولاً موجوداً بموطن البائع ولم يوجد اتفاق أو عرف معين يبين مكان التسليم، فإنه يجب على المشتري أن يتسلم الشيء المبيع في موطن البائع، وإذا لم يتقدم لاستلامه كان مخلاً بالتزامه. وزمان التسلم هو زمان التسليم، إلا إذا وجد اتفاق خاص على غير ذلك.

ونفقات تسلم المبيع على المشتري، ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضى بغير ذلك، مادة (٤٦٤) مدنى، وعلى ذلك: فإن المشتري يتحمل نفقات نقل المبيع من المكان الذي يجب ان يتم فيه التسليم والتسلم إلى المكان الذي يقصده^(١).

وإذا اخل المشتري بالتزامه بتسلم المبيع كان للبائع أن يطالبه بتنفيذ التزامه عيناً، أو المالبة بالفسخ.

(١) د. السنهورى - فقرة ٤٢٤.

ويجوز للبائع بعد إعدار المشتري بالتسليم أن يحصل على إذن من القاضي بإيداع المبيع على ذمة المشتري ونفقته في مكان آخر إن كان منقولاً، أو أن يطلب وضعه تحت الحراسة إن كان عقاراً، مادة (٣٣٦) مدني، وإذا كان المبيع مما يتسارع إليه للتلف أو يقتضي نفقات مرتفعة في إيداعه أو حراسته، جاز للبائع أن يقوم ببيعه في المزاد العلني بعد أن يستأذن القاضي، ويودع الثمن خزانة المحكمة، ويجوز للبائع طلب فسخ البيع، مع حقه في المطالبة بتعويض عما يصيبه من ضرر، نتيجة لعدم تنفيذ المشتري لالتزامه بتسليم المبيع^(١)، وبعد إعدار المشتري لتسليم المبيع، إذا لم يتم بتسلمه وهلك، فإن تبعة الهلاك تقع عليه^(٢).

(١) د. عبد المنعم البدرأوى - السابق - ص ٥٧١.

(٢) د. عبد الرازق حسن فرج - المكان السابق.

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٥	مقدمة
٩	عقد البيع (تمهيد)
١٥	الباب التمهيدي تعريف البيع وتمييزه عما يختلط به من العقود
١٩	الفصل الأول: التعريف بالبيع وبيان خصائصه
١٩	المبحث الأول: تعريف عقد البيع
٢٣	المبحث الثاني: خصائص عقد البيع
٣٥	الفصل الثاني: تمييز عقد البيع عما يختلط به من العقود
٣٦	المبحث الأول: التمييز بين البيع والإيجار
٤٧	المبحث الثاني: البيع والمقايضة
٤٩	المبحث الثالث: البيع والوكالة
٥١	المبحث الرابع: البيع والهبة
٥٤	المبحث الخامس: البيع والمقايضة
٥٦	المبحث السادس: البيع والوصية
٦٥	الباب الأول أركان عقد البيع
٦٩	الفصل الأول: الرضا في عقد البيع

الموضوع	الصفحة
المبحث الأول: مضمون الرضا في عقد البيع	٧١
المطلب الأول: التراضي على العناصر الرئيسية في عقد البيع	٧١
المطلب الثاني: الأهلية اللازمة لإبرام عقد البيع	٧٧
المطلب الثالث: سلامة الإرادة من العيوب	٨٠
الفرع الأول: العلم بالمبيع علماً كافياً	٨٠
الفرع الثاني: الغبن في بيع عقار مملوك لناقص الأهلية	٩٠
المبحث الثاني: بعض الصور الخاصة للتراضي في عقد البيع	٩٩
المطلب الأول: الوعد بالمبيع أو بالشراء	٩٩
المطلب الثاني: البيوع الموصوفة	١٠٤
الفرع الأول: البيع بشرط التجربة	١٠٤
الفرع الثاني: بيع المذاق	١٠٨
الفرع الثالث: البيع بالعينة، أو النموذج	١١١
الفرع الرابع: البيع بالعربون	١١٥
الفصل الثاني: المبيع	١١٩
المبحث الأول: كون المبيع موجوداً أو قابلاً للوجود	١٢٠
المبحث الثاني : كون المبيع معيناً أو قابلاً للتعين	١٢٣

الصفحة	الموضوع
١٢٥	المبحث الثالث: قابلية الشيء للتعامل فيه
١٢٧	المبحث الرابع: أن يكون المبيع مملوكاً للبائع (أحكام بيع ملك الغير)
١٣١	المطلب الأول: حكم بيع ملك الغير فيما بين المتعاقدين
١٣٦	المطلب الثاني: حكم بيع ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي
١٣٨	المطلب الثالث: تأصيل أحكام بيع ملك الغير
١٤٣	الفصل الثالث: الثمن في عقد البيع
١٥١	الباب الثاني: آثار عقد البيع
١٥٥	الفصل الأول: التزامات البائع
١٥٦	المبحث الأول: التزام البائع بنقل الملكية
١٥٧	المطلب الأول: نقل ملكية المنقول المعين بالذات
١٦١	المطلب الثاني: نقل ملكية المنقول المعين بالنوع
١٦٣	المطلب الثالث: نقل الحقوق العقارية
١٧٦	المبحث الثاني: التزام البائع بتسليم المبيع
١٧٧	المطلب الأول: مضمون الالتزام بتسليم المبيع
١٧٧	الفرع الأول: معنى التسليم وكيفية
١٨٠	الفرع الثاني: نطاق الالتزام بالتسليم
١٨١	الفرع الثالث: حالة المبيع وقت التسليم

الصفحة	الموضوع
١٨٤	المطلب الثاني: أحكام الالتزام بتسليم المبيع
١٨٤	الفرع الأول: زمان التسليم ومكانه ونفقاته
١٨٦	الفرع الثاني: حق البائع في حبس المبيع
١٩٠	الفرع الثاني: تبعة هلاك المبيع قبل التسليم
١٩٤	المبحث الثالث: التزام البائع بالضمان
١٩٦	المطلب الأول: ضمان التعرض والاستحقاق
١٩٦	الفرع الأول: ضمان التعرض الشخصي
٢٠٢	الفرع الثاني: ضمان التعرض الصادر من الغير
٢١٠	الفرع الثالث: ضمان الاستحقاق
٢١٠	الموضوع الأول: التعويض في حالة الاستحقاق الكلى
٢١٦	الموضوع الثاني: التعويض في حالة الاستحقاق الجزئى
٢١٩	المطلب الثاني: ضمان العيوب الخفية
٢١٩	الفرع الأول: شروط العيب الموجب للضمان
٢٣١	الفصل الثاني: التزامات المشتري في عقد البيع
٢٣٢	المبحث الأول: التزام المشتري بدفع الثمن
٢٣٦	المبحث الثاني: التزام المشتري بالمصروفات
٢٣٧	المبحث الثالث: التزام المشتري بتسلم المبيع
٢٣٩	الفهرس